

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

CRISTIÁN BOETSCH GILLET

Los siguientes apuntes, cuyo exclusivo objeto es facilitar el estudio de la responsabilidad extracontractual por parte de los alumnos, han sido elaborados en base a extractos de diversos manuales de estudio, a los cuales se han adicionado comentarios.

De los manuales empleados se deben destacar los siguientes:

1. **ABELIUK MANASEVICH, René**, *Las Obligaciones*, Editorial Jurídica de Chile, 2001.
2. **ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo**, *De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno*, Editorial Jurídica de Chile, 2005
3. **BARROS BOURIE, Enrique**, *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica de Chile, 2006.
4. **BARROS BOURIE, Enrique**, *Apuntes de curso de responsabilidad civil*, Universidad de Chile, Facultad de Derecho.
5. **CORRAL TALCIANI, Hernán**, *Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual*, Editorial Jurídica de Chile, 2003.
6. **DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen**, *El Daño Moral*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2000.
7. **DUCCI CLARO, Carlos**, *Responsabilidad Civil (ex-contractual)*, Memoria de prueba, El Imparcial, 1936.
8. **GATICA PACHECO, Sergio**, *Aspectos de la indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato*, Editorial Jurídica de Chile, 1959.
9. **GONZALEZ CASTILLO, Joel**, *Apuntes de Responsabilidad Extracontractual*, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho..
10. **MEZA BARROS, Ramón**, *Manual de Derecho Civil. De las Fuentes de las Obligaciones*, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Octava Edición, 2000.
11. **RODRÍGUEZ GREZ, Pablo**, *Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica de Chile, 1999.
12. **ZELAYA, Pedro**, *La Responsabilidad Civil del Empresario por el Hecho de su Dependiente*, Revista de Derecho, Universidad de Concepción, N° 197 (1995).

TEMARIO

I.

ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL
3. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
4. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL
5. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL Y CUASICONTRACTUAL
6. REGLA GENERAL O DERECHO COMÚN DE RESPONSABILIDAD CIVIL
7. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
 - 7.1. Función primordial: reparación del daño
 - 7.2. Función de garantía de la libertad de actuar
 - 7.3. Función preventiva
 - 7.4. Función punitiva
8. SISTEMAS O MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD
 - 8.1. La responsabilidad subjetiva
 - 8.2. La responsabilidad objetiva

II.

LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO

A. LA CAPACIDAD DELICTUAL

1. REGLA GENERAL
2. INCAPACIDADES
 - 2.1. Incapacidad por discapacidad mental. Los dementes
 - (i) Concepto
 - (ii) Requisitos
 - (iii) La ebriedad como caso especial
 - 2.2. Incapacidad por minoría de edad. Infantes y menores
3. RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN DEL INCAPAZ

B. EL HECHO VOLUNTARIO

1. EL HECHO VOLUNTARIO
2. CASOS DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE VOLUNTAD
3. EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 - 3.1. Concepto
 - 3.2. Elementos
4. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS

C. LA ANTIJURIDICIDAD

1. CONCEPTO
2. CAUSALES QUE EXCLUYEN LA ILICITUD
 - 2.1. Ejecución de actos autorizados por el derecho
 - (i) El ejercicio de un derecho

- (ii) Cumplimiento de un deber legal
- (iii) Actos autorizados por usos normativos
- 2.2. El consentimiento de la víctima
- 2.3. El estado de necesidad
- 2.4. La legítima defensa

D. LA CULPABILIDAD

1. EXIGENCIA DE CULPABILIDAD.
2. DISTINCIÓN ENTRE DELITO Y CUASIDELITO CIVIL
3. EL DOLO
4. LA CULPA
 - 4.1. Concepto
 - 4.2. Apreciación de la culpa
 - 4.3. El estándar de cuidado: la culpa leve
 - 4.4. Culpa y previsibilidad
 - 4.5. Culpa infraccional
 - 4.6. Culpa por omisión
5. NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO DE CULPABILIDAD
6. PRUEBA DE LA CULPABILIDAD
7. PRESUNCIONES DE CULPA
 - 7.1. Consideraciones generales
 - 7.2. Presunción de culpabilidad por el hecho propio del art. 2329
 - 7.3. Condiciones de aplicación de la presunción

E. EL DAÑO

1. CONCEPTO
2. REQUISITOS DE RESARCIBILIDAD DEL DAÑO
 - 2.1. El daño debe lesionar un derecho o un interés legítimo
 - 2.2. El daño debe ser cierto
 - 2.3. Debe existir una relación directa con el hecho ilícito
 - 2.4. El daño no debe estar indemnizado
 - 2.5. El daño debe ser de una magnitud suficiente
 - 2.6. El daño debe ser previsible
 - 2.7. El daño debe haber sido personalmente sufrido por la víctima
3. CLASES DE DAÑOS
 - 3.1. Daño material o patrimonial
 - (i) El daño emergente
 - (ii) El lucro cesante
 - 3.2. Daño moral o extrapatrimonial
 - (i) Concepto
 - (ii) Resarcibilidad del daño moral
 - (iii) Categorías de daño moral
 - (iv) El daño moral en las personas jurídicas
 - (v) Prueba del daño moral
 - (vi) Evaluación del daño moral
4. PRUEBA DEL DAÑO
5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REGULACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN

F. LA CAUSALIDAD

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CAUSALIDAD
2. TEORIAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD
 - 2.1. Teorías empiristas
 - (i) Teoría de la equivalencia de las condiciones
 - (ii) Teoría de la causa adecuada
 - 2.2. Teorías normativas
 - (i) Teoría de la relevancia jurídica
 - (ii) Teoría de la imputación objetiva
3. LA CAUSALIDAD COMO UN TEMA EMPÍRICO Y NORMATIVO
4. PLURALIDAD DE CAUSAS
 - 4.1. Caso fortuito o fuerza mayor
 - 4.2. Pluralidad de agentes
 - 4.3. Concurrencia de culpa de la víctima
5. PRUEBA DE LA CAUSALIDAD
6. CALIFICACION DE LA CAUSALIDAD

III.

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

1. NOCIONES GENERALES
2. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO
 - 2.1. Capacidad delictual del hechor y responsable
 - 2.2. Comisión de un hecho ilícito por la persona de cuyos actos se responde
 - 2.3. Vínculo entre hechor y responsable
3. CASOS PARTICULARES DE TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES
 - 3.1. Responsabilidad del padre o madre por sus hijos menores que habiten con ellos
 - 3.2. Responsabilidad del guardador por el pupilo
 - 3.3. Responsabilidad de los jefes de escuelas y colegios por sus discípulos
 - 3.4. Responsabilidad del artesano por sus aprendices
 - 3.5. Responsabilidad del empresario por sus dependientes
 - 3.6. Responsabilidad del amo por sus criados o sirvientes
4. EXONERACIÓN DEL TERCERO RESPONSABLE
 - 4.1. Regla general
 - 4.2. Casos de improcedencia de exoneración de responsabilidad
5. ACCION DE REGRESO CONTRA EL SUBORDINADO
6. RESPONSABILIDAD DEL HECHOR

IV.

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS

1. NOCIONES GENERALES
2. DAÑOS CAUSADOS POR UN ANIMAL
 - 2.1. Regulación del Código Civil
 - 2.2. Regulación de la Ley N° 21.020
3. DAÑOS CAUSADOS POR LA RUINA DE UN EDIFICIO
 - 3.1. Acciones preventivas
 - 3.2. Acciones indemnizatorias
 - 3.3. Daños provenientes de vicios de construcción
4. DAÑOS CAUSADOS POR UNA COSA QUE CAE O SE ARROJA
 - 4.1. Acción preventiva

4.2. Acción indemnizatoria

V.**RESPONSABILIDAD OBJETIVA**

1. NOCIONES GENERALES
2. REGÍMENES LEGALES DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA
 - 2.1. Responsabilidad por daños causados por animales fieros
 - 2.2. Responsabilidad por daños ocasionados por las cosas que se arrojan o caen desde la parte superior de un edificio
 - 2.3. Responsabilidad por accidentes del trabajo
 - 2.4. Responsabilidad por daños ocasionados por el conductor de un vehículo motorizado
 - 2.5. Responsabilidad del explotador de aeronaves por daños ocasionados en caso de accidente aéreo
 - 2.6. Responsabilidad por daños ocasionados por aplicación de plaguicidas
 - 2.7. Daños ocasionados por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar
 - 2.8. Responsabilidad por daños nucleares
 - 2.9. Responsabilidad por daños causados en ejercicio de la facultad de catar y cavar
3. OBJETIVACION DE SECTORES DE RESPONSABILIDAD. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
 - 3.1. Responsabilidad de la Administración del Estado y de las Municipalidades
 - 3.2. Responsabilidad por error judicial
 - 3.3. Responsabilidad por actos legislativos

VI.**RESPONSABILIDAD PREVENTIVA**

1. CARACTERIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PREVENTIVA
2. EL DAÑO CONTINGENTE COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PREVENTIVA
3. LEGITIMACIÓN PASIVA
4. LEGITIMACIÓN ACTIVA
5. PRESCRIPCIÓN

VII.**ACCIÓN Y JUICIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD
2. OBJETO DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
 - 2.1. Formas de reparación
 - 2.2. Extensión de la reparación
 - (i) Principio general: la reparación integral
 - (ii) Reducción de la reparación
 - (iii) Reajustabilidad de la indemnización
 - (iv) Procedencia del pago de intereses
3. LEGITIMACIÓN ACTIVA
 - 3.1. Titulares por derecho propio
 - 3.2. Titulares por derecho derivado
 - 3.3. Titularidad de las "clases de perjudicados"
 - 3.4. Acción popular
4. LEGITIMACIÓN PASIVA
 - 4.1. Autor del hecho ilícito
 - 4.2. Responsable del hecho ajeno

- 4.3. El que recibe provecho del dolo ajeno
- 4.4. Los herederos
- 5. TRIBUNAL COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO
- 6. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD
 - 6.1. Renuncia
 - 6.2. Transacción
 - 6.3. Prescripción

VIII.
RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

- 1. DISCUSIÓN ACERCA DE LA DUALIDAD O UNIDAD DE RÉGIMENES
- 2. DIFERENCIAS ENTRE AMBAS RESPONSABILIDADES
- 3. CÚMULO O CONCURSO DE RESPONSABILIDADES
- 4. EJERCICIO CONJUNTO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL
- 5. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
- 6. RESPONSABILIDAD DE QUIEN CAUSA LA NULIDAD DEL CONTRATO
- 7. RESPONSABILIDAD POST CONTRACTUAL

I.

ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

En términos muy generales, la *responsabilidad* consiste en la necesidad efectiva, o eventual, en que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto que se le atribuye como propio.

En particular, la *responsabilidad civil* consiste en la necesidad en que se encuentra un individuo de tener que reparar un daño causado por su obrar doloso o culposo; tal necesidad se satisface por medio de la indemnización de perjuicios.

Como se puede observar, la responsabilidad civil se encuentra esencialmente vinculada al *daño* que sufre una o más personas, y al deber de repararlo o compensarlo con medios equivalentes. En este sentido, la Corte Suprema ha resuelto que “Por responsabilidad debe entenderse, en general, la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicios causado”. La esencialidad del daño exigida por la responsabilidad civil constituye una notable diferencia con la responsabilidad penal, pues esta última contempla la existencia de figuras delictivas de mero peligro y sanciona conductas tentativas y frustradas, sin daño.

2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad civil y penal son independientes entre sí: puede haber responsabilidad penal sin que exista responsabilidad civil (por ejemplo, si el hecho ilícito penal no ocasiona daños) y, a la inversa, es usual que los casos de responsabilidad civil no conlleven responsabilidad penal, como ocurre genéricamente cuando el hecho que ocasiona el daño no está tipificado como delito.

Las principales diferencias entre la responsabilidad civil y penal se expresan en las mayores exigencias que el derecho plantea para dar lugar a esta última.

Entre las múltiples diferencias entre uno y otro régimen se encuentran las siguientes:

(i) En materia penal el requisito de la *tipicidad* exige que la conducta que se sanciona se adecue exactamente a la descripción del delito que contiene la ley. En materia civil, en cambio, el concepto de ilicitud importa la infracción a un deber de cuidado que *puede* haber sido establecido en forma previa por la ley, en las hipótesis de culpa infraccional. En la generalidad de los casos, sin embargo, el tipo específico es determinado por el juez con posterioridad a la conducta que se juzga;

(ii) El daño es una condición necesaria de la responsabilidad civil, de manera tal que si la acción culpable no genera daño, no existe responsabilidad. En materia penal, en cambio, se sanciona el disvalor de la acción y no sólo del resultado. Es más, no resulta necesario que se produzca un daño efectivo al bien jurídico protegido para atribuir responsabilidad, salvo que se trate de un *delito de resultado*. Así se explica, además, que la ley penal contemple sanciones para la mera tentativa y el delito frustrado.

Estando sujeta la responsabilidad penal a requisitos más estrictos, la sentencia que se pronuncie en esa sede puede producir efectos en materia civil, lo que no ocurre en el sentido contrario.

En efecto, el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece la influencia de la *sentencia condenatoria* en los siguientes términos: “En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo”.

Por su parte, por regla general las *sentencias absolutorias* penales no producen cosa juzgada en materia civil, por cuanto de la circunstancia que no exista responsabilidad penal no se sigue necesariamente que tampoco exista responsabilidad civil. Así lo establece el artículo 179.1 del Código de Procedimiento Civil al señalar que las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo, sólo producen cosa juzgada en materia civil, cuando se funden en ciertas circunstancias que expresamente señala la misma disposición.

3. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad extracontractual se encuentra regulada en el XXXV del Libro IV del Código Civil (arts. 2314 a 2334), denominado “*De los delitos y cuasidelitos*”.

El Código otorga a los delitos y cuasidelitos civiles la categoría de fuente de obligaciones en los arts. 1437 y 2284. En efecto, el art. 1437 señala que: “Las obligaciones nacen [...] ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos [...]”; y el art. 2284 precisa que “Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un *delito*. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un *cuasidelito*”.

Puede definirse el *delito civil* como el hecho ilícito cometido con intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona (arts. 1437, 2284, 2314). *Cuasidelito civil* es, en cambio, el hecho culposo pero cometido sin intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona (arts. 1437, 2284, 2314).

El delito y cuasidelito se caracterizan porque son hechos ilícitos y causan daño.

El art. 2314 dice: “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

El hecho ilícito es fuente de obligaciones, porque da origen a una obligación que antes de él no existía: indemnizar los perjuicios causados. La responsabilidad nace al margen de la voluntad del acreedor o deudor; aunque se haya actuado con dolo (delito civil), o sea, con la intención de causar daño, el autor no ha querido adquirir una obligación, ha querido el daño, no ha querido convertirse en deudor de la reparación. Si sólo hay culpa (cuasidelito civil), o sea, negligencia o imprudencia, no hay intención de perjudicar y mucho menos de asumir una obligación.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Como se ha indicado, la imputación a una persona de la obligación de reparar un perjuicio es lo que constituye el contenido esencial del concepto de responsabilidad civil.

La *responsabilidad contractual* es la obligación del deudor de indemnizar al acreedor los perjuicios que le ha originado el incumplimiento, cumplimiento imperfecto o cumplimiento tardío de la obligación. Por su parte, la *responsabilidad extracontractual*, que se suele también llamar delictual o aquiliana (por la ley aquiliana que reglamentó la materia en la Roma antigua) consiste en la obligación en que se encuentra el autor de indemnizar los perjuicios que su hecho ilícito, delito o cuasidelito, ha ocasionado a la víctima.

Más adelante se hará referencia a una serie de aspectos relativos a ambos regímenes de responsabilidad, como son sus principales diferencias, el denominado cúmulo de responsabilidades y las interconexiones entre ambas.

5. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL Y CUASICONTRACTUAL

Mientras en materia extracontractual la acción que se concede a la víctima es esencialmente indemnizatoria y, según se ha dicho, tiene por objeto obtener la reparación íntegra del daño sufrido por ésta (artículo 2329 del Código Civil), en el ámbito cuasicontractual, en cambio, el derecho concede acciones meramente restitutorias, cuyo objeto es el resarcimiento de los costos directos en que el actor ha incurrido en beneficio de un tercero.

Un claro ejemplo del carácter restitutorio de las acciones emanadas de los cuasicontratos está representado por el artículo 2290 del Código Civil, aplicable a la agencia oficiosa. En virtud de esta norma, aquel que sin mediar mandato se ha hecho cargo de la administración de negocios ajenos (denominado *gerente*), sólo tiene derecho a que se le restituya lo invertido en expensas útiles o necesarias, pero no puede exigir que se le

remunere por sus actos. En otros términos, no tiene derecho a que se le indemnice por el lucro cesante (costo de oportunidad) que significa haber dedicado tiempo a la protección de los intereses de otro. Idéntico principio rige en el cuasicontrato de pago de lo no debido y, en general, en la acción innominada de enriquecimiento sin causa.

6. REGLA GENERAL O DERECHO COMÚN DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La legislación nacional regula dos grandes estatutos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual), pero no establece explícitamente el régimen común aplicable (por ejemplo, al incumplimiento de obligaciones legales).

Parte de la doctrina nacional sostiene que el régimen común de responsabilidad es el contractual, pues es el único que está regulado genéricamente a propósito de los efectos de las obligaciones (artículos 1545 y ss. del Código Civil). En este sentido, ALESSANDRI sostiene que el Título XII del Libro IV trata de la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones bajo el epígrafe “*Del efecto de las obligaciones*”, expresión que las involucra a todas, y se exceptúan los hechos ilícitos por el tratamiento separado que les otorga bastante más adelante. Se cita, además, en apoyo de esta tesis el contenido de los arts. 201, 250, 391, 427, 2308 y 2288, que hablan de culpa leve, de buen padre de familia y culpa levísima, etc., todas graduaciones de culpa, las que sólo serían admisibles en el terreno contractual, no obstante referirse a obligaciones legales o cuasicontractuales.

En contra de dicha posición, ciertos autores afirman que el Título XII discurre sobre la idea de una estipulación previa de las partes, cuestión que no acontece respecto de las obligaciones extracontractuales. Puede agregarse que el art. 2284 agrupa a las obligaciones que se contraen sin convención, refiriéndose a las obligaciones que nacen de la ley o del hecho voluntario de una de las partes, en este último caso hablamos de los delitos y cuasidelitos civiles y de los cuasicontratos, dando a entender claramente que dichas obligaciones tienen una naturaleza similar diferente de las obligaciones que emanan de la responsabilidad contractual (igual cosa hace el art. 578 respecto de los derechos personales o créditos). En consecuencia, aplicando una razón de analogía, y en consideración a que estamos frente a un vacío de la ley, que no establece cuál es el derecho común, puede decirse que la distinción precedente debe aplicarse para establecer la regla general en materia de responsabilidad. En consecuencia, habría que agrupar las obligaciones de la misma naturaleza bajo unas mismas reglas supletorias.

En otras palabras, el contrato supone necesariamente un acuerdo previo, que debe ser observado y cuya inobservancia genera una obligación indemnizatoria de segundo grado. Sin embargo, la mayoría de los deberes de cuidado a que se está sometido en el tráfico no dan lugar a relaciones obligatorias. Por ello, en la práctica, el régimen común es el de responsabilidad extracontractual, pues se refiere precisamente a esas relaciones que no están regidas por vínculo obligatorio preexistente.

La cuestión se torna más discutible en los casos en que existe una obligación preexistente, que no tiene su origen en el contrato sino en la ley, como la responsabilidad que surge del incumplimiento de la obligación de dar alimentos, o la que tienen los directores de una sociedad anónima respecto de los accionistas. Al respecto, ciertos autores afirman que en tales casos la responsabilidad sigue al incumplimiento de una obligación personal y podría regirse, por analogía, por las normas de la responsabilidad contractual.

7. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

7.1. Función primordial: reparación del daño

La responsabilidad civil extracontractual o derecho de daños apunta ciertamente a un gran y fundamental fin: reparar el daño causado, dejar a la víctima indemne. Es claro que no se pretende que el daño como tal desaparezca, puesto que éste ya se ha producido y la reparación que se obtenga mediante el ejercicio de la correspondiente acción de responsabilidad sólo conseguirá que otra persona asuma el costo que significa compensar, hasta donde sea posible, la pérdida sufrida por el perjudicado.

Sin perjuicio de lo anterior, que no se debate, adicionalmente la doctrina estima que la responsabilidad cumple otras funciones, que someramente se pasarán a analizar a continuación

7.2. Función de garantía de la libertad de actuar

La libertad de los privados encuentra, entre otros límites, la prohibición de causar un daño injustificado a otro. Nadie tiene derecho a actuar si con ello perjudica a alguien que no debe soportar ese daño: *alterum non laedere* (nadie debe dañar a otro injustamente).

En este sentido, la responsabilidad extracontractual sirve a los particulares para conocer la esfera de libertad que el ordenamiento jurídico les reconoce. En este sentido, puede decirse que la responsabilidad es un elemento de garantía de la persona que permite saber a priori cuáles eventos pueden serle imputados a quien actúa y consiente a la persona una libre elección de sus propios comportamientos.

7.3. Función preventiva

El derecho de daños cumple también una función disuasiva, tanto en el sentido particular del que ya ha sufrido la condena civil por un actuar injusto, como del resto de los integrantes de la sociedad. Parece lógico que, desde el punto de vista psicológico, la persona que ha obrado dañinamente y en virtud de esta acción se ve conminada a soportar en su patrimonio el costo del daño causado, tratará de evitar en el futuro la conducta descuidada o dolosa que le produjo tal pérdida.

Lo mismo puede decirse de los demás miembros de la sociedad que son advertidos de no producir ciertos daños o de ser más cuidadosos para evitar incurrir en los desembolsos de aquellos que han sido condenados por algún hecho culposos o doloso.

7.4. **Función punitiva**

Existen sistemas de derecho de daños en los que la responsabilidad declaradamente cumple una función punitiva o represiva. Es el caso del régimen de responsabilidad que existe en el sistema jurídico angloamericano (*Tort Law*).

En este esquema se reconoce que el Derecho de *Torts* cumple tres funciones: *compensation* (reparación), *deterrence* (disuasión) y *punishment* (sanción). La aplicación de los llamados *punitive damages* frente a ilícitos civiles (*torts*) es la forma de cumplir esta función punitiva: se trata de una suma de dinero que el juez puede ordenar pagar a la víctima más allá de la indemnización reparatoria; cuestión que sólo es procedente en casos de ilícitos de especial malignidad o gravedad. Así, por ejemplo, en el sistema inglés, existen tres categorías de daños punitivos: a) los casos de acción represiva, arbitraria e inconstitucional de los funcionarios del gobierno; b) los casos en que el demandado calculó su conducta dañina de manera de sacar un provecho superior a la indemnización meramente reparatoria que correspondería al demandante; c) y finalmente los casos en los que tales daños son expresamente autorizados por algunos *statute*, por ejemplo, el *Copyright, Designs and Patent Act* de 1988.

En los sistemas de Derecho civil continental, la figura de los daños punitivos es desconocida. Se estima que el acordar al demandante una cantidad de dinero no como reparación sino como pena privada atentaría contra los principios constitucionales que reglan el debido proceso y la aplicación de penas.

Ahora bien, en ocasiones la propia ley civil mezcla la finalidad reparatoria con la sancionatoria. Es lo que sucede, por ejemplo, con el art. 1768, que dispone que aquel de los cónyuges que dolosamente hubiere ocultado o destruido alguna cosa de la sociedad perderá su porción en la misma y se verá obligado a restituirla doblada.

8. **SISTEMAS O MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

La pregunta esencial que plantea la responsabilidad civil dice relación con las razones o fundamentos que el derecho considera a efectos de establecer que una determinada persona debe responder por un daño sufrido por una víctima.

En general, dos tendencias existen principalmente para fundamentar la responsabilidad por el hecho ilícito: la responsabilidad subjetiva o por culpa, y la responsabilidad estricta, objetiva o sin culpa.

8.1. La responsabilidad subjetiva

La doctrina clásica señala como fundamento de la obligación que la ley impone de indemnizar el daño causado, la culpabilidad del agente, esto es, la actitud reproachable del autor del delito o cuasidelito, que puede recorrer una cierta graduación desde el dolo a la negligencia, pero que le impone la necesidad de responder de su conducta. Para esta doctrina, dos son los requisitos fundamentales de la responsabilidad extracontractual: el daño y que él haya sido originado por la culpa o dolo de quien lo ha provocado.

Precisamente se la llama subjetiva o por culpa, porque la razón de existir de la obligación indemnizatoria es la actuación ilícita del agente del daño. En otras palabras, la razón para atribuir responsabilidad a un tercero radica en que el daño ha sido causado por su acción culpable, esto es, ha sido el resultado de una acción ejecutada con infracción a un deber de cuidado. Este deber puede ser establecido por el legislador, mediante la dictación de reglas de conducta orientadas a evitar accidentes (como ocurre en la Ley del Tránsito o en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente), o bien ser el resultado de una regla no legislada, definida por los jueces recurriendo a la costumbre o a criterios de responsabilidad.

Atendida la enorme plasticidad y variedad de la conducta humana, así como la cantidad de riesgos que impone la vida en sociedad, la mayor parte de estos deberes de cuidado no pueden ser definidos con exhaustividad por la ley, quedando entregada su determinación a los jueces. En esto existe una radical diferencia entre la responsabilidad civil y la penal, en la que el requisito de tipicidad excluye la posibilidad que el ilícito sea definido en alguna instancia judicial, sin la existencia de una ley anterior que describa y sancione la conducta.

El sistema de responsabilidad subjetiva no ha estado exento de críticas.

Se señala al respecto que resulta dificultoso para la víctima probar la culpa.

Al efecto, se indica que exigir culpa en la responsabilidad civil es confundirla con la responsabilidad moral y penal, en que justamente se sanciona una actitud culpable del agente; en la primera, en cambio, lo único que importa es el daño ocasionado.

Luego se la criticó por motivos de justicia social. En efecto, el problema adquirió caracteres más dramáticos en los accidentes del trabajo, en que los obreros quedaban prácticamente desamparados para luchar en pleitos largos y engorrosos con las empresas. Generalmente la víctima es de menos recursos que el autor del daño, y el legislador debe protegerla. Por ello se criticó a la doctrina subjetiva que mira más a la actuación del autor del daño que hacia la situación de la víctima, que evidentemente merece mayor protección.

El sistema de responsabilidad civil por culpa o negligencia es el régimen común de responsabilidad en el derecho nacional, aplicable a todos aquellos casos que no están regidos por una regla especial diversa. Así lo entiende ALESSANDRI: "Nuestro Código Civil consagra la teoría clásica de la responsabilidad subjetiva en toda su amplitud; la teoría del riesgo no la admite en caso alguno. No podría ser de otro modo si se considera que fue dictado en una época -1855- en que nadie discutía ni ponía en duda la necesidad de la

culpa o dolo de parte del autor del daño para comprometer su responsabilidad”. A la responsabilidad por culpa o negligencia se refiere como regla general los artículos 2284, 2314 y 2329 del Código Civil.

8.2. La responsabilidad objetiva

A diferencia del modelo general de responsabilidad por culpa o negligencia, la responsabilidad estricta u objetiva tiene como antecedente el riesgo generado por una determinada conducta y no la negligencia, de modo que es indiferente el juicio de valor respecto de la conducta del autor del daño.

Si bien el análisis particular de la responsabilidad objetiva se realizará en el Capítulo V de estos Apuntes, desde ya cabe destacar que se trata de un régimen especial y como tal de derecho estricto, que opera sólo respecto de ciertos ámbitos de conducta o de tipos de riesgos previamente definidos por el legislador

II.

LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO

Según la doctrina y jurisprudencia tradicional, encabezada por ALESSANDRI, los elementos que integran la responsabilidad civil por culpa o negligencia son: la capacidad, el dolo o la culpa, el daño y la relación de causalidad. Por su parte, la doctrina moderna suele subsumir el estudio de la capacidad en un elemento más amplio, como es el hecho voluntario, agregando además la antijuridicidad.

Si bien uno y otro enfoque considera toda la reglamentación que el Código Civil otorga a la responsabilidad extracontractual, en este capítulo se seguirá la sistematización que el profesor CORRAL realiza respecto de los elementos de la responsabilidad, los cuales son los siguientes:

- (a) El presupuesto general de la responsabilidad es la *capacidad delictual*;
- (b) Contando con tal presupuesto, en primer lugar, se necesita que el hecho o acto sea originado en la voluntad del ser humano; esto es se requiere de un *acto humano*;
- (c) Luego, debe exigirse que tal hecho voluntario sea *antijurídico*, esto es, que contraste con el derecho, es decir, sea injusto o ilícito desde un punto de vista objetivo;
- (d) El hecho voluntario antijurídico debe ser reprochable o imputable al dolo o culpa de una persona (*culpabilidad*);
- (e) Adicionalmente, el hecho debe haber efectivamente producido un *daño*.
- (f) Por último, debe existir una relación de *causalidad* entre el hecho y el daño producido.

A continuación se analizarán en detalle cada uno de estos elementos.

A. LA CAPACIDAD DELICTUAL

1. REGLA GENERAL

La capacidad constituye una condición de imputabilidad de la responsabilidad civil, que, en tal sentido, muestra su carácter retributivo. En efecto, la imputabilidad supone que el autor sea capaz, y ello exige algún grado mínimo de aptitud de deliberación para discernir

lo que es correcto. Así, la **capacidad es la aptitud que tiene una persona para contraer la obligación de reparar un daño.**

La regla general en materia extracontractual, más ampliamente aún que en otros campos, es **la capacidad para responder de los daños ocasionados por un hecho ilícito.** En consecuencia, el estudio de la capacidad delictual se resuelve en el análisis de las incapacidades establecidas en la ley.

2. INCAPACIDADES

De acuerdo al art. 2319 las incapacidades en materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual pueden sintetizarse en dos causas: falta de razón o demencia, y minoría de edad.

2.1. Incapacidad por discapacidad mental. Los dementes

(i) **Concepto**

En términos generales, demente es aquella persona privada de razón. ALESSANDRI sostiene que son dementes los que, al tiempo de ejecutar el hecho, están privados de la razón por causas patológicas.

En materia de responsabilidad extracontractual determinar esta privación de razón es una **cuestión de hecho**, que debe ser **probada** al ser opuesta como excepción perentoria en un juicio de responsabilidad. Sin embargo, es también una **cuestión normativa**, porque el concepto jurídico de demencia no es idéntico al de la medicina. Por esa misma razón, la noción jurídica de demencia no es necesariamente coincidente en materia de responsabilidad contractual y extracontractual, ya que el **umbral de deliberación exigido por el derecho puede diferir en una y en otra.**

(ii) **Requisitos**

Para que la demencia sea causa de **imputabilidad**, se precisan los siguientes requisitos:

a) *Que la demencia sea actual.* La discapacidad mental es una situación permanente. Pero lo importante es que al momento de ejecutarse el hecho el agente estuviera imposibilitado de deliberar normalmente.

Al respecto, ciertos autores afirman que el demente **es responsable si ha actuado en un “intervalo lúcido”**, a diferencia de lo que ocurre en materia contractual, en que si se ha declarado la interdicción no se acepta dicha excepción (art. 465). Sin embargo, en la psiquiatría moderna se tiende a **negar la posibilidad de que existan realmente estas “lagunas de cordura”** dentro de una enfermedad mental. Por su parte, BARROS afirma que en materia extracontractual el **decreto de interdicción es sólo un antecedente**, que podrá servir de base para una declaración judicial específica de demencia en el juicio

de responsabilidad, pero que no produce efectos necesarios. En consecuencia, al menos teóricamente, el interdicto por demencia puede ser tenido por capaz para efectos de establecer su responsabilidad extracontractual.

b) *Que la demencia sea total.* El sujeto debe estar absolutamente impedido de darse cuenta del acto y de sus consecuencias; al punto que no pueda determinar su voluntad de acuerdo al conocimiento adquirido.

c) *Que la demencia no sea imputable a la voluntad del sujeto.* Este es un requisito no generalmente admitido por los autores; sin embargo, la regulación que el Código Civil realiza respecto del ebrio da cuenta de un principio general sobre la materia.

(iii) La ebriedad como caso especial

El art. 2318 dispone que “El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito”.

Su responsabilidad se funda en su culpabilidad por haberse colocado en tal estado (*actio liberae in causa*); por ello, no obstante la amplitud del precepto, la doctrina concluye que no estaría obligado por su hecho ilícito si ha sido colocado en este estado por obra de un tercero y contra su voluntad, lo que se extiende igualmente a cualquier otra intoxicación, como por estupefacientes. En tal caso, el intoxicado o ebrio no tiene culpa, y ella correspondería a quien lo colocó en tal situación.

2.2. Incapacidad por minoría de edad. Infantes y menores

Para determinar la capacidad delictual hay que distinguir dos situaciones:

a) *Infantes.* Según el art. 2319.1 “no son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años”; esto es, los infantes (art. 26).

b) *Mayores de siete años y menores de dieciséis.* En este caso, el Código ha dispuesto que la inimputabilidad se determine judicialmente caso a caso: “Queda a la prudencia del juez -dice la disposición- determinar si el menor de 16 años ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento” (art. 2319.2).

En consecuencia, la plena capacidad para los hechos ilícitos se adquiere a los 16 años, pero puede extenderse en el caso señalado hasta los 7 años.

Al influjo de la concepción objetiva de la responsabilidad, la legislación contemporánea tiende a abolir, en mayor o menor grado, la irresponsabilidad del incapaz.

En algunas legislaciones el incapaz debe reparar el daño cuando la reparación no ha podido obtenerse de quien lo tiene a su cuidado (Código alemán); otras otorgan al juez la

facultad de condenar al incapaz, cuando la equidad lo exija (Código suizo de las obligaciones); el incapaz, en fin, suele ser plenamente responsable (Código mexicano).

3. RESPONSABILIDAD DEL GUARDIÁN DEL INCAPAZ

En materia de responsabilidades el término “guardián” se usa para designar a la persona que tiene a su cargo a otra o a una cosa y debe vigilarla; si no cumple este deber es responsable de los daños que ocasione esa persona o cosa, y su culpa consiste precisamente en haber faltado a dicha obligación.

Así ocurre con los incapaces: responde de los daños por ellos causados quien debe vigilarlos. Así lo señala el art. 2319.1: “pero serán responsables de los daños causados por ellos [los incapaces], las personas a cuyo cargo estén si pudiese imputárseles negligencia”. Esto es, la víctima debe probar la negligencia del guardián.

En el artículo siguiente (2320), el Código trata la responsabilidad por el hecho ajeno, como la del padre por los hechos ilícitos del hijo menor, etc., que difiere fundamentalmente de la que establece el art. 2319 en un doble sentido: (a) en ésta no hay hecho ilícito del incapaz, pues falta el requisito de la capacidad; lo hay del guardián por su negligencia. Este responde del hecho propio, mientras en la responsabilidad indirecta del art. 2320 se responde del hecho ilícito de otra persona capaz, y que también es responsable; y (b) en la responsabilidad indirecta se presume la culpa del responsable por el hecho ajeno, y a él corresponderá probar su ausencia de culpa, mientras que tratándose de un incapaz, la víctima debe probar la negligencia del guardián. A primera vista podría pensarse que la distinción es injusta y odiosa; pero la verdad es que hay una diferencia fundamental entre un caso y otro.

En cualquier caso, el guardián soporta definitivamente la indemnización; no puede repetir contra el incapaz, pues éste no ha cometido hecho ilícito. Así se deduce a contrario sensu del art. 2325, que da derecho a pedir restitución del que “era capaz de delito, cuasidelito, según el art. 2319”.

B. EL HECHO VOLUNTARIO

1. EL HECHO VOLUNTARIO

La responsabilidad tiene por antecedente el acto humano, esto es, el hecho voluntario. No hay propiamente responsabilidad si no existe un daño reconducible a la conducta libre de un sujeto, que puede consistir en un hecho positivo (una acción), o en uno negativo (una omisión). Este principio de la responsabilidad civil se encuentra recogido en nuestro derecho, y en particular, en las normas de los artículos 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil.

Por regla general, los daños relevantes para el derecho son los producidos a consecuencia de una acción.

La omisión se configura cuando el deber general de cuidado prescribía al agente el asumir una determinada conducta y éste no la realizó.

2. CASOS DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR FALTA DE VOLUNTAD

La doctrina suele asimilar a la demencia estados transitorios de pérdida del uso de la razón, como quien actúa en estado de hipnosis o sonámbulo.

Al efecto, CORRAL afirma que estos casos no deben asimilarse a la demencia, en cuanto es una causal de incapacidad, y por lo mismo califica a una persona de un modo permanente. Los estados transitorios de falta de uso de razón son más bien causales de exoneración por falta de voluntariedad de la acción.

3. EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

3.1. Concepto

Según el art. 45 del Código, “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Cierta doctrina afirma que el caso fortuito constituye una causal de exoneración de responsabilidad por falta de antijuridicidad, o de culpa, o de nexo causal entre el hecho y el daño. Por su parte, siguiendo a CORRAL lo cierto es que lo más propio es ubicarlo como causal de supresión de la voluntariedad del hecho: cuando un daño se produce por un caso fortuito, en rigor no puede ser vinculado a una voluntad humana.

3.2. Elementos

Los elementos del caso fortuito o fuerza mayor son: (a) la irresistibilidad; (b) la imprevisibilidad; y, (c) la exterioridad.

(a) *Irresistibilidad*. El carácter de irresistibilidad se expresa con claridad en el concepto de fuerza mayor. Lo que se exige es que se trate de un evento insuperable, que no sea posible evitar sus consecuencias.

El límite de la irresistibilidad está dado por el deber de diligencia del actor, en forma similar a la obligación contractual de medio. Es decir, la irresistibilidad se mide en función del deber de cuidado.

b) *Imprevisibilidad.* También la imprevisibilidad está en las fronteras de la culpa: el caso fortuito comienza donde cesa el deber de previsión. No se trata de algo absolutamente imprevisible, sino imprevisible para el autor del daño atendido el nivel de diligencia que le es exigible. Por tanto es un concepto normativo: aquello que el autor no estaba obligado a prever.

De esta manera es caso fortuito el reventón del neumático de un automóvil nuevo o el síncope de una persona sin antecedentes cardíacos, y no lo es, un temblor grado cinco a seis en la zona central de Chile.

c) *Exterioridad.* El hecho debe ser externo a la esfera de acción del agente. Este requisito de exterioridad es constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor, pues pertenece al terreno de estricta causalidad (los elementos anteriores pueden conducir al terreno de la culpa). Es indiferente que el daño provenga de un hecho de la naturaleza o del hecho culpable o no de un tercero: lo decisivo es que **sea ajeno al ámbito de cuidado del demandado**. También tiene el carácter de exterior la hipótesis de culpa de la víctima que resulta ser la causa jurídicamente excluyente de la ocurrencia del daño; respecto del autor es un hecho que está fuera de su control y por el cual no puede ser considerado responsable, aunque su acción sea remota causa necesaria del perjuicio.

Este requisito es especialmente importante en los regímenes de responsabilidad estricta, pues la previsibilidad e irresistibilidad pueden no ser excusa suficiente en la medida en que haya intervenido como causa del daño el riesgo creado por la acción, pero pesará como fuerza mayor si el daño se debió a un hecho externo al ámbito de riesgo cubierto por la regla de responsabilidad estricta. Aunque una responsabilidad estricta muy extensa puede comprender el caso fortuito.

4. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS

Atendido que se exige la voluntad humana para generar responsabilidad, surge el problema de la posibilidad de que respondan las personas jurídicas. El tema ha sido discutido para quienes sostienen que la persona jurídica es una mera ficción, en cuanto no cabe hablar de una “voluntad” real de la asociación.

Sin embargo, en Chile la responsabilidad civil extracontractual está formalmente reconocida en el art. 58 del Código Procesal Penal (ex art. 39 del Código de Procedimiento Penal), que dice: “La acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito. La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas **responden los que hubieren intervenido en el acto punible**, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare”.

Esta disposición deja en claro que las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidad civil, de indemnizar los daños que sus órganos o representantes causen.

Tradicionalmente se ha sostenido que la persona jurídica responde por el hecho propio cuando el ilícito ha sido cometido por un órgano en ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, el concepto de órgano carece de límites bien definidos en materia civil. En principio, son órganos de una persona jurídica todas las personas naturales que actuando en forma individual o colectiva, están dotadas por la ley o los estatutos de poder de decisión, como ocurre, por ejemplo, con la junta de accionistas, el directorio y el gerente en una sociedad anónima.

La noción de órgano ha sido extendida a todas aquellas personas dotadas permanentemente de poder de representación, es decir, facultadas para expresar la voluntad de la persona jurídica. Lo determinante es el poder autónomo y permanente de decisión, materia que es una cuestión de hecho que debe ser analizada en concreto.

La citada disposición del Código Procesal Penal se pone en el caso de que el hecho ilícito que engendra responsabilidad sea al mismo tiempo penal y civil: en el primer carácter afecta al individuo que obró y él irá a la cárcel si ésta es la sanción del caso, y la persona jurídica soportará la indemnización de perjuicios a que haya lugar. En todo caso, la doctrina y jurisprudencia aceptan la responsabilidad civil de la persona jurídica, aún cuando el hecho no constituya un ilícito penal.

C. LA ANTIJURIDICIDAD

1. CONCEPTO

Para que haya responsabilidad es necesario que el daño provenga de un comportamiento *objetivamente ilícito*, contrario al ordenamiento, contrario a lo justo.

Así se deduce de las siguientes disposiciones: (i) el art. 1437 señala que es fuente de obligaciones el “hecho que ha inferido injuria o daño”; (ii) el art. 2284 agrega que “Si el hecho es *ilícito*, y cometido con intención de dañar, constituye un delito [...]”.

La valoración de la licitud de la conducta generadora de la responsabilidad puede fundarse en una infracción a un deber legal expreso o en la transgresión del principio general de que no es lícito dañar sin causa justificada a otro.

En la doctrina nacional generalmente no se considera la antijuridicidad como un elemento autónomo de la responsabilidad, por cuanto se le subsume en la culpabilidad: si hay dolo o culpa, es porque hay ilicitud; o en el daño: sólo se indemniza el daño injusto.

CORRAL y RODRÍGUEZ son de la opinión contraria, por cuanto no necesariamente la ilicitud va vinculada a la culpabilidad o al daño: puede haber culpa, pero no ilicitud, y un daño puede causarse de manera justificada, en cuanto opere alguna causal de justificación.

En relación a la materia, el análisis de la ilicitud se centrará en la constatación de si el hecho en cuestión constituye una infracción a una norma positiva o va en contra del principio general de que nadie puede dañar injustamente a otro (*alterum non laedere*).

Si bien a diferencia del derecho penal en materia civil no se exige la tipicidad como requisito de la responsabilidad, en ciertas ocasiones la ley civil describe ciertas conductas que considera causantes de responsabilidad civil extracontractual (v.gr. arts. 423, 631, 926, 934, 1287, 1336, 1768 y 1792.18), casos en los cuales la doctrina habla del *ilícito civil típico*. CORRAL afirma que tal tipificación cumple la función de ser un indicio de la antijuridicidad de la conducta; por su parte, RODRÍGUEZ sostiene que el ilícito civil típico funcionaría de un modo semejante a la responsabilidad objetiva.

2. CAUSALES QUE EXCLUYEN LA ILICITUD

Si bien la ley no ha reglamentado las causas eximentes de responsabilidad civil, la doctrina las ha identificado, destacándose al efecto las siguientes: La ejecución de actos autorizados por el derecho; El consentimiento de la víctima; El estado de necesidad; y, La legítima defensa.

En opinión de ALESSANDRI, entre las causales de justificación que denomina “eximentes de responsabilidad”, se incluyen además el caso fortuito o fuerza mayor, la violencia física o moral, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero. Sin embargo, si bien las causales señaladas determinan la inexistencia de responsabilidad, no lo hacen por la vía de excluir la ilicitud, sino actuando sobre otros elementos de la responsabilidad por negligencia, como la voluntariedad del acto.

2.1. Ejecución de actos autorizados por el derecho

Dentro de estos actos es posible distinguir: (a) los ejecutados en ejercicio de un derecho, (b) los ejecutados en cumplimiento de un deber legal, y (c) los autorizados por usos normativos.

(i) El ejercicio de un derecho

El ejercicio de un derecho elimina la ilicitud de la acción que causa el daño y, por ello, en principio no hay ilicitud en el hecho de que un restaurante se instale a media cuadra de otro ya existente y le prive de parte de su clientela, siempre que respete las normas de la libre competencia o el mero ejercicio de una acción judicial, aunque los tribunales no la acojan en definitiva, no constituye injuria o daño por sí solo.

Pero el ejercicio de un derecho, en sí mismo justo, puede llegar a ser ilícito o injusto: puede causar daño ilegítimamente. Nace así la teoría del **abuso del derecho**, que sostiene que el ejercicio abusivo de un derecho genera obligación de reparar los perjuicios producidos.

La doctrina tradicional solía sostener que un derecho subjetivo es una potestad otorgada por el Derecho Objetivo a un determinado sujeto, para realizar una determinada actuación en el ámbito jurídico. Al respecto, en un principio, los autores de carácter más individualista, destacando entre ellos PLANIOL, sostuvieron que el contenido del derecho era el único límite del mismo, pues de lo contrario se caería en una situación que atentaría a toda lógica, pues no puede ejercerse a la vez un derecho que sea contrario a derecho, pues nada puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido (principio de la no contradicción). Como es claro, para estos autores no sería posible, desde un punto de vista lógico, hablar de “abuso del derecho”.

Sin embargo, con posterioridad JOSSEAND, contradiciendo la tesis de PLANIOL, introduce la teoría del abuso del derecho, postulando que se abusaba de un derecho subjetivo cuando era ejercido contrariando su función social y económica; en otras palabras, el ejercicio abusivo tiene lugar cuando un derecho subjetivo se ejerce en desacuerdo con el derecho objetivo, agregando que para determinar si existe un abuso será necesario indagar en los motivos que han inducido a obrar al titular o el fin que se ha propuesto alcanzar. Por su parte, otros autores, como RIPERT y MAZEAD –seguidos en nuestro medio por ALESSANDRI-, entienden que el abuso del derecho es una culpa cometida en el ejercicio de ese derecho, lo que por ende da lugar a responsabilidad civil.

Sin perjuicio de las múltiples opiniones y posturas que existen sobre la materia, muy buena parte de los autores estima que existirá abuso del derecho, y por lo tanto se limitará el ejercicio del mismo, cuando este sea ejercido de manera desleal, esto es, contrariando a la buena fe y a las buenas costumbres. Así, Ferreira Rubio señala que “la buena fe indica un límite, es decir algo que no debe sobrepasarse, sin provocar consecuencias negativas. Ese margen está representado por el respeto a los demás, por el cumplimiento de las normas que impone la buena fe”. Por su parte, DIEZ-PICAZO señala que “el ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la buena fe no sólo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o función económica o social para la cual ha sido atribuido a su titular, sino también cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone en el tráfico jurídico [...] Los derechos subjetivos han de ejercitarse siempre de buena fe. Más allá de la buena fe el acto es inadmisibles y se torna antijurídico”. En nuestro medio, BARROS afirma que “la buena fe expresa en el derecho aquel núcleo de sentido que subyace a las normas atributivas de derechos, que se muestra en los límites que la norma no expresa, pero da por supuesto”.

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos múltiples disposiciones que dan cuenta de las limitaciones en el ejercicio del derecho subjetivo por excelencia, como es la propiedad. En primer término, la Constitución Política establece en su artículo 19 N° 24 que el ejercicio de la propiedad puede encontrar limitaciones que deriven de su “función social”, la que conforme a la Carta Fundamental comprende “cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”. Por su parte, al definir el artículo 582 del Código Civil el derecho de dominio, establece que el mismo habilita a gozar y disponer arbitrariamente de la cosa corporal sobre el que recae, pero “no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno”. Esta última disposición y los límites por ella impuestos se extienden a todas las cosas incorporales (derechos) en conformidad al artículo 583 del mismo cuerpo legal.

Cabe agregar que el Código Civil establece casos de abuso de derecho precisamente en base a la trasgresión de la buena fe con la cual deben ser ejercidos. Así aparece en los artículos 2110 a 2112, que establecen que en el contrato de sociedad no vale la renuncia que se hace de mala fe o intempestivamente, especificando al efecto que “renuncia de mala fe el socio que lo hace por apropiarse una ganancia que debía pertenecer a la sociedad; en este caso podrán los socios obligarle a partir con ellos las utilidades del negocio, o a soportar exclusivamente las pérdidas, si el negocio tuviere mal éxito. Podrán asimismo excluirle de toda participación en los beneficios sociales y obligarle a soportar su cuota en las pérdidas.”

En general, la jurisprudencia estima que el abuso del derecho constituye un ilícito civil que da lugar y se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual.

En este sentido, en un reciente fallo del año 2007 se resolvió que “la doctrina del abuso del derecho asume que el ejercicio de un derecho puede ser ilícito, aunque el titular actúe dentro de los límites externos que establece el respectivo ordenamiento normativo y sólo puede ser invocada cuando el comportamiento del titular atenta contra estándares mínimos de conducta”, agregando que “en general, la jurisprudencia es constante en someter el ejercicio del derecho a las reglas de la responsabilidad civil y exigir dolo o culpa para que se genere la obligación indemnizatoria” y que “cualquiera que sea el ámbito de aplicación de la doctrina sobre el abuso del derecho, dolo, culpa o negligencia, irracionalidad en su ejercicio, falta de interés o necesidad legítimos, intención del agente en perjudicar, o con desvío de los fines de la institución o para los que fue concebida e incluso, aplicado a procedimientos judiciales, es evidente que, de parte del agente causante del mal, debe existir un ánimo manifiesto de perjudicar o una evidente falta de interés o de necesidad de lo que promueva o un actuar motivado por el afán de causar un perjuicio a su contraparte o co-contratante. Esa intención de perjudicar no sólo debe manifestarse, como es lógico, cuando se actúa en la órbita de la irresponsabilidad extracontractual, sino que también para el caso en que el acto se ejecute excediendo el interés jurídicamente protegido”

(ii) Cumplimiento de un deber legal

Igualmente quien actúa en cumplimiento de un deber impuesto por la ley no comete ilícito alguno. Tal es el caso del agente de policía que priva de libertad al detenido, o del receptor judicial que traba un embargo.

Algo más complejo es el tema de la observancia de órdenes emanadas de autoridad competente. Por regla general, la circunstancia de actuar en cumplimiento de una orden de autoridad actúa como causal de justificación siempre y cuando dicha orden no sea manifiestamente ilegal.

Sin embargo, subsiste la pregunta respecto de la forma en que el destinatario de la orden debe plantear su ilegalidad para beneficiarse de la excusa: ¿basta la mera representación de la ilegalidad al superior o es necesario rechazar la orden? CORRAL afirma que lo relevante es determinar el grado de coerción de la orden, esto es, si la misma es capaz de suprimir la voluntariedad (lo que raramente ocurrirá).

(iii) Actos autorizados por usos normativos

Más allá de las fuentes formales, la ilicitud en materia civil se refiere a aquello que es generalmente considerado como impropio. De este modo, queda también excluida la culpa cuando la conducta da cuenta de usos o prácticas que son tenidos comúnmente por correctos.

En este sentido, la incisión que hace el médico al operar conforme a las prescripciones de su *lex artis*, o las lesiones que ocasiona el futbolista que ejecuta una acción violenta, pero tolerada por las reglas del juego, no constituyen hechos ilícitos. En todos estos casos, el límite está dado por los deberes de cuidado que rigen cada actividad. Luego, sólo la infracción a esos deberes, y no la lesión producida, acarreará responsabilidad.

2.2. El consentimiento de la víctima

Tratándose de responsabilidad civil extracontractual, es normal que no exista relación previa entre la víctima y el autor del daño. En este ámbito los encuentros son, por regla general, casuales.

Sin embargo, nada obsta a que en esta materia puedan existir *acuerdos previos* entre el potencial autor del daño y la eventual víctima, ya sea en la forma de autorizaciones para realizar un determinado acto (caso en el cual el *acuerdo* es, en rigor, un acto jurídico unilateral), o de convenciones sobre responsabilidad, por medio de los cuales se acepta un cierto nivel de riesgo, se modifican condiciones de responsabilidad, etc.

Se ha discutido acerca de la validez de las estipulaciones destinadas a suprimir o modificar la responsabilidad del autor del daño, la que en materia extracontractual puede presentarse, por ejemplo, si antes de un evento deportivo —v.gr. una carrera automovilística— se establece entre los participantes la recíproca irresponsabilidad por los accidentes que puedan ocurrir, o si entre vecinos se conviene ella por los daños que posiblemente ocurran, etc.

Se distinguen dos clases de convenciones sobre responsabilidad: las unas eximen a la persona de toda obligación de indemnizar; las otras la limitan en cierta forma (por ejemplo, a una determinada suma de dinero).

La existencia de una estipulación sobre responsabilidad no hace derivar ésta en contractual, porque ella supone una obligación previa que no se ha cumplido.

Cuando la víctima potencial presta su consentimiento autorizando la ejecución de un acto que puede causarle daño, realiza un acto de disposición, que, como tal, está sujeto a límites según las reglas generales: (i) la autorización no puede importar condonación de dolo futuro, por prohibirlo el artículo 1465 del Código Civil; y, (ii) no puede significar la renuncia de derechos indisponibles (como la vida o la integridad física), en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del mismo Código.

Con todo, la situación es distinta dependiendo de si la víctima renuncia a un derecho o solamente asume un riesgo. En principio, sólo puede hablarse de disposición en el primer caso, y en consecuencia, sólo a éste se aplican los límites ya señalados.

Tratándose de la simple aceptación de un riesgo razonable, el acto debe entenderse autorizado aún cuando se refiera a bienes indisponibles. Así, ocurre respecto de quien realiza vuelos de prueba o participa en experimentos con fármacos (asume el riesgo de un daño probable respecto de bienes no disponibles). Por el contrario, si la probabilidad de daño es muy alta y hace que el riesgo exceda de lo razonable, habrá un verdadero acto de disposición respecto de bienes o derechos irrenunciables, y como tal, la autorización de la víctima no será válida.

Finalmente, para que la aceptación voluntaria del riesgo opere como causal de justificación, es necesario que el autor del daño haya proporcionado a la víctima información suficiente acerca de éste y de sus componentes (intensidad y probabilidad del daño), siendo aplicables íntegramente a este respecto las reglas generales sobre la buena fe contractual.

Cosa distinta es que una vez producido el hecho ilícito la víctima renuncie a la indemnización, la componga directamente con el responsable, transe con él, etc., porque en tales casos no se condona el dolo futuro sino el ya ocurrido, ni se comercia con la personalidad humana, sino con un efecto pecuniario: la indemnización, que es netamente patrimonial.

2.3. El estado de necesidad

El estado de necesidad es aquel en que una persona se ve obligada a ocasionar un daño a otra para evitar uno mayor a sí misma o a un tercero. Un ejemplo jurisprudencial de esta eximente se refiere a un incendio en un puerto, en el cual la autoridad, para evitar su propagación, se vio obligada a echar al mar unos barriles de aguardiente; por considerar que se había actuado para evitar un daño mayor, se negó lugar a la responsabilidad del Estado.

Los requisitos para que opere esta causal son: a) que el peligro que se trata de evitar no tenga su origen en una acción culpable, y b) que no existan medios inocuos o menos dañinos para evitar el daño.

En relación con el segundo de los requisitos, en un caso en que la fuerza pública que custodiaba un puerto, obedeciendo una orden superior, arrojó al mar cajones de cerveza de propiedad de un particular para impedir que cayeran en poder de unos huelguistas, la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que “el deber de la autoridad de mantener ante todo el orden público, no la faculta para adoptar el primer medio que se le presente, ni la exime de la obligación de recurrir entre varios, a los que menos daños ocasionen al derecho de los particulares”.

El estado de necesidad se diferencia del caso fortuito en que si bien hay un hecho imprevisto, él no es irresistible; puede resistirse pero a costa de un daño propio. Al igual que la fuerza mayor, puede presentarse también en la responsabilidad contractual.

Nuestra legislación no contempla para efectos civiles esta institución (lo establece como eximente de responsabilidad penal el N° 7 del art. 10 del Código Penal), por lo que para acogerla debe asimilarse a alguna otra situación reglamentada, como la ausencia de culpa, el caso fortuito, la fuerza mayor, etc.

El estado de necesidad excluye la acción indemnizatoria de la víctima por el daño ocasionado, pero no obsta al ejercicio de la acción restitutoria, pues el Derecho no puede amparar el enriquecimiento injusto de aquel que salva un bien propio con cargo a un patrimonio ajeno. Al respecto señala RODRÍGUEZ: “Nótese que en este caso, la responsabilidad no se extenderá a todos los perjuicios sufridos, sino única y exclusivamente a la compensación de los daños materiales que haga posible restaurar el equilibrio existente entre ambos patrimonios antes de que surgiera el estado de necesidad”.

2.4. La legítima defensa

La legítima defensa opera en derecho civil de modo análogo que en derecho penal. Así, actúa en legítima defensa quien ocasiona un daño obrando en defensa de su persona o derechos, a condición que concurran las siguientes circunstancias: a) que la agresión sea ilegítima, b) que no haya mediado provocación suficiente por parte del agente, c) que la defensa sea proporcionada al ataque, d) que el daño se haya producido a causa de la defensa.

D. LA CULPABILIDAD

1. EXIGENCIA DE CULPABILIDAD.

El hecho no sólo debe ser ilícito, sino también culpable, en el sentido que ha de poderse dirigir un juicio de reproche personal al autor. Este juicio de reprochabilidad puede fundarse en la comisión dolosa (con dolo) o culposa (con culpa).

Según se indicó con anterioridad, el sistema de responsabilidad civil por culpa o negligencia es el régimen común de responsabilidad en el derecho nacional, aplicable a todos aquellos casos que no están regidos por una regla especial diversa.

2. DISTINCIÓN ENTRE DELITO Y CUASIDELITO CIVIL

El que la conducta sea realizada con dolo o con culpa es lo que determina que, en el primer caso, exista un “delito”, y en el segundo un “cuasidelito” (arts. 1437, 2284 y 2314).

Si bien en uno y otro caso el autor del ilícito debe responder en igual medida por el daño causado, es posible observar las siguientes diferencias entre ambos:

- a) Sólo en caso de dolo se autoriza la demanda contra el tercero que, sin ser autor o cómplice del delito, ha recibido provecho del dolo ajeno (arts. 1458 y 2316).
- b) Las cláusulas de irresponsabilidad no proceden respecto del acto cometido por dolo (delito) (art. 1465).
- c) En ciertos ilícitos típicos se exige el dolo, por lo que se descarta la responsabilidad por culpa, como acontece con el consejo malicioso (v.gr. arts. 1768 y 2119).

3. EL DOLO

El artículo 44 del Código Civil define *dolo* como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Definido en el Título Preliminar, el dolo se presenta en varias circunstancias en el Derecho Civil, principalmente como vicio del consentimiento, como agravante de la responsabilidad contractual y como elemento del delito civil, pero siempre, según la teoría unitaria del dolo es uno mismo: la intención del agente de causar daño a otro.

Este es un concepto de dolo extremadamente estricto, y corresponde únicamente al *dolo directo*, referido a los casos en que el autor no sólo ha previsto y aceptado el daño, sino además ha querido que éste ocurra.

La definición legal excluye las hipótesis de *dolo eventual*, donde el autor de la conducta no pretende dañar, aunque se representa la posibilidad del daño como una consecuencia de su acción.

El dolo eventual plantea diversas dificultades de aplicación en materia civil. Ante todo, porque la mera representación y aceptación del daño no son constitutivos de culpa *per se*, sino en la medida que se incurre en contravención con un estándar de cuidado debido (así, el automovilista que conduce representándose y aceptando la posibilidad de dañar a terceros y causa un accidente por un defecto de su automóvil, en principio no es responsable). Además, toda forma de dolo supone indagar en la subjetividad del autor, cuestión que presenta severos problemas probatorios.

BARROS afirma que la distinción entre dolo directo y eventual carece de importancia práctica si se considera que en materia civil la culpa grave se asimila al dolo, según lo dispuesto en el artículo 44 del Código Civil. En efecto, la culpa grave se encuentra en la frontera con el dolo y equivale al extremo descuido, que supone exponer a los demás a aquella clase de riesgos que ni aún las personas negligentes están dispuestos a asumir para sí. En materia civil, un descuido de esta magnitud se

asimila al dolo, es decir, se le atribuyen los mismos efectos que se imponen al autor cuando el motivo determinante de la acción es el resultado dañoso

El dolo se aprecia *in concreto* según las circunstancias del actor, ya que incluye un elemento psicológico: la intención, el deseo de causar el daño, cuya prueba corresponderá siempre al demandante, ya que el dolo no se presume.

4. LA CULPA

4.1. Concepto

Suele definirse la culpa como la omisión de la diligencia a que se estaba jurídicamente obligado, o también como la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios.

Nuestro Código Civil no contiene entre las normas sobre delito y cuasidelito civil una definición especial de la culpa, siendo aplicable a este respecto la definición legal del artículo 44 del mismo código. En dicha norma el legislador optó claramente por seguir la noción romana de culpa, construida en relación con patrones abstractos de conducta (el *hombre de poca prudencia*, el *buen padre de familia* y el *hombre juicioso*), alejándose así del concepto moral, asociado a la idea de reproche personal.

4.2. Apreciación de la culpa

Para apreciar la culpa existen en doctrina dos concepciones que reciben, respectivamente, las denominaciones de culpa objetiva o en abstracto, y de culpa subjetiva o en concreto (la primera designación no es aconsejable, pues puede inducir a error en relación a la responsabilidad objetiva y subjetiva, distinción que se funda en la concurrencia de culpa como requisito de la indemnización).

En la culpa en abstracto, se compara la actitud del agente con la que habría tenido en el caso que ocasiona daño una persona prudente expuesta a la misma situación; o sea, se adopta un tipo ideal y se determina cómo habría éste reaccionado. En la responsabilidad in concreto o subjetiva, se procede, al igual que en el dolo, a determinar la situación personal del sujeto al tiempo del accidente.

La doctrina sostiene casi unánimemente que en nuestra legislación se adopta el primer criterio, y el sujeto ideal de comparación es el buen padre de familia (*bonus pater familias*), según el concepto del art. 44.

Sin embargo, la culpa se determina en concreto, en cuanto se consideran las circunstancias de la acción u omisión. En efecto, la determinación del grado de cuidado que habría empleado el hombre razonable o prudente depende, por una parte, de la situación externa, y por otra, del rol social o calidad del autor (la calidad de experto, por citar un ejemplo). La determinación en concreto no

implica que la culpa devenga subjetiva, porque el rol social o la calidad del autor se consideran abstractamente, habida consideración de las circunstancias. Así, para apreciar si hay o no culpa de parte de un médico al practicar una operación urgente, se comparará su conducta con la de un médico prudente que se hallare en las mismas circunstancias.

4.3. El estándar de cuidado: la culpa leve

Parece razonable que el grado de culpa de la que se responda en materia extracontractual sea culpa leve. Sin embargo, parte de la doctrina nacional siguiendo un antiguo proverbio recogido por la doctrina francesa, ha sostenido que en materia extracontractual se responde de toda culpa, incluida la levísima, pues la clasificación de la culpa en lata, leve y levísima que hace nuestro Código tiene una aplicación estrictamente contractual.

Si bien es cierto que la clasificación de la culpa se efectúa en el Código Civil a propósito de la responsabilidad contractual, ello ocurre sólo porque al tiempo de su redacción la responsabilidad extracontractual había experimentado una escasa evolución.

A ello cabe agregar las referencias del legislador a la culpa o negligencia en el ámbito extracontractual son siempre genéricas, y en consecuencia, se aplica lo dispuesto en el artículo 44.2 del Código Civil, según el cual “*culpa o descuido*, sin otra calificación, significa culpa o descuido *leve*”.

Por otra parte, constituye una contradicción afirmar que la culpa se aprecia en abstracto, aplicando el patrón de cuidado del hombre prudente, y al mismo tiempo señalar que en materia extracontractual se responde incluso de culpa levísima, pues se trata de grados de cuidado asimétricos. No es razonable que se exija al hombre medio emplear en sus actos “aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en sus negocios importantes”.

Sin embargo, a la hora de definir el estándar de cuidado que el sujeto debió observar en el caso concreto, la mayoría de los fallos que acogen la doctrina de la responsabilidad por culpa levísima acuden a la pauta del hombre prudente o buen padre de familia, al momento de determinar la conducta que resultaba exigible atendidas las circunstancias del caso.

Por otra parte, la extensión de la responsabilidad hasta las hipótesis de culpa levísima exige que en cada una de nuestras actividades debamos emplear aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. De esta manera, en nuestro comportamiento cotidiano de relación nos veríamos obligados a actuar según los estándares de cuidado recíproco más exigentes, llevando en la práctica a la responsabilidad por culpa hacia los límites de la responsabilidad estricta.

Pareciera, por el contrario, que la noción de culpa invoca naturalmente la idea de cuidado ordinario, pues atiende a lo que razonablemente podemos esperar de los demás en nuestras relaciones recíprocas. **Culpable es quien actúa defraudando las expectativas que los demás tenemos respecto de su comportamiento**, y dichas expectativas no son otras que aquellas que **corresponden al actuar del hombre simplemente prudente**, y no del especialmente cauteloso.

De ahí que aún quienes sostienen que en materia extracontractual se responde de toda culpa, no puedan eludir referirse al definirla a la *“falta de aquel cuidado o diligencia que el hombre prudente emplea en sus actividades”*, con clara alusión al estándar del buen padre de familia.

Lo anterior no debe inducir al error de creer que el nivel de cuidado exigible sea siempre el mismo, puesto que el **hombre prudente determina su nivel de cuidado considerando las circunstancias que rodean su actuar**. Por eso, la determinación del deber de cuidado es una tarea que atiende necesariamente a las circunstancias en que se desarrolla la actividad y al riesgo que ésta genera. Así, no es igual el nivel de cuidado exigible al médico que atiende espontáneamente a un accidentado en la vía pública, que al médico que efectúa una operación de peritonitis de urgencia en una posta pública de urgencia, y que al médico que realiza una operación programada con dos meses de anticipación.

4.4. Culpa y previsibilidad

La culpa supone la previsibilidad de las consecuencias dañosas del hecho, porque el modelo del hombre prudente nos remite a una persona que delibera bien y actúa razonablemente, y como lo imprevisible no puede ser objeto de deliberación, dentro del ámbito de la prudencia sólo cabe considerar lo previsible.

Es justamente la previsibilidad como condición de la culpa lo que permite distinguir a ésta última del caso fortuito, es decir, del hecho con consecuencias dañosas imprevistas e imposibles de resistir que no pudieron ser objeto de deliberación al momento de actuar y que, por lo tanto, queda fuera de la diligencia exigida.

Nuestra jurisprudencia ha admitido que la previsibilidad es un requisito esencial de la culpa, y más aún, ha definido a ésta última como “una posibilidad de prever lo que no se ha previsto”.

Que la previsibilidad sea un elemento esencial de la culpabilidad, tiene consecuencias en cuanto a los efectos de la responsabilidad por culpa, pues si sólo respecto de los daños previsibles ha podido el autor obrar imprudentemente, sólo estos daños deberán ser objeto de la obligación de indemnizar.

4.5. Culpa infraccional

En este tipo de culpa, los deberes de cuidado son establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad normativa, por medio de una ley, reglamento, ordenanza, etc.

Ejemplos de deberes de cuidado determinados por el legislador encontramos en la Ley N°18.290, Ley del Tránsito (típicamente los límites de velocidad), en las normas sobre seguridad en oleoductos, en las normas sobre control de medicamento y drogas, y en la legislación medioambiental.

Aquí la culpa consiste en haber violado la ley o los reglamentos. El principio básico es que cuando el accidente se produce a consecuencia de la infracción de alguna de estas reglas, el acto es considerado *per se* ilícito. En otros términos, existiendo culpa infraccional el acto es tenido como ilícito sin que sea necesario entrar a otra calificación. Señala ALESSANDRI: “Cuando así ocurre, hay culpa por el solo hecho de que el agente haya ejecutado el acto prohibido o no haya realizado el ordenado por la ley o el reglamento, pues ello significa que omitió las medidas de prudencia o precaución que una u otro estimaron necesarias para evitar un daño”.

Con todo, no basta con la mera infracción de la norma para que pueda atribuirse responsabilidad, pues además se requiere que exista una relación de causalidad directa entre la ilicitud (infracción) y el daño. En otros términos, es necesario que el daño se haya producido a causa de la infracción.

4.6. Culpa por omisión

La culpa puede ser de acción (*in commitendo*), esto es, por obrar no debiendo hacerlo, o por omisión o abstención (*in ommitendo*), esto es, por dejar de actuar.

Lo normal será, sin embargo, que la omisión se produzca en el ejercicio de una actividad, o sea, consiste en no tomar una precaución que debió adoptarse, en no prever lo que debió preverse, como por ejemplo, si un automovilista vira sin señalizar previamente su intención de hacerlo. Esta culpa es lo que algunos llaman negligencia, por oposición a la imprudencia, que sería la culpa por acción.

Todas estas culpas dan lugar a responsabilidad, pero una corriente de opinión sostiene que también la hay en la mera abstención, esto es, cuando el agente no desarrolla ninguna actividad en circunstancias que debió hacerlo. Es el caso de una persona que pudiendo salvar a otra sin riesgo grave para sí misma no lo hace o del médico que sin razón de peso, se niega a atender a un herido, etc.

5. NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO DE CULPABILIDAD

La tendencia inicial de la jurisprudencia nacional fue a considerar el juicio de culpabilidad como una cuestión de hecho. En la actualidad no existe un criterio uniforme en la materia, aún cuando puede observarse una cierta tendencia a calificarlo como una cuestión de derecho, en el que la culpa es tratada como una materia esencialmente de carácter jurídico.

Por su parte, la doctrina nacional se manifiesta en forma unánime por calificar el juicio de culpabilidad como una cuestión normativa, susceptible de ser revisada por la Corte Suprema mediante el recurso de casación en el fondo.

Es indiscutible que precisar los hechos que pueden constituir la culpa, por ejemplo, si hubo choque o no, si existía disco "Pare", la velocidad del conductor, etc., corresponde a los jueces del fondo, salvo que los hayan dado por establecidos con infracción de las leyes reguladoras de la prueba. Pero calificarlos, esto es, si ellos constituyen dolo, culpa, caso fortuito, es cuestión de derecho y susceptible de revisión por la casación en el fondo, puesto que se trata de conceptos establecidos en la ley. El dolo y la culpa son conceptos legales, definidos por la ley; se trata de determinar la fisonomía jurídica de los hechos establecidos por los jueces del fondo para hacerlos calzar con los conceptos de culpa o dolo.

6. PRUEBA DE LA CULPABILIDAD

La culpabilidad, en sus dos modalidades (dolosa y culposa), debe ser probada por quien la alega, en cuanto incumbe probar las obligaciones (en este caso la de indemnizar) a quien alega su existencia (art. 1698).

La víctima que cobra indemnización sostiene que ha existido de parte del demandado un acto u omisión doloso o culpable que le causa daño, por lo cual está obligado a la reparación, o sea, afirma la existencia de una obligación, para lo cual deberá acreditar que concurren los requisitos legales para que ella tenga lugar, sus elementos constitutivos, uno de los cuales es la culpa o el dolo.

La prueba no tiene restricciones, como que se trata de probar hechos, y puede recurrirse a las presunciones, testigos, confesión, peritajes, etc., sin limitación alguna. No se consideran las normas que limitan la prueba testimonial, en cuanto los arts. 1707 y siguientes se aplican a los "actos y contratos".

7. PRESUNCIONES DE CULPA

7.1. Consideraciones generales

El principio general en virtud del cual la culpa debe ser probada por quien la alega, pone con frecuencia a la víctima en una importante desventaja estratégica frente al autor del daño.

Por lo general, el demandante carecerá de los instrumentos probatorios para demostrar que el autor del daño no empleó la diligencia debida, y en los casos más complejos, difícilmente estará en condiciones de probar cual era el deber de cuidado que correspondía observar. En consideración a estas dificultades, el sistema de responsabilidad contempla presunciones de culpabilidad, cuyo efecto es invertir el peso de la prueba en favor de la víctima.

De este modo, sin alterar la naturaleza de la responsabilidad, fundada en la negligencia o dolo, se modifica la posición estratégica de las partes frente a la prueba, correspondiendo al demandante probar el hecho, el daño y la relación causal, y al demandado su diligencia, o la concurrencia de fuerza mayor o de alguna causal de justificación.

El Código Civil establece presunciones de culpabilidad referidas al hecho propio (artículo 2329), las que se refieren al hecho de las cosas (artículos 2323, 2324, 2326, 2327 y 2328) y las que se refieren al hecho ajeno (artículos 2320 y 2322).

A continuación se analizará la presunción de culpabilidad por el hecho propio; en capítulos posteriores se estudiarán las presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno y el hecho de las cosas.

7.2. Presunción de culpabilidad por el hecho propio del art. 2329

La presunción general de culpabilidad por el hecho propio ha sido estructurada en el derecho nacional a partir de la norma del artículo 2329 del Código Civil.

Inicialmente, la doctrina y cierta jurisprudencia consideraron que el artículo 2329 del Código Civil no era sino una repetición de la norma del artículo 2314, cuya única peculiaridad consistía en citar algunos ejemplos o casos de aplicación del principio general de responsabilidad por culpa.

La primera explicación del art. 2329 bajo una hipótesis de presunción de culpa fue formulada por DUCCI, afirmando que la norma establecía una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de actividades caracterizadas por su peligrosidad. Luego, ALESSANDRI extendió el ámbito de la presunción señalando que el art. 2329 establece “una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de un hecho que, por su naturaleza o

por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a culpa o dolo del agente”. Según esta tesis, un hecho que por su naturaleza se presume culpable es, por ejemplo, un choque de trenes, pues “los trenes deben movilizarse en condiciones de no chocar”.

Los más diversos tipos de argumentos han sido planteados para justificar la doctrina de que el artículo 2329 es fundamento para dar por establecida la presunción de culpabilidad por el hecho propio de quien causa el daño:

(a) Desde un punto de vista exegético, son ilustrativos de la intención del legislador (i) la ubicación del artículo 2329, inmediatamente después de las normas que establecen presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno (artículos 2320 y 2322) y por el hecho de las cosas (artículos 2323 a 2328), y (ii) el enunciado inicial de la norma, “*por regla general todo daño...*”. En verdad, todo parece indicar que el legislador quiso establecer una regla de clausura del sistema de presunciones que contempla el Código Civil. Según ALESSANDRI, de esta forma se quiso dictar una regla que comprendiere los demás casos análogos que pudiesen haberse omitido. La norma sigue la lógica interna de este sistema de presunciones, agregando algunos hechos que eran de usual ocurrencia a la época de su redacción.

Esta es, por lo demás, la única forma de dar sentido y utilidad a la disposición, pues de lo contrario habría que aceptar que se trata de una innecesaria repetición de la regla del artículo 2314 del Código Civil.

(b) También existen razones de texto que avalan esta interpretación. La norma no se refiere a todo daño *causado por o proveniente de* malicia o negligencia, sino a “todo daño que *pueda imputarse a* malicia o negligencia de otra persona”. Este concepto, ilustrado por los ejemplos del inciso segundo, se refiere a una conducta que por sí misma tiende naturalmente a ser negligente, aún antes de prueba alguna. Es una referencia a un actuar que *pueda ser* calificado como descuidado y no a algo que *es*. El artículo 2329 no exige que se haya acreditado que el daño proviene de dolo o culpa para imponer la obligación de repararlo, sino que obliga al autor a indemnizar cuando es razonable suponerlo, dando a entender que mientras no se establezca lo contrario, pesa sobre el autor del daño la obligación de indemnizar. Un daño que de acuerdo a la experiencia pueda estimarse como debido a negligencia hace presumir la culpabilidad, correspondiendo al inculpaado descargarse probando su propia diligencia.

Los ejemplos del artículo 2329 también contribuyen en favor de esta interpretación, pues todos se refieren a hechos que por sí solos son expresivos de culpa. Así, en el caso del disparo imprudente de un arma de fuego, la circunstancia que permite inferir la culpabilidad es el peligro implícito en disparar un arma. En la remoción de las losas de una acequia o cañería en una calle o camino sin las precauciones necesarias, y la mantención en mal estado de un puente o acueducto que atraviesa un camino, se está frente a manifiestas omisiones en la acción que justifican la presunción de culpa.

(c) Esta interpretación resulta coincidente también con la experiencia y la razón. Se atribuye en principio responsabilidad a otro, cuando el sentido común y la experiencia indican que el daño provocado en tales circunstancias usualmente se debe a culpa o dolo del que lo causa. Es lo que en el derecho anglosajón se conoce con la expresión latina *res ipsa loquitur* (“dejad que las cosas hablen por sí mismas”).

(d) Desde el punto de vista de la justicia correctiva, la presunción de culpa por el hecho propio se justifica porque resulta a menudo el único camino para poder construir en la práctica la responsabilidad del autor del daño. La presunción es de especial relevancia en caso de accidentes que se deben a algún error en un complejo proceso industrial o de servicios, sin que sea posible determinar, sin embargo, el acto u omisión concretos que lo provocaron. Es el caso, por ejemplo, de los productos defectuosos (fármacos, alimentos), a falta de una legislación que establezca, como en otros ordenamientos, una regla de responsabilidad estricta.

La jurisprudencia coincide en señalar que la enumeración del artículo 2329 no tiene carácter exhaustivo, y ha considerado otros hechos como reveladores de negligencia, tales

como los derrumbes que durante la demolición de un edificio causan daños a terceros, la muerte de un transeúnte causada por una línea eléctrica extendida en condiciones peligrosas, la existencia de un pozo descubierto sin señales de prevención, el volcamiento de un carro de ferrocarril por mal estado de la vía férrea.

7.3. Condiciones de aplicación de la presunción

La presunción de responsabilidad por el hecho propio del artículo 2329 del Código Civil reconoce al menos tres grupos de casos de aplicación:

(i) *Peligrosidad de la acción*: La peligrosidad de la acción es un elemento relevante para aplicar la presunción de responsabilidad en caso de accidente, pues quien actúa en ámbitos riesgosos, sea por la probabilidad o la intensidad del daño, está obligado a adoptar todos los resguardos para evitar que ocurra un accidente; así se explica la temprana jurisprudencia que dio por establecida la culpa por el sólo hecho de ocurrir un choque de trenes.

(ii) *Control de los hechos*: Tratándose de daños ocasionados por quien está en condiciones de controlar todos los aspectos de su actividad, como ocurre con las personas está a cargo de procesos productivos complejos, quien está en mejor posición relativa para procurarse medios de prueba es precisamente el autor del daño. Para el lego, e incluso a veces para el experto, no resulta sencillo determinar dónde residió el error de conducta que hizo posible el accidente. Mientras no se demuestre que fue debido a un hecho por el cual no responde el fabricante o el prestador del servicio, la culpa puede ser presumida.

Por otra parte, poner la prueba de la culpa de cargo de la víctima, importaría en estos casos, transformar la responsabilidad en una cuestión puramente teórica, justificándose aquí la aplicación de la presunción por razones de justicia correctiva.

(iii) *El rol de la experiencia*: Finalmente, existe una buena razón para aplicar la presunción cuando, conforme a la experiencia, cierto tipo de accidentes se deben más frecuentemente a negligencia que a un caso fortuito.

En otras palabras, si probada la relación causal entre el hecho y el daño, éste último resulta razonablemente atribuible a culpa del autor, debe aplicarse la presunción de responsabilidad por el hecho propio del artículo 2329 del Código Civil.

E. EL DAÑO

1. CONCEPTO

Para que exista responsabilidad es indispensable que el hecho ilícito haya causado un daño (arts. 1437 y 2314). En consecuencia, es posible que concurren los demás requisitos e incluso que exista responsabilidad penal, pero si no hay daño no habrá delito o cuasidelito civil. De ahí que el delito frustrado no provoque responsabilidad civil.

De este modo, el daño es una condición de la pretensión indemnizatoria, de modo que ésta sólo nace una vez que el daño se ha manifestado. Así, se ha fallado que “tratándose de un cuasidelito civil, para que nazca el derecho es necesario que concorra el daño y si este elemento falta, no ha nacido el derecho para demandar perjuicios”. No obstante, en ciertos supuestos se permite que la responsabilidad civil actúe por anticipado antes de que el daño inminente se produzca y para que se adopten las medidas necesarias para evitarlo (arts. 2333, en cuanto se refiere al “daño contingente”).

En nuestra legislación los términos “daño” y “perjuicio” son términos sinónimos y se usan indistintamente, mientras que en otras legislaciones se reserva la primera expresión para el daño emergente y la segunda para el lucro cesante. En Francia se habla también de daños e intereses para efectuar el mismo distingo.

El concepto más difundido de daño o perjuicio es el que lo considera como todo detrimento o menoscabo que sufra una persona en su patrimonio o en su persona física o moral. La jurisprudencia ha resuelto en el mismo sentido que “Es todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial” (R.D.J., T. 70, sec. 4ª, p. 68).

2. REQUISITOS DE RESARCIBILIDAD DEL DAÑO

La doctrina y jurisprudencia han ido delimitando las diversas condiciones que deben cumplirse para que el daño tenga relevancia jurídica y pueda ser fundamento de un resarcimiento a título de responsabilidad civil, señalándose a al efecto los siguientes requisitos:

2.1. El daño debe lesionar un derecho o un interés legítimo

Existe amplio consenso en torno a que el daño será resarcible en cuanto lesione un *derecho subjetivo*.

Tal concepción se ha ampliado, en cuanto no sólo hay lugar a la indemnización cuando se vulnera un derecho, sino también un *interés* en la satisfacción de necesidades o bienes

humanos de carácter privado. Así se aceptó en el siguiente caso: el padre ilegítimo, si no es llamado por testamento (que no lo era en el caso), no es heredero ni tiene derecho a alimentos del hijo ilegítimo; este último falleció atropellado por un tren, pero como vivía a expensas del hijo, el padre demandó la indemnización y le fue otorgada.

Con todo, no todo daño a un interés es resarcible, sino que se debe tratar de un interés *legítimo*, esto es, que de alguna manera se encuentre tutelado por el derecho. En razón de ello es que cierta doctrina rechaza, por ejemplo, que los concubinos puedan cobrar indemnización por los daños personales que les produzca el fallecimiento de su conviviente a causa de un hecho ilícito.

2.2. El daño debe ser cierto

Que el daño sea cierto, quiere significar que debe ser real, efectivo, tener existencia. En consecuencia, se rechaza la indemnización del daño eventual, meramente hipotético, que no se sabe si existirá o no.

No quiere decir que se exija que el daño sea actual. Es indemnizable el daño futuro, pero sólo en la medida en que, al momento en que se dicta la sentencia, haya certeza de que necesariamente sobrevendrá. En este caso la certidumbre del daño debe ser actual, pero el perjuicio puede ser futuro.

Asimismo se admite también la responsabilidad sobre un daño contingente, que aún no ha ocurrido pero que puede producirse de no adoptarse medidas preventivas. En tal caso la certidumbre deberá recaer sobre la inminencia o amenaza de producirse el daño.

- **La pérdida de oportunidad o de una chance**

En relación a la materia, desde hace un tiempo la doctrina y jurisprudencia nacional han aceptado la resarcibilidad de lo que se denomina **pérdida de una chance** o **pérdida de oportunidad**, que se refiere a los casos en que el demandante pide indemnización porque la conducta culpable del demandado le impidió aprovechar una oportunidad o ejercer un derecho del cual con mayor o menor probabilidad, pero no con certeza, obtendría un beneficio. Son típicos los casos de negligencia profesional del abogado por la cual el cliente no pudo ejercer una acción y por lo tanto pierde la oportunidad de ganar el pleito; como no hay forma de determinar si el tribunal superior habría acogido el recurso, el daño es en cierta forma hipotético.

La pérdida de una oportunidad o una chance constituye un daño indemnizable, que se produce en casos que se hace imposible determinar si la víctima de un comportamiento antijurídico habría o no obtenido una ganancia o evitado una pérdida, atendido que el referido comportamiento antijurídico ha interferido en el curso normal de los acontecimientos. En la doctrina nacional, TAPIA señala que en las hipótesis de pérdida de

una oportunidad o una chance “existe para la víctima un bien aleatorio que se encontraba en juego (ganar el proceso, cerrar el negocio, recobrar la salud, evitar la muerte, obtener un premio, acceder a una profesión, etcétera) y el agente destruyó ese potencial de oportunidades con su acción u omisión negligente (olvidó apelar, descuidó certificar un documento, omitió un examen médico, accidentó al caballo, lesionó al postulante, etcétera)”, agregándose que como “sólo existe certeza –y relación de causalidad– respecto de la pérdida de oportunidades generada, la indemnización se reduce a una estimación del valor de esa chance desaparecida. Usualmente, se expresa ese valor en un porcentaje de oportunidades perdidas, que se multiplicará por el valor total del bien en juego.” En un sentido similar, RÍOS y SILVA definen la pérdida de una oportunidad como la “frustración actual de una probabilidad de alcanzar una situación patrimonial o extrapatrimonial más beneficiosa, o de evitar un empeoramiento de la situación patrimonial o extrapatrimonial presente”.

En la actualidad, la jurisprudencia nacional admite la indemnización de la pérdida de chance.

En efecto, la Corte Suprema ha resuelto lo siguiente sobre la materia: “9°.- Que entre nosotros se ha sostenido que: “La pérdida de una chance se encuentra entre estas últimas hipótesis (cuando no se sabe lo que habría ocurrido en el futuro de no haberse cometido el hecho ilícito), esto es, incide en la frustración de una expectativa de obtener una ganancia o de evitar una pérdida. Pero, a diferencia del daño eventual, en los casos de pérdida de una oportunidad puede concluirse que efectivamente la víctima tenía oportunidades serias de obtener el beneficio esperado o de evitar el perjuicio, tal como ya se ha mencionado”, destacando enseguida que se trata del caso de “una víctima que tenía oportunidades de obtener un bien ‘aleatorio’ que estaba en juego (ganar un proceso, recobrar la salud, cerrar un negocio, acceder a una profesión, etcétera) y el agente, al cometer el hecho ilícito, destruyó ese potencial de oportunidades (olvidó apelar, no efectuó un examen, omitió certificar un documento, lesionó al postulante, etcétera). La víctima en todos estos casos se encontraba inmersa en un proceso que podía arrojarle un beneficio o evitarle una pérdida (tratamiento médico, apelación de una sentencia, preparación de un examen, etcétera), y el agente destruyó por completo con su negligencia las chances que la víctima tenía para lograr tal ventaja” (Mauricio Tapia Rodríguez, “Pérdida de una chance: “un perjuicio indemnizable en Chile”, en “Estudios de Derecho Civil VII”. Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Viña del Mar, 2011. Fabián Elorriaga de Bonis (Coordinador). Legal Publishing Chile, pág. 650).

10°.- Que en este sentido se ha sostenido también que: “Las chances por las chances no se indemnizan. Estas deben representar para el demandado la posibilidad de estar mejor. No es la privación de una chance en sí lo que la hace indemnizable, sino la concatenación de ésta a un resultado eventualmente más beneficioso para la víctima. Lo que se sanciona con la pérdida de chance no es el hecho de que la víctima no haya podido optar, elegir, escoger, decidir (un análisis como ese sería incompleto); antes bien, la pérdida de la chance se hace indemnizable sólo cuando las chances representan para la víctima de su privación una probabilidad de quedar en mejores condiciones, sea porque se podría obtener algo mejor o mayor, sea porque se suprime un riesgo existente [...] En pocas palabras, no es el derecho a optar lo que se indemniza, sino el derecho a optar por algo mejor” (Ignacio Ríos Erazo y Rodrigo Silva Goñi. “Responsabilidad Civil por pérdida de la oportunidad”. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2014, pág. 267).”

2.3. Debe existir una relación directa con el hecho ilícito

La relación entre el daño indemnizable y la actuación que genera responsabilidad debe ser directa, sin intermediarios. La doctrina ha expresado que el daño es directo cuando “es una consecuencia *cierta y necesaria* del hecho ilícito”.

Los daños secundarios o indirectos no pueden ser indemnizados, por cuanto fallará la relación de causalidad, que es un elemento indispensable para configurar la responsabilidad civil. Así, se sigue una regla similar a la consagrada en el artículo 1558 respecto de la responsabilidad contractual.

2.4. El daño no debe estar indemnizado

En principio no puede exigirse la indemnización de un perjuicio ya reparado. Y así hay casos en que la víctima tiene acción en contra de varias personas para demandar los daños; por ejemplo, si los autores del hecho ilícito son varios, por ser solidaria la acción (art. 2317), la víctima puede cobrar el total a cualquiera de ellos, pero indemnizada por el demandado no podrá volver a cobrar los daños a otro.

Igualmente en la responsabilidad por el hecho ajeno, como en el caso del padre por sus hijos menores, la víctima puede demandar al hechor o a aquél, pero no puede exigir a ambos que cada uno pague el total de la indemnización.

Se presenta en este punto el problema del llamado *cúmulo de indemnizaciones*, esto es, que la víctima haya obtenido de un tercero ajeno al hecho ilícito una reparación total o parcial del daño sufrido. Este tercero podrá ser una compañía aseguradora o un organismo de la Seguridad Social, etc. La solución más aceptada es que si tales beneficios tienden a reparar el daño, éste se extingue, ya no existe, y no puede exigirse nuevamente su reparación. En todo caso, en esta situación la compañía de seguros se subroga en los derechos de la víctima a efectos de repetir en contra del hechor.

2.5. El daño debe ser de una magnitud suficiente

La magnitud o significancia del daño puede ser tomada en cuenta también para calificar sobre la justicia y conveniencia de su reparación. Si bien el Código Civil señala que “todo” daño debe ser indemnizado, lo cierto es que si las personas reclamaran por todos los daños que sufren en su diario vivir el sistema judicial colapsaría. En consecuencia, la noción de daño excluye aquellas incomodidades o molestias que las personas se causan recíprocamente como consecuencia normal de la vida en común (por ejemplo en las relaciones de vecindad).

2.6. El daño debe ser previsible

En este punto existe una importante discusión doctrinal. Para efectos de análisis, cabe recordar que el artículo 1558 del Código Civil dispone que los daños directos pueden ser previstos e imprevistos, clasificación más propia de los contratos, pues sólo se responde por regla general de los previstos al tiempo de su celebración, y de los imprevistos únicamente en caso de dolo o culpa grave.

La doctrina tradicional afirma que en responsabilidad extracontractual deben indemnizarse los perjuicios previstos e imprevistos, ya que el art. 2329 dispone la reparación de “todo daño”. Sobre la materia, ALESSANDRI señala: “Sea que se trate de un delito o de un cuasidelito, la reparación comprende tanto los perjuicios previstos como los imprevistos que sean su consecuencia necesaria y directa. El art. 1558 es inaplicable en materia delictual o cuasidelictual; se refiere a las obligaciones contractuales. Sólo en ellas las partes han podido prever los daños que su incumplimiento podría irrogar. Tratándose de un hecho ilícito, esta previsión no es posible: en materia delictual y cuasidelictual el daño es por su naturaleza imprevisto”.

De contrario se sostienen que la previsibilidad es esencial para que pueda haber un factor de conexión de causalidad, y asimismo constituye un elemento de la culpabilidad. En particular, BARROS sostiene que “La culpa supone la previsibilidad de las consecuencias dañosas del hecho, porque el modelo del hombre prudente nos remite a una persona que delibera bien y actúa razonablemente, y como lo imprevisible no puede ser objeto de deliberación, dentro del ámbito de la prudencia sólo cabe considerar lo previsible... Que la previsibilidad sea un elemento esencial de la culpabilidad, tiene consecuencias en cuanto a los efectos de la responsabilidad por culpa, pues si sólo respecto de los daños previsibles ha podido el autor obrar imprudentemente, sólo estos daños deberán ser objeto de la obligación de indemnizar”.

2.7. El daño debe haber sido personalmente sufrido por la víctima

La exigencia de que los daños estén radicados en el actor excluye la indemnización por *daños difusos*, es decir, daños que afecten a personas indeterminadas.

Ello plantea el problema del denominado “daño por repercusión o rebote”, que es el que sufre una persona a consecuencia del hecho ilícito experimentado por otra.

El principal problema del daño por repercusión o rebote estriba en determinar quiénes son las personas que están verdaderamente legitimadas para pretender ser indemnizadas por parte del causante de los daños, puesto que la cadena de perjudicados a consecuencia de un hecho dañoso podría llegar a ser verdaderamente insospechada.

BARROS indica que todo aquel que a consecuencia del accidente se ve privado de los ingresos que le proporcionaba la víctima, a título de alimentos e incluso sin tener derecho a ellos, como en algunos casos ha declarado la jurisprudencia nacional, sufre un daño patrimonial de carácter personal, en razón de lucro cesante, y tiene una acción directa en contra del autor del daño.

También es un daño personal el que consiste en el dolor por la pérdida de un ser querido (una de las manifestaciones del daño moral). Con todo, tratándose del daño moral el derecho tiende a exigir que entre la víctima mediata y la persona fallecida exista un grado de parentesco que justifique la indemnización, lo que usualmente ocurre con el cónyuge, los ascendientes y los descendientes.

3. CLASES DE DAÑOS

En definitiva, atendiendo a la naturaleza del bien lesionado, los daños reparables han sido clasificados tradicionalmente en dos grandes categorías: (a) Daños materiales o patrimoniales, y (b) Daños morales o extrapatrimoniales. Asimismo cabe referirse a las subcategorías de uno y otro, como a otras clases de daños consideradas por la ley y la doctrina.

3.1. Daño material o patrimonial

Daño patrimonial o material es el que consiste en una pérdida pecuniaria, en un detrimento del patrimonio. Se manifiesta en la diferencia entre el estado y posición económica de la víctima después de ocurrido el accidente, y la situación en que hipotéticamente se encontraría en caso de que éste no hubiere ocurrido.

El daño material puede ser de dos clases: (i) daño emergente, y (ii) lucro cesante. No dice el Código expresamente en el Título XXXV que ambos son indemnizables, como lo hace el art. 1556 en materia contractual, pero tanto la doctrina, como la jurisprudencia en forma unánime igual lo entienden así, dada la amplitud de los preceptos que establecen la indemnización delictual. En efecto, el art. 2314 al contemplar la obligación del autor del hecho ilícito a la indemnización, habla de “daño” sin distinguir, y el art. 2329 por su parte dispone que “todo daño” imputable a una persona obliga a ésta a la reparación. Finalmente el art. 2331 menciona expresamente para un caso especial -injurias- ambas clases de daños.

(i) El daño emergente

Daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio de una persona. A consecuencias del daño emergente el activo del patrimonio pesa menos. El daño emergente puede consistir en la destrucción o el deterioro de cosas que poseen valor

económico, en los costos en que ha de incurrir la víctima a causa del accidente, o bien, en un perjuicio puramente económico.

Tratándose de la destrucción de una cosa, la indemnización corresponderá a su valor de reposición, según el estado en que se encontraba antes del hecho. Si la cosa sufre deterioro, la indemnización debe consistir en la suma que es necesario gastar para su completa reparación, y la víctima tiene derecho a ser compensada además por el menor valor que tenga la cosa después de reparada. Habrá casos en que la reparación resulte más costosa que la cosa misma (ciertos automóviles, por ejemplo); en tal evento, el restablecimiento al estado patrimonial inmediatamente anterior al accidente se logrará pagando a la víctima el precio de la cosa.

También constituyen daño emergente los gastos en que debe incurrir la víctima a causa del accidente, por concepto de hospitalización, honorarios médicos, medicamentos, arriendo de un vehículo que reemplace al dañado mientras dura la reparación y otros semejantes.

Los daños económicos o puramente patrimoniales, en tanto, son aquellos que no se traducen en detrimento de cosas determinadas, pero que, sin embargo, afectan al patrimonio. Tal es el daño que sufre el comerciante que es víctima de competencia desleal, si su negocio pierde valor a consecuencia de publicidad engañosa.

(ii) El lucro cesante

Puede definirse como la pérdida del incremento neto que habría tenido el patrimonio de la víctima de no haber ocurrido el hecho por el cual un tercero es responsable.

Refiriéndose a la materia, la jurisprudencia nacional ha afirmado que “la característica de esta clase de daño se produce por lo que el actor deja de percibir como consecuencia del hecho ilícito”. Se ha fallado que el lucro cesante “lo constituyen los intereses del capital en que se avalúa o estima el monto real y efectivo del perjuicio causado”.

También es lucro cesante la pérdida de oportunidades de uso y goce de la cosa dañada, aún cuando ésta pérdida no se traduzca en perjuicio económico presente, como el que experimenta la víctima que se ve obligada a dejar de usar su automóvil, deteriorado a consecuencia de un accidente. Por el contrario, el mismo daño será calificado de daño emergente si la víctima se ha procurado un automóvil arrendado.

La determinación del lucro cesante considera un grado razonable de probabilidad en la percepción de los ingresos futuros, y obedece a una proyección del curso normal de los acontecimientos, atendidas las circunstancias particulares de la víctima.

Existen casos en que esa probabilidad es cercana a la certeza, como ocurre en general con el dinero. En ese evento, el lucro cesante será igual al interés que la víctima habría ganado

de no mediar el hecho. Pero, en general, la probabilidad de ganancia será más incierta, y de ahí que la jurisprudencia haya concluido que “para avaluar el lucro cesante, deben proporcionarse antecedentes más o menos ciertos que permitan determinar una ganancia probable que dejó de percibirse a consecuencia del delito o cuasi-delito”. La certidumbre del daño, que la doctrina suele señalar como condición de su reparabilidad, debe ser calificada en el caso del lucro cesante, pues rara vez habrá certeza de que el provecho se habría efectivamente producido. El cálculo del lucro cesante exige, en consecuencia, aplicar un cálculo probabilístico de su efectiva ocurrencia.

3.2. Daño moral o extrapatrimonial

(i) Concepto

El daño moral ha sido objeto de reparación sólo en el último siglo. El Código Civil no contiene una definición de daño moral.

El daño moral tradicionalmente ha sido definido como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. De ahí entonces que la indemnización del daño moral se identifique en general con la expresión latina *pretium doloris* o “precio del dolor”.

Con todo, la noción de daño moral entendido como el dolor (en un sentido amplio) o las molestias ocasionadas en la sensibilidad física del individuo, no está exenta de críticas, entre otras razones, porque excluiría las demás manifestaciones de esta especie de daño, como los perjuicios estéticos o la alteración de las condiciones de vida, de amplio reconocimiento en el derecho comparado.

Así se explica que, siguiendo una definición restrictiva del concepto general de daño, cierta jurisprudencia haya definido el daño moral como aquél que lesiona un *derecho extrapatrimonial* de la víctima. Así, se ha fallado que “se entiende el daño moral como la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a otro hombre”. Sin embargo, en nuestra tradición jurídica el daño no se restringe a la lesión de un derecho, sino de un legítimo interés. Por eso, se puede definir el daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los *intereses extrapatrimoniales* de la víctima, de esta forma es posible comprender en la reparación todas las categorías o especies de perjuicios morales (y no sólo el *pretium doloris*).

Por ello, resulta más fácil definir el daño moral en términos negativos, como todo menoscabo no susceptible de evaluación pecuniaria, esto es, como sinónimo de daño no patrimonial.

En lo que toca al concepto del daño moral, recientemente la Corte Suprema ha señalado que “la jurisprudencia reiterada de esta corte de casación expresa que el daño moral es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, por lo tanto, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.” (Sentencia de fecha 7 de agosto de 2007, recurso de casación en el fondo Rol N° 2821-2007, considerando 14°).

(ii) Resarcibilidad del daño moral

Hace décadas la procedencia de la indemnización del daño moral fue resistida porque se decía que la indemnización tiene por objeto hacer desaparecer el daño y el moral es imposible dejarlo sin efecto; que la indemnización es muy difícil de establecer, y que puede llegarse a abrir al aceptarla una avalancha de demandas por este capítulo de las personas amigas, familiares, etc., de la víctima, todas ellas alegando su aflicción.

Sin embargo, hoy en la doctrina y jurisprudencia unánime acepta la indemnización del daño moral, entre otras, por las siguientes razones:

- a) No necesariamente toda indemnización es de carácter resarcitoria, en cuanto también es posible una reparación en especie, como la publicación de la sentencia, en caso de ofensas al honor o crédito, etc.
- b) La dificultad de fijar la indemnización y los posibles abusos no pueden servir de pretexto para negar la compensación, pues también se presentan en los daños materiales.
- c) Las disposiciones que establecen la indemnización de perjuicios en materia extracontractual (arts. 2314 y 2329) son amplias y no distinguen, y ordenan indemnizar todo perjuicio;
- d) La legislación posterior al Código Civil es confirmatoria en tal sentido, pues menciona expresamente el daño moral entre los indemnizables: art. 19, N° 7, letra i de la Constitución Política; art. 69 de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo; art. 40 inc. 2° de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, sucesora de la Ley de Abusos de Publicidad; art. 3 letra e) de la Ley N° 19.496 sobre protección de los consumidores.
- e) Finalmente, cabe observar que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia tradicional entendían que en el art. 2331 el legislador negó expresamente la indemnización del daño moral; agregándose que si lo dijo expresamente en esta situación el legislador,

quiere decir que en los demás se indemniza el daño moral, pues si no el precepto estaría de más.

Ahora bien, esta interpretación del art. 2331 ha tenido una variación en la jurisprudencia. Como se ha indicado, tradicionalmente la doctrina y jurisprudencia nacional ha entendido que esta norma dispondría que si las imputaciones injuriosas no traen un menoscabo patrimonial, no podría reclamarse una indemnización en dinero, aunque la víctima haya sufrido grandes pesares a causa de dichos ataques a su honor o su crédito.

Atendido tal entendimiento del art. 2331, es que en juicios de responsabilidad extracontractual en los que se reclamó la indemnización de daño moral por imputaciones injuriosas, el demandante deducía recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a efectos de que la disposición no fuese aplicada al caso. El art. 2331 fue declarado inaplicable por inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 10 de junio de 2008, en la que resolvió que “el efecto natural de la aplicación del precepto legal impugnado en estos autos -artículo 2331 del Código Civil- es, precisamente, privar a los atentados contra el derecho a la honra que no constituyan delitos específicos, de la protección de la ley, pues, mientras las lesiones a otros derechos igualmente no constitutivas de delitos dan lugar a indemnización por todos los daños patrimoniales y morales causados, de acuerdo a la regla general del artículo 2.329 del Código Civil, las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a la indemnización del daño moral, que es naturalmente el producido por esta clase de atentados y, ordinariamente, el único”; lo cual era inconstitucional, entre otros motivos, porque el art. 19 N° 26 de la Constitución prohíbe que una ley (como el Código Civil) pueda limitar un derecho constitucional, como el establecido en el art. 19 N° 4 de la Carta Fundamental (derecho a la honra). El mismo razonamiento se encuentra en otras sentencias del Tribunal Constitucional.

Cabe agregar que mediante sentencia de 7 de junio de 2021 (Rol N° 6296-2019) tuvo lugar un giro jurisprudencial relativo a la interpretación del art. 2331, en el sentido de que la norma no restringía la indemnización de daño moral por imputaciones injuriosas. Al efecto, y muy en síntesis, la Corte Suprema tuvo en consideración (a) el principio de reparación integral del daño; (b) la norma no excluye expresamente el daño moral, solo no lo menciona, lo que resulta entendible pues a la época de la dictación del Código Civil no se contemplaba tal rubro indemnizatorio (como lo demuestra el art. 1556, que solo se refiere al daño emergente y al lucro cesante), siendo la materia desarrollada con posterioridad por la jurisprudencia; (c) razonar de un modo diverso infringiría las garantías constitucionales del derecho a la vida e integrada física y psíquica (art. 19 N° 1) y al respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de las personas y su familia (art. 19 N° 4). Un razonamiento e interpretación tradicional se encuentra en la sentencia dictada por la Corte Suprema con fecha 10 de agosto de 2021 (Rol N° 22.901-2019).

La Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, de 4 de junio de 2001, (sucesora de la Ley N° 16.643 sobre Abusos de Publicidad), establece penas corporales severas para los delitos de calumnia e injuria cometidos por cualquier medio de comunicación social (artículo 29), y además declara que en tal caso habrá derecho a la indemnización del daño emergente, lucro cesante y daño moral (art. 40 inc. 2º).

(iii) Categorías de daño moral

Siguiendo a CORRAL el daño moral, entendido en su sentido amplio como todo daño extrapatrimonial que sufre la persona, ha dado lugar a una tipología bastante abierta de categorías, no del todo delineadas y aceptadas, entre las que caben destacar las siguientes:

a) *El daño emocional*

Éste es el concepto original del daño moral, el clásico “*pretium doloris*”. La indemnización intenta paliar o compensar hasta donde sea posible el sufrimiento psíquico que el hecho ilícito ha producido a la víctima.

b) *La lesión de un bien o derecho de la personalidad*

Con independencia del dolor psíquico que ha producido a la víctima, habrá daño moral si se lesiona en forma directa o ilegítima un derecho de la personalidad, como la honra, la intimidad, la imagen, el derecho de autor. En este sentido, se hace posible que las personas jurídicas, que no pueden sentir o sufrir, sean no obstante dañadas moralmente, si se lesionan algunos de sus derechos propios de naturaleza extrapatrimonial (buen nombre, reputación, imagen, etc.).

c) *El “préjudice d’agrément”*

En la doctrina y jurisprudencia francesa el perjuicio del gusto de vivir (lo que en la experiencia inglesa se denomina *loss of amenities of life*), es uno de los más importantes rubros de las indemnizaciones de daño moral. Se suele definir como “la privación de las satisfacciones de orden social, mundano y deportivo de las cuales se beneficia un hombre de la edad y de la cultura de la víctima”. Por cierto hay nociones restringidas y otras más abiertas de este perjuicio, pero en general se señala que debe contabilizarse el daño físico que produce incapacidad permanente o temporal, y que la indemnización debe aumentarse si se prueba que la víctima presenta un daño superior al medio por haber cultivado con éxito alguna capacidad creativa, un talento particular, un *hobby*, etc.

d) *El daño corporal o fisiológico*

El daño es corporal cuando afecta la integridad física y psíquica de una persona natural, y se distingue del daño puramente moral en que no recae como éste en la pura esfera emotiva o espiritual: “cuando los daños afectan al cuerpo, es decir, a la integridad física de la persona, tanto desde el punto de vista externo como interno, los conocemos como daños corporales, entre los que se encuentran también las lesiones a la integridad psíquica, cuando médicamente sea posible identificarlas, como por ejemplo los supuestos de *shock* nervioso o de depresiones”. El daño corporal puede traer consecuencias patrimoniales indemnizables: los gastos de atención médica y la pérdida de una ganancia por la inhabilidad física (lucro cesante). Además puede dar lugar a otros rubros de daños extrapatrimoniales como el sufrimiento o dolor psíquico, el daño estético y la privación del gusto por la vida.

En Chile, Elorriaga ha propiciado la autonomía del concepto de daño corporal, de manera de excluirlo de la categoría de daño material donde sólo se aprecian las consecuencias patrimoniales pero no el daño físico en sí. En concepto de este autor, el daño corporal debe situarse como una categoría de daño extrapatrimonial de carácter personal independiente del daño moral.

e) *El daño estético*

Como una consecuencia del daño corporal ha sido advertida la necesidad de reparar el daño estético o a la apariencia física. “La reparación del perjuicio estético –señala Elorriaga– está orientada a compensar los sufrimientos que experimenta el sujeto en su fuero interno al saberse y sentirse negativamente modificado su aspecto”.

f) *“Wrongful birth” y “wrongful life”*

Como explica CORRAL, desde hace ya algunos años, primero en Estados Unidos y luego en Europa, se están presentando demandas que, de alguna forma, plantean que el hecho de que un niño haya nacido es constitutivo de daño indemnizable en favor de los padres que deben acogerlo o incluso del mismo niño que llega a la vida con alguna limitación física.

La primera clase o tipo son los denominados casos de *“wrongful birth”*, que se refiere al caso de padres que reclaman por tener que hacerse cargo de las responsabilidades paternales frente a un nacimiento imprevisto de un hijo e imputan una negligencia médica o falta de información en la práctica de una esterilización o de un aborto frustrado. En Chile, se presentó un caso semejante ante la demanda de una mujer que había concebido y alumbrado dos niñas en contra del médico que le había practicado un ligamiento de trompas sin informarle que sólo había sido parcial: se dio lugar a indemnización por daño emergente y moral (C. Antofagasta, 2 de mayo de 2012, Rol N° 373-2011).

La segunda clase –mucho más compleja y discutible– se refiere a casos de *“wrongful life”*, en los que se pretende que si existió algún error en la práctica de exámenes y diagnósticos

prenatales y por ello no se advirtió a la madre que su hijo venía con alguna malformación o discapacidad, los centros o profesionales médicos deben indemnizar los daños patrimoniales y morales que representa para los padres el nacimiento de un niño enfermo (son los casos de). Se hace ver que la madre, de haber sabido la tara que afectaba al hijo, habría podido impedir su llegada al mundo por medio de un aborto, que en los países en los que estos casos se plantea está legalizado. Se trataría de una “*pérdida de una chance*”: el médico, con su error de diagnóstico, habría impedido a la madre ejercer la posibilidad de elegir suprimir la vida del niño enfermo y evitarse así la carga de cuidarlo.

CORRAL observa que esta última clase de casos es inaceptable, en cuanto no se reconoce al ser humano y a su dignidad esencial como un fin en sí, que exige respeto incondicionado y está por encima de todo análisis utilitarista. Agrega que un hijo no puede ser nunca concebido como daño, ni económico ni moral, aunque esté aquejado de una dolencia. Un ser humano, aunque limitado y enfermo, es siempre una persona que incrementa la bondad y la belleza del mundo. Tampoco la propia existencia puede ser considerada como un daño: no se puede comparar, ni es admisible que alguien lo plantee, la no existencia con la existencia. Si la vida humana es un valor fundamental de todo sistema jurídico civilizado, su conceptualización como daño reparable no puede ser sino un síntoma de desquiciamiento y barbarie.

Por cierto, señala CORRAL, lo anterior no se opone a que el hijo pueda reclamar el daño corporal que le haya sido causado *in utero* o por una manipulación en técnicas de procreación artificial. Tampoco a que el hijo reclame por la falla de un diagnóstico prenatal que de haber sido hecho correctamente hubiera podido permitir un tratamiento oportuno que le sanara de la dolencia que le aquejaba *in utero*. En estos casos lo que se reclama es la lesión a la salud (por tanto, de un bien propio de la vida) del propio *nasciturus*.

Nada se opone tampoco a que los llamados casos de *wronglife* sean objeto de prestaciones y ayudas de la seguridad social para permitir un mejor desenvolvimiento e integración familiar, escolar y social del discapacitado. Esto es justamente lo contrario que tratarlo como daño y rebajarlo a la categoría de indemnización monetaria: es considerarlo como persona cuya vida y desarrollo es un bien para todos.

(iv) El daño moral en las personas jurídicas

Si bien durante buena parte del siglo pasado la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia fue uniforme en negar toda reparación de daños morales a cualquier clase de asociación, desde hace alrededor de dos décadas comenzaron a pronunciarse –aunque de forma bastante aislada– fallos en el sentido contrario. Comoquiera que sea, se debe advertir que un detenido estudio de las sentencias dictadas sobre la materia dan cuenta que en la actualidad no existe uniformidad –mas sí una tendencia– en reconocer el derecho de las personas jurídicas a ser resarcidas por estos rubros, en la medida que en el caso concurran determinados presupuestos.

Sobre la materia, se debe considerar que la idea misma de daño moral ha sufrido varios cambios desde su irrupción como un aspecto importante del estudio del Derecho. En efecto, el daño moral transitó desde una concepción limitada a los sentimientos de una persona hacia una cada vez mayor ampliación de una lista interminable de rubros, como el daño biológico, la pérdida del agrado de vivir, el perjuicio estético, etc. Por lo mismo, es que la mayoría de la doctrina reserva hoy el nombre de daño moral solamente a una especie determinada de los perjuicios que no pueden evaluarse económicamente, y que corresponde a la aflicción o pesar padecido por la víctima de la acción; el también llamado "*pretium doloris*". El género, por su parte, se prefiere denominarlo como daños extrapatrimoniales o inmateriales (que en forma eufemística, pero forzada, algunos autores estiman que afectarían el "*patrimonio ideal*" de un sujeto en oposición a su "*patrimonio material*").

Es evidente que el daño moral, en su acepción moderna y restringida, no puede ser experimentado por una persona jurídica, lisa y llanamente porque no puede sufrir tristeza alguna. De ahí que la doctrina y los abogados hayan tenido que levantar la mirada en busca de otros rubros en los cuales identificar las lesiones extrapatrimoniales de estas entidades.

La fundamentación del daño extrapatrimonial de las personas jurídicas más célebre en Chile y el Derecho Comparado, consiste en determinar que sólo son indemnizables aquellos menoscabos que si bien no inciden en el patrimonio de una persona, proyectan sus consecuencias nocivas en el patrimonio de la víctima. Sería de esta naturaleza, por ejemplo, la situación de la empresa que en razón de la publicidad infundada sobre la mala calidad de sus productos ve reducido su número de clientes, o el caso real ocurrido en España, de la empresa que es incluida indebidamente en un registro de deudores morosos viendo afectada su capacidad de crédito. La crítica que ha debido enfrentar esta doctrina es la asimilación de la consecuencia pecuniaria de una conducta dañosa como un asunto extrapatrimonial: si el daño repercute en la esfera del patrimonio, malamente puede ser catalogado como inmaterial, no tratándose de un perjuicio extrapatrimonial.

De otro lado, hay quienes han llamado a no confundir las consecuencias del hecho: un mismo comportamiento puede dar lugar a resultados perjudiciales tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, los que deben ser indemnizados si se dan las condiciones necesarias para ello, particularmente en el caso de los daños inmateriales, que lesionen objetivamente los derechos de la personalidad de una persona jurídica.

Un examen breve de la jurisprudencia nacional permite comprobar el desarrollo que esta discusión ha tenido en nuestro país, que, al igual que otros países ha oscilado sin una postura exclusiva entre las distintas doctrinas que hemos expuesto anteriormente. Un primer pronunciamiento que ineludiblemente no podemos dejar de lado es un muy acabado fallo por el que la Excm. Corte Suprema descartó de plano la hipótesis de que

una persona jurídica pudiera sufrir perjuicios exclusivamente extrapatrimoniales, siendo indemnizables sólo aquéllos que tuvieran consecuencias patrimoniales al verse afectado el prestigio o la confianza comercial de la víctima (Excma. Corte Suprema, 9 de diciembre de 2003, número de ingreso 4677-1999).

De ahí en adelante, pareciera haberse establecido éste como el criterio principal dentro de la jurisprudencia chilena para revisar la legitimación activa de las personas jurídicas para reclamar la indemnización de estos perjuicios, dejando atrás la visión que denegaba sin más la procedencia de la reparación de éstos. Así, se ha resuelto que *“lo que debe verse afectado es la reputación de la persona jurídica y ella sólo si tiene trascendencia en la situación económica (...) y no por el solo hecho de lesionar la reputación”* (Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, 18 de octubre de 2011, número de ingreso 768-2011); que respecto de las personas jurídicas *“cabe descartar a su respecto el concepto de daño moral puro y centrarnos en el daño moral con consecuencias patrimoniales”* (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 23 de noviembre de 2009, número de ingreso 6875-2011); o que *“para pretender ser indemnizado por el daño a la imagen de una empresa, es necesario demostrar que ha existido lesión a la imagen de una empresa, y acreditar, de una manera cierta, las consecuencias económicas en que se ha traducido ese desprestigio”* (Excma. Corte Suprema, 31 de octubre de 2012, número de ingreso 3325-2012). Existen, sin embargo, otras sentencias minoritarias que han denegado la indemnización de este rubro de perjuicios (por todas, Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, 29 de septiembre de 2008, número de ingreso 3688-2004).

(v) Prueba del daño moral

En cuanto a la prueba del daño moral numerosos fallos sostienen que en determinadas situaciones el daño moral no requiere de una acreditación por medios formales, ya que su ocurrencia se desprende de las circunstancias en las que ocurre el hecho y las relaciones de los partícipes, como ocurre con la muerte de un hijo.

Según una posición más extrema el daño moral no requeriría prueba puesto que la sola constatación de una lesión a un derecho extrapatrimonial genera el perjuicio, quedando el juez atribuido de la facultad de evaluarlo.

Sin embargo, lo cierto es que, como todo daño -requisito de la acción de responsabilidad-, el de carácter moral debe probarse, procediendo al efecto todos los medios de prueba admisibles legalmente. Pero la prueba del daño moral debe acomodarse a su naturaleza especial: si se alega un daño corporal, debe acreditarse la pérdida que la lesión o enfermedad produce a la víctima; si se trata de un daño estético, debe apreciarse por el juez que efectivamente el daño es real; si se trata del dolor psíquico, la prueba deberá centrarse en la acreditación de los hechos que ordinariamente para una persona normal en la misma situación hubiera sentido. De este modo, la prueba por presunciones adquiere especial relevancia; presunción que en todo caso debe fundarse en hechos conocidos,

probados y existentes en el proceso y el juez debe explicar el raciocinio lógico por el cual del hecho conocido es posible arribar al hecho ignorado y que se quiere establecer.

(vi) Evaluación del daño moral

Respecto de la evaluación del daño moral los tribunales se enfrentan a la dificultad de traducir lo que es un concepto intangible en una realidad monetaria y lucrativa. Están contestes los tribunales en que la evaluación del daño moral es una facultad privativa de los tribunales del fondo y no es susceptible del control de casación.

Los criterios de evaluación que se emplean son las consecuencias físicas, psíquicas, sociales o morales que se derivan del daño causado; las condiciones personales de la víctima; el grado de cercanía o de relación afectiva que el actor tenía con la víctima; la gravedad de la imprudencia de la conducta del autor que causó el perjuicio; la situación patrimonial o económica del ofendido y del ofensor; la clase de derecho o interés extrapatrimonial agredido; la culpabilidad empleada por el ofensor y la víctima; etc.

4. PRUEBA DEL DAÑO

La prueba del daño corresponde a la víctima.

El daño material puede ser acreditado haciendo uso de todos los medios de prueba. En lo que respecta al lucro cesante, estos medios consistirán usualmente en presunciones e informes periciales.

Respecto del daño moral tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que no requiere prueba. Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño, por ejemplo, la calidad de hijo de la víctima que fallece en un accidente.

5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA REGULACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN

Se ha considerado en general por nuestros tribunales que la determinación del monto del daño es cuestión de hecho, no susceptible de revisión por la vía de la casación, pero la calificación de ellos, aunque se ha vacilado mucho, o sea, si es daño eventual, indirecto, moral, etc., es cuestión de derecho.

F. LA CAUSALIDAD

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CAUSALIDAD

Para que un hecho doloso o culpable genere responsabilidad, es necesario que entre éste y el daño exista un vínculo o nexo, una relación de causalidad o de causa-efecto: el hecho ilícito debe constituir una causa del daño, y el daño debe ser un efecto del hecho ilícito.

Si bien el requisito de la causalidad no se encuentra reglamentado en el Código Civil, diversas normas del título XXXVI del Libro IV lo reconocen de forma implícita: el art. 2314 señala que el delito o cuasidelito debe haber “inferido daño a otro”; el art. 2318 afirma que el ebrio es responsable del daño “causado por su delito o cuasidelito”; los arts. 2319 y 2325 se refieren a los “daños causados”. Adicionalmente, buena parte de la doctrina se apoya en el art. 1558, norma de la responsabilidad contractual cuya aplicación amplían a sede extracontractual; dicha disposición señala que se debe responder de “los perjuicios que fueron consecuencia inmediata y directa”.

El análisis y establecimiento de la relación de causalidad como requisito de la responsabilidad es uno de los tópicos más complejos y que ha dado lugar a mayor discusión y doctrinas, muchas de ellas elaboradas por la ciencia penal, y utilizadas por la doctrina civil.

En efecto, para efectos jurídicos la identificación de la causa de un daño puede ser de resolución sencilla: por ejemplo, no cabe duda que un conductor ebrio que no respeta una luz roja será la causa del daño sufrido por un peatón por él atropellado mientras cruzaba correctamente la calzada. Sin embargo, el tema puede complejizarse por innumerables factores: ¿qué ocurre si a raíz del atropello el peatón sufre una lesión menor, por la cual concurre a un hospital donde le dan un antibiótico respecto del cual es alérgico y termina matándolo? ¿o bien sube a una ambulancia que colisiona con otro auto y también provoca la muerte?

Los estudios de derecho penal suelen mencionar diversos casos típicos en los que la conexión causal es compleja:

- a) Casos de inducción a autoasumir riesgos o peligros ordinarios. Por ejemplo, quien, con la intención de que muera, le aconseja a alguien pasear en un lugar donde se desata una tormenta y hay probabilidades de que caiga un rayo; en el evento que efectivamente caiga el rayo y que éste produzca la muerte, ¿puede decirse que el comportamiento del autor ha sido la causa del daño?
- b) Casos de agravamiento del mal por defecto imperceptible de la víctima. Por ejemplo, quien golpea a otro sin más ánimo que causarle lesiones leves, pero por un defecto constitutivo de la víctima, el golpe le provoca la muerte. ¿Ha sido la acción del agente la causa del daño?
- c) Casos de desviación del curso causal normalmente esperable. Por ejemplo, una persona golpea a otra causándole lesiones leves, pero luego al ser trasladado al centro médico en una ambulancia fallece con motivo de la colisión de ésta con otro vehículo. ¿Debe juzgarse al que causó el golpe inicial como agente causante del daño final en el que devino el curso causal?

Los diversos casos problemáticos desde la perspectiva causal han dado lugar a múltiples teorías sobre la relación de causalidad, las que sumariamente se analizarán en el siguiente apartado.

2. TEORIAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD

Las múltiples doctrinas que se han forjado para determinar la causa en materia de responsabilidad pueden agruparse en dos grandes corrientes: las teorías de carácter empírico o naturalísticas y las teorías normativas. Las primeras intentan localizar el momento causal observando los fenómenos empíricos o naturales, y emplazando la conducta humana dentro del cortejo de acontecimientos que ocurren en la naturaleza según las leyes físicas. Las segundas, si bien parten de la observación del suceder causal empírico, estiman imprescindible, para asignar el rol de causa, efectuar valoraciones jurídicas o normativas que superen el marco de las previsiones y conexiones de la mera causalidad física.

2.1. Teorías empiristas

(i) Teoría de la equivalencia de las condiciones

Esta teoría, la más clásica y también denominada de la “*condictio sine qua non*”, postula que no es posible distinguir de entre las varias condiciones que concurren para producir un resultado (dañoso), cuál es más causa que otra. Todas ellas son equivalentes en cuanto a la causalidad. De esta forma, aunque hayan concurrido otros factores, si el hecho voluntario del eventual autor del daño es una de las condiciones que intervinieron en la producción del resultado lesivo, vale como causa, y puede establecerse una relación de causalidad suficiente para establecer la responsabilidad.

Para conocer si un factor es verdaderamente condición del resultado, y por tanto equivalentemente causa, la teoría utiliza el procedimiento de la *supresión mental hipotética*. Así, si se busca saber si un factor es condición (y por ende causa) del resultado, se debe reconstruir mentalmente la situación sin el factor analizado: si en este supuesto el resultado igualmente hubiere acaecido, quiere decir que dicho factor no fue una condición del mismo. En cambio, si al prescindir mentalmente del factor en análisis el resultado no se hubiera producido, entonces dicho factor tiene la categoría de condición (*condictio sine qua non*: condición sin la cual el resultado no hubiera tenido lugar). Y siendo condición, eso lo habilita para ser tratado como causa del resultado, en el sentido que sin su concurrencia el hecho dañoso no habría tenido lugar.

De este modo si en un resultado dañoso interviene una secuencia de causas necesarias, como en caso de lesiones sufridas en un accidente del tránsito que devienen mortales por un erróneo tratamiento médico, cada una de ellas por separado de lugar a un vínculo

causal a efectos de determinar las responsabilidades civiles por la muerte de la víctima. Aplicando este criterio, si en la producción del daño han intervenido como condición necesaria otros hechos ilícitos atribuibles a terceros, la persona obligada a indemnizar podrá repetir contra sus autores por la parte que a cada uno corresponda, pero frente a la víctima estará obligada íntegramente por el daño causado (según la regla de solidaridad contenida en el art. 2317).

Esta teoría ha sido muy empleada por la jurisprudencia nacional, especialmente por su simpleza.

Así, por ejemplo, en dos casos ha resuelto que si una persona fallece de una gangrena sobrevenida a causa del accidente, el daño es directo y debe indemnizarse, porque civilmente se responde de todos los daños inmediatos como también de los mediatos o remotos que sean consecuencia necesaria del acto, pues a no mediar éste no habrían ocurrido

Sin embargo, ha sido objeto de severas críticas por parte de la doctrina:

a) En primer término, se indica que la supresión mental hipotética sólo es eficaz si se ha hecho un juicio previo sobre si el factor suprimido es o no causa del resultado.

ROXIN plantea esta refutación en los siguientes términos: “Si por ejemplo se quiere saber si la ingestión del somnífero ‘contergan’ durante el embarazo ha causado la malformación de los niños nacidos subsiguientemente..., no sirve de nada suprimir mentalmente el consumo del somnífero y preguntar si en tal caso habría desaparecido el resultado; pues a esa pregunta sólo se puede responder si se sabe si el somnífero es causal o no respecto de las malformaciones, pero si eso se sabe, la pregunta está de más. En una palabra: la fórmula de la supresión mental presupone ya lo que debe averiguarse mediante la misma”

b) Asimismo se observa que en casos de causalidad acumulativa en que actúan dos causas independientes que por su confluencia producen el resultado, pero que si se eliminara mentalmente cualquiera de ellas debería llegarse a la conclusión que ninguna de ellas es causa, produciendo la impunidad del hecho.

Un autor pone como ejemplo el que, el día de la ejecución de un asesino por parte de un batallón de fusilamiento, el padre de la víctima dispara y da muerte al asesino. En tal caso, conforme a la teoría en análisis si se suprime el obrar del padre, igualmente se habría producido el efecto (muerte del asesino por parte del batallón), por lo que éste no sería responsable.

c) Otra crítica de esta teoría provino de advertir que, aplicada con rigor, conducía a una extensión exagerada de la responsabilidad, ya que cualquier hecho situado en la cadena de acontecimientos en la que luego se inserta el resultado podía ser considerado causa del mismo.

Así, llevando las cosas al extremo, podría imputarse la causalidad de un homicidio a los padres que procrearon al asesino.

(ii) Teoría de la causa adecuada

Esta teoría intenta corregir las deficiencias de la teoría de la equivalencia de las condiciones, haciendo una distinción entre las condiciones que concurren en la producción del daño. Así, entre todas las causas que concurren a la producción del daño debe elegirse aquella que normalmente ha de producirlo, o sea, es necesario preferir el acontecimiento que ha desempeñado el papel preponderante en la ocurrencia del perjuicio.

Según la doctrina de la causa adecuada, la atribución de un daño supone que el hecho del autor sea generalmente apropiado para producir esas consecuencias dañosas. Si desde la perspectiva de un observador objetivo, la ocurrencia del daño es una consecuencia verosímil del hecho, entonces se puede dar por establecida una relación de causa adecuada y habrá lugar a la responsabilidad. La causa no es adecuada cuando responde a factores intervinientes que resultan casuales, porque según el curso normal de los acontecimientos con posterioridad al hecho resultan objetivamente inverosímiles en la perspectiva de un observador imparcial.

Si bien esta doctrina tiene el mérito de limitar la extensión de la causalidad, también ha sido objeto de críticas. Las mayores dificultades que plantea la doctrina de la causa adecuada se refieren a que introduce también en sede la atribución objetiva del daño al hecho ilícito un elemento de *previsibilidad* que es propio de la culpabilidad, confundiendo ambos elementos.

Adicionalmente, la doctrina de la causa adecuada recurre a la figura del observador externo que debe juzgar *ex-post* cuáles daños pertenecen al desarrollo natural de los acontecimientos y cuáles a circunstancias extraordinarias que alteran sustantivamente el curso causal e impiden efectuar esa atribución. Con ello se puede generar una distorsión en el análisis, por cuanto el observador *ex – post* regularmente contará con mucha mayor información que el agente, lo cual influirá en su juzgamiento.

Más allá de su origen probabilístico, en la práctica la definición de lo que se tendrá por curso normal o extraordinario dependerá de la actitud que asuma el observador. Por cierto que este observador cuenta con la información disponible para quien realizó la acción. Pero, además, cuenta con una información acerca del curso verosímil de los acontecimientos que puede tener diversos niveles de intensidad. Así, puede entenderse que ese observador dispone de la información que tiene una persona corriente, pero también puede asumirse la perspectiva de un *observador óptimo*, como ha tendido a aceptar la jurisprudencia alemana, que dispone de información perfecta, con lo cual la responsabilidad se extiende más allá de lo que pertenece a lo previsible según la experiencia general de la vida. En definitiva, la atribución supone un juicio de valor, porque el *curso ordinario* de los acontecimientos puede ser extremado hasta consecuencias que una persona corriente no estaba en condiciones de tomar en consideración. Pareciera que la posición del observador óptimo, que todo lo sabe porque está en una situación extrema de información, que además es definida *ex-post*, desnaturaliza la idea de que el desarrollo posible de los acontecimientos, según la información del autor del hecho y la experiencia general, establece el límite a la responsabilidad por efectos dañosos subsecuentes.

Para superar estas críticas se han ideado nuevas teorías, como la de la *causa eficiente*, que pretende atribuir la cualidad de causa a la condición que podía considerarse como la “más operativa” en el conjunto de la situación, o la de la *causa próxima*, que daba relevancia a la condición “más directamente conectada” con el resultado. Se ha criticado estas teorías porque no sería posible establecer criterios de jerarquía, prioridad o eficacia, si se permanece en el plano ontológico de los fenómenos naturales.

2.2. Teorías normativas

Como se indicó anteriormente, si bien las teorías normativas parten de la observación del suceder causal empírico, estiman imprescindible, para asignar el rol de causa, efectuar valoraciones jurídicas o normativas que superen el marco de las previsiones y conexiones de la mera causalidad física. A continuación se analizarán brevemente estas doctrinas.

(i) Teoría de la relevancia jurídica

Conforme a esta doctrina, para saber qué condiciones son causas en el plano empírico se reconoce la validez de la teoría de la equivalencia: todas las condiciones son causas desde el punto de vista meramente natural. Pero este análisis no basta al jurista, ya que, jurídicamente, no todas las causas son equivalentes. Para el derecho sólo pueden ser tomados en cuenta los procesos relevantes. La relevancia de la causa se determina siguiendo criterios de previsibilidad utilizados por la teoría de la adecuación.

Esta teoría intenta conciliar las teorías de la equivalencia y de la adecuación, y por ello no ha sido acogida plenamente.

(ii) Teoría de la imputación objetiva

Esta teoría fue desarrollada primeramente por LARENZ, para quien la relación de causalidad es una investigación acerca de la existencia de una imputación, es decir, el intento de delimitar dentro de los acontecimientos accidentales un hecho que puede ser considerado como propio (imputable) de un hombre. Para este autor, habrá causalidad (imputación) cuando el hecho, con sus consecuencias, fue previsible y dominable o dirigible.

En base a lo anterior, el penalista ROXIN elaboró la teoría de la imputación objetiva, conforme a la cual la causalidad debe ser jurídicamente entendida como imputación medida por parámetros objetivos. Sólo un resultado imputable al acto del autor puede generar responsabilidad.

Ahora bien, en las acciones existe un nivel de riesgo general de la vida que no puede ser evitado o incluso riesgos que deben ser tolerados o fomentados para bien de la

colectividad. La creación de una situación en la que se mantiene el riesgo general de la vida no puede ser considerada causa del resultado producido por este riesgo. Así, sólo la creación de un riesgo superior al riesgo general de la vida, y que, además sea jurídicamente desaprobado puede ser imputable al autor, generará responsabilidad.

3. LA CAUSALIDAD COMO UN TEMA EMPÍRICO Y NORMATIVO

En la actualidad, la doctrina nacional —CORRAL, BARROS y otros— estiman que la relación de causalidad no puede ser analizada desde una perspectiva ni meramente naturalística ni meramente normativa.

En este sentido, BARROS afirma que la causalidad actúa, por un lado, como elemento o requisito de la responsabilidad civil y, por otro, como límite. Como requisito, exige que el hecho sea condición necesaria del daño. Como límite, pues no basta una relación puramente descriptiva, sino que además exige una apreciación normativa que permita calificar el daño como una consecuencia directa del hecho ilícito. En consecuencia, la determinación del daño directo no es un problema puramente técnico o pericial, pues exige dar por establecida una relación normativa, una razonable proximidad del daño con el hecho.

Este autor otorga los siguientes ejemplos:

- (a) Una persona es atropellada y debe acudir a un hospital para recibir tratamiento. Allí se contagia de influenza (sin que el accidente haya aumentado la disposición a contraerla), y su tiempo de inactividad a consecuencia del accidente se duplica. ¿Es responsable el autor del accidente? Pareciera que no, porque la influenza no tiene por causa adecuada el accidente, ni este fue determinante en aumentar el riesgo.
- (b) Un bocinazo causa un ataque cardíaco en un conductor de avanzada edad. ¿Hay responsabilidad? Pareciera que no. En este caso, la debilidad particular de la víctima opera como una circunstancia exorbitante que excede el ámbito de riesgo creado por la acción.
- (c) La ambulancia que a gran velocidad conduce al herido víctima de un accidente choca ocasionando daños a otro vehículo. ¿Es responsable el autor del accidente? A diferencia de los casos anteriores, se ha entendido que este tipo de circunstancias quedan comprendidas en el ámbito de riesgo creado por la acción y, en consecuencia, dan origen a responsabilidad.
- (d) El mal estado de un camino público produce un choque y un gran atochamiento de tránsito, en el que queda atrapado un empresario que se dirigía a cerrar un negocio. ¿Es responsable el Estado? De ser así, ¿cuál es la extensión de su responsabilidad? En principio, el Estado debe responder de los daños ocasionados por a las víctimas inmediatas del accidente, pero su responsabilidad no alcanza a los daños que sufre el empresario por la pérdida del negocio, pues estos daños son ajenos al fin protector de la norma.

Por su parte, CORRAL afirma que es necesario distinguir entre el actuar humano y el resto de la causalidad de la naturaleza física. Evidentemente un ser humano puede intervenir en el suceder causal sin que su voluntad pueda reputarse causa responsable de un acontecimiento. Lo que interesa en el tema de la responsabilidad es cómo puede atribuirse a una voluntad humana un proceso causal, en cuanto voluntad, y no en cuanto intervención física y natural de un cuerpo de un hombre.

Así, la teoría de la equivalencia de las condiciones y su test de la supresión mental hipotética ayuda a determinar que acontecimientos no son causa y para excluir la causalidad, pero no es suficiente para determinar cuáles son jurídicamente una causa. Para establecerla, resulta necesario complementar el análisis con la previsibilidad del resultado y la determinación del incremento ilícito del riesgo ordinario de la vida.

La previsibilidad del resultado dañino puede introducirse en el análisis de la causalidad para descartar aquellos procesos causales en los que la acción humana interviene decididamente, pero en los que parece imposible imputar ese resultado a ese comportamiento humano concreto al carecer el agente de toda posibilidad de prever las consecuencias que se derivarían de su acción y no poder así atribuirse a su actuación ninguna forma de dirigibilidad del proceso (por ejemplo, el caso del choque de la ambulancia que llevaba al atropellado al hospital). En tales eventos, la relación de causalidad, y por ende la responsabilidad, podrá predicarse sólo por el daño efectivo que el actor pudo prever y dirigir, aunque él sea subsumido en el daño mayor que se produce como consecuencia de circunstancias imprevisibles.

El incremento del riesgo ordinario debe también ser tomado en cuenta para excluir como causales las acciones humanas que, aun cuando hayan operado sobre hechos previsibles, no son constitutivas por sí mismas de un incremento real de los riesgos generales e inevitables de toda convivencia humana. De esta forma, un simple consejo de pasear por un paraje donde suelen desatarse tormentas con relámpagos no puede atribuir jurídicamente responsabilidad en el resultado si la previsible muerte se produce. En todos estos casos el agente no pone nada de su parte para incrementar el riesgo general y por ende el acontecimiento no puede ser atribuible a su voluntad.

4. PLURALIDAD DE CAUSAS

Existen diversas hipótesis de pluralidad de causas. Así ocurre, ante todo, cuando el daño se debe a la intervención de dos o más personas, ya sea porque todas ellas intervienen en la ejecución del mismo hecho, o porque cada uno ejecuta un hecho distinto que contribuye a ocasionar el daño. Una hipótesis diferente representa el daño debido en parte al hecho del autor y en parte a la intervención de la propia víctima. Según la teoría de la equivalencia de las condiciones, cada causa es considerada antecedente del daño, y cada uno de los causantes es responsable por el total, salvo el caso de culpa de la víctima, en que la indemnización está sujeta a reducción. En una tercera hipótesis el daño puede deberse a un hecho externo al autor del hecho ilícito, que a su respecto constituye caso fortuito o fuerza mayor.

4.1. Caso fortuito o fuerza mayor

Se plantea el problema cuando coexisten en la producción del daño, por una parte un acontecimiento inevitable, imprevisible e irresistible (caso fortuito), y por otra, un comportamiento imprudente del agente.

Para determinar la responsabilidad habría que cuestionar si el comportamiento imprudente puede ser considerado causa del daño, con independencia de la existencia del caso fortuito; es decir, si la acción hubiese causado el perjuicio aun cuando no hubiere intervenido la fuerza mayor. En este caso, debe afirmarse la relación de causalidad, y por tanto la responsabilidad del agente. Al revés, si la causa del daño es el caso fortuito y éste se hubiera producido con independencia del comportamiento negligente del sujeto, no habrá relación de causalidad entre esta conducta y el daño.

Si en algún supuesto cabe imaginar que caso fortuito y comportamiento negligente actúan como concausas en forma necesaria y simultánea, quizás lo más justo sería no absolver totalmente de responsabilidad al agente, pero sí reducir el monto de la indemnización de manera proporcional a la entidad del aporte causal del agente.

4.2. Pluralidad de agentes

Bajo las reglas de la causalidad, puede haber pluralidad de responsables en tres circunstancias: (i) cuando existen varios responsables que actúan simultáneamente ejecutando un mismo hecho; (ii) cuando existen varios responsables por hechos distintos, todos los cuales son antecedentes necesarios del daño (por ejemplo, el caso del peatón víctima de un accidente de tránsito ocasionado por la negligencia concurrente de dos conductores); o bien, (iii) cuando cada hecho individualmente es apto para producir el daño con independencia del otro hecho.

(i) Varios responsables por un mismo hecho

Si un mismo hecho es atribuible a diversas personas todas ellas son solidariamente responsables, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil.

También existe solidaridad entre la persona que según las reglas generales es responsable por el hecho de un tercero que está bajo su dependencia o cuidado y el autor del hecho (artículos 2320, 2321 y 2322 del Código Civil). Aunque los deberes de cuidado infringidos sean diferentes (negligencia en la acción u omisión y negligencia en la vigilancia o cuidado), el hecho que genera la responsabilidad es el mismo.

El Código Civil no contiene una norma general que regule las relaciones internas entre los coautores del daño frente a la obligación de indemnizar. En efecto, no resulta aplicable en materia extracontractual la regla de contribución a la deuda del artículo 1522, que

establece una distribución entre los deudores en atención a su interés en la operación contractual que dio lugar a la obligación solidaria.

La ley, en sede extracontractual, sólo establece una norma especial en el artículo 2325, aplicable a la responsabilidad por el hecho ajeno. Según esta disposición, la contribución recae en el autor del daño, de modo que el tercero civilmente responsable tiene acción en su contra para obtener el reembolso de lo pagado. El reembolso procede a condición de que el autor del daño sea capaz, que no haya existido culpa personal de ese tercero civilmente responsable, y que éste no haya dado una orden al autor del hecho que le debía obediencia.

Para los demás casos no contemplados por esa regla especial es posible idear dos soluciones: se reparte la deuda entre los coautores por partes iguales, o se distribuye entre éstos en razón de la intensidad de su contribución a la consecuencia dañosa. Esta última solución parece preferible, pues resulta coherente con el principio de justa repartición de la contribución a la deuda, que opera cuando ha intervenido la culpa de la víctima, según el artículo 2330 del Código Civil. De acuerdo con este criterio, los coautores contribuyen a la indemnización de acuerdo a la culpa de cada uno y de la causalidad de cada hecho, dividiéndola en proporción al grado o intensidad de la participación de cada responsable.

(ii) Varios responsables por hechos distintos

También se plantea la hipótesis que existan varios responsables por hechos distintos, cada uno de los cuales es causa del daño. En principio, a esta situación no se aplicaría literalmente el artículo 2317 del Código Civil, pues no se trata de un solo delito o cuasidelito, sino de hechos ilícitos distintos, que generan responsabilidad separadamente para sus autores.

Sin embargo, como el autor de cada hecho ilícito debe responder de la totalidad del daño, y la víctima en caso alguno puede obtener una indemnización que exceda el monto de los perjuicios efectivamente sufridos, es necesario dividir la responsabilidad entre los autores de los diversos hechos, en proporción a su participación en el daño. El efecto, en consecuencia, es análogo al del artículo 2317 que establece la solidaridad: cada autor será responsable por el total del daño, sin perjuicio de su acción contra los demás para obtener reembolso en proporción a sus respectivas participaciones.

(iii) Causa difusa

Mayores dificultades presenta la causalidad difusa que se muestra cuando el daño se debió al hecho culpable de alguno entre varios candidatos a responsable, sin que resulte posible determinar cuál concretamente desencadenó esos efectos dañosos. En otras legislaciones la ley ha previsto la responsabilidad de cada uno de tales candidatos. En Chile sólo se conocen las normas sobre responsabilidad difusa por ruina de edificios y

caída de objetos, que establecen una regla de distribución de la responsabilidad, que constituye una excepción al principio de solidaridad del artículo 2317 (artículos 2323.2 y 2328.1).

La experiencia comparada muestra que estas situaciones de causalidad difusa pueden surgir en accidentes de importancia: choques múltiples, productos defectuosos, daños ambientales, entre otros. La regla de división de la responsabilidad, mientras no se pruebe a cual hecho en particular puede ser atribuido el daño, parece ser una solución razonable en estos casos, pues responde al mismo principio de atribución de los artículos 2323 y 2328 ya referidos, según un criterio de integración del vacío legal por analogía.

4.3. Concurrencia de culpa de la víctima

Sobre la materia, cabe primeramente establecer si la culpa de la víctima ha sido la única causa del daño. En tal caso es evidente que no hay responsabilidad para el autor del mismo, porque no hay culpa suya, como si un peatón cruza de improviso la calzada a mitad de cuadra y es atropellado por un vehículo que transita respetando las exigencias reglamentarias.

Pero puede existir también concurso de culpas, esto es, tanto del que causa los daños como de la víctima. Tal situación se encuentra prevista en el art. 2330: “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. O sea, procede una rebaja de la indemnización. Los criterios para determinar la reducción son la intensidad relativa de las culpas o imprudencias y la intensidad de las causas. En general ambos factores son objeto de una evaluación prudencial

Otra cuestión a determinar consiste en establecer si la reducción procede sólo respecto de la reparación solicitada por la víctima a la que es imputable directamente el comportamiento imprudente, o si también la deben sufrir los que piden indemnización de los perjuicios morales derivados por repercusión del daño causado a la víctima imprudente. Los fallos manifiestan criterios diversos. Así, por una parte se ha dicho que la norma se aplica también a víctimas por repercusión: respecto del daño moral reclamado por parientes de las víctimas fallecidas, se ha resuelto que se debe regular la indemnización considerando también la exposición imprudente al daño recibido por parte de los fallecidos. No sería equitativo ni racional imponer al demandado la reparación de la totalidad de un daño que no ha causado sino en parte. Además, de no ser así resultaría que las víctimas indirectas obtendrían una reparación superior a la que hubiera recibido la víctima directa. En sentido inverso se ha dicho que si los beneficiados con indemnización del daño moral no fueron los que se expusieron al daño que reclaman, no procede la reducción, y que su acción es propia e independiente; un fallo sostiene que “La disminución de la indemnización que forzosamente debe hacerse con relación a la víctima imprudente, no cabe aplicarla respecto de sus progenitores, por no haber sido los causantes de tal comportamiento”.

En otras ocasiones, los tribunales buscan fundar la reducción en la misma imprudencia de los parientes que reclaman el daño moral. En un caso de muerte de un infante en un accidente, si bien la sentencia deja en claro que no procede reducción por parte de la víctima por su incapacidad, sí se da lugar a la reducción respecto de los padres que al ausentarse del hogar y dejar solo al niño en un sitio donde se realizaban faenas de excavación donde ocurrieron los hechos, incurrieron en una manifiesta imprudencia, que autoriza la reducción de la indemnización pedida.

Otra cuestión es la de decidir si, para aplicar la norma de la reducción, debe tratarse de una persona con capacidad delictual. Según CORRAL, aquí no hay propiamente una exención de responsabilidad del autor fundada en la responsabilidad de la víctima, por lo que no es necesario acreditar que exista responsabilidad civil por parte de ésta con todos sus elementos. Se trata más bien de una conducta de la víctima por la que ella misma interviene el proceder causal que da como resultado el daño. Siendo así la exposición imprudente puede ser debida a un menor de edad o a una persona inimputable. Sería difícil sustentar la rebaja de la indemnización cuando una misma conducta ha sido desarrollada por una víctima capaz y negarla cuando ha sido llevada a cabo por un menor o incapaz. La jurisprudencia se pronuncia por la exigencia de capacidad delictual de la víctima menor imprudente, pero se deja en claro que sí procede la reducción respecto de los padres que demandan indemnización por la muerte del niño si hubo descuido en su atención.

5. PRUEBA DE LA CAUSALIDAD

Los hechos que den lugar a la relación causal deben ser probados por el demandante, porque se trata de aquellos invocados para dar por probada una obligación indemnizatoria (artículo 1698). La carga de la prueba se extiende a la demostración de que el hecho es condición necesaria del daño (causa en sentido estricto) y a las circunstancias de hecho que permiten calificar el daño como directo (imputación normativa del daño al hecho).

En casos difíciles, no existe otra manera de probarla que las presunciones judiciales, especialmente cuando se trata de daños producidos por causas múltiples o que resultan de la aplicación de tecnologías complejas. En el derecho comparado se ha tendido a favorecer el establecimiento de presunciones judiciales cuando *prima facie* existe una razonable probabilidad que el hecho del demandado ha causado el daño.

Las razones para dar por establecida una presunción legal de culpa por el hecho propio, de acuerdo al artículo 2329, rigen también para dar por acreditada la causalidad; si de acuerdo a la experiencia el daño “puede ser imputado” objetivamente al hecho doloso o culposo de un tercero, éste resulta responsable, a menos que se logre desmontar la presunción mediante la prueba que el mismo allegue al juicio. La norma referida puede ser

construida como una presunción legal de responsabilidad (comprensiva de la culpa o la causalidad, o de ambas, según las circunstancias). Para ello, sin embargo, debe cumplirse el requisito general de aplicación de esa regla, esto es, que de acuerdo con la experiencia la ocurrencia del daño se debe usualmente a un hecho del demandado.

6. CALIFICACION DE LA CAUSALIDAD

La jurisprudencia tradicionalmente ha entendido que la determinación de la causalidad es una cuestión de hecho, y como tal, privativa de los jueces del fondo.

Con todo, la causalidad sólo es una cuestión estrictamente de hecho en su primer aspecto, esto es, entendida como condición necesaria de la responsabilidad. Por el contrario, la atribución normativa del daño al hecho ilícito (daño directo) es una cuestión de derecho, y como tal, susceptible de ser revisado por la Corte Suprema mediante la casación en el fondo

III.

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

1. NOCIONES GENERALES

La regla general en nuestro Derecho —aplicable al ámbito contractual y extracontractual— es que una persona no sólo responde por los daños que ocasione él mismo (materia que se ha analizado hasta ahora), sino también por los perjuicios ocasionados por las personas que de él dependen (Arts. 1590, 1679, 2320 y 2322 del Código Civil).

En el ámbito extracontractual el principio general está establecido en el artículo 2320 inciso primero del Código Civil, que señala: *“Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”*.

La norma establece un principio general de responsabilidad en dos sentidos. En primer lugar, porque se aplica genéricamente a todas las relaciones de dependencia o cuidado, de modo que las situaciones específicas referidas en los demás incisos del artículo 2320 son puramente ejemplares. En segundo lugar, porque establecida la relación de dependencia o cuidado de quien realiza un acto susceptible de generar responsabilidad, se presume la culpabilidad de quienes deben ejercer ese cuidado, de modo que sólo pueden exonerarse de esa responsabilidad si logran probar que “con la autoridad y el cuidado que la respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho” (artículos 2320.5 y 2322.2).

Existen numerosas leyes especiales que también establecen para casos particulares la responsabilidad por el hecho ajeno. Por ejemplo, el Art. 886 del Código de Comercio sobre la responsabilidad del naviero por los daños causados por su capitán; el Art. 162 del Código Aeronáutico sobre la responsabilidad del explotador de la nave por la culpa o dolo del piloto; el Art. 174 de la Ley N° 18.290 sobre Accidentes del Tránsito sobre la responsabilidad del dueño del automóvil por los hechos del conductor; entre varias.

La responsabilidad por el hecho ajeno puede estar construida como una forma de responsabilidad estricta, que en este caso suele denominarse *vicaria*. En diversos sistemas jurídicos, establecida la relación de dependencia y el hecho ilícito que causa daño cometido por el dependiente, la responsabilidad de quien tiene a este bajo dirección o cuidado no está basada en la culpa, sino en el mero hecho de concurrir esas circunstancias (common law, derecho francés, por ejemplo). En el derecho chileno la responsabilidad por el hecho ajeno está construida sobre la base de un *doble ilícito civil*: el del dependiente, que causa el daño directamente, y el de quien lo tiene bajo dirección o cuidado (*guardián*), cuya culpa es legalmente presumida. La culpa del *guardián* consistirá en no haber actuado con el

cuidado necesario para evitar que el tercero ocasione daños, ya sea al elegir, instruir o vigilar a éste último.

El fundamento de esta responsabilidad radica en que un sujeto puede favorecer la comisión de un hecho dañoso en caso de haber estado en la posición de haber impedido que dicho menoscabo se consumara, omitiendo este cuidado necesario que de haber sido desplegado hubiera llevado a evitar que se lesionara a la víctima. Por lo mismo, en atención a esta especial autoridad, que lo habilita para ordenar la conducta de quien produce directamente el daño, es que nuestro Derecho lo hace también sujeto de responsabilidad.

En otras palabras, la atribución de responsabilidad respecto del guardián se fundamenta en el deber de vigilancia o en el deber de correcta selección que tienen ciertas personas respecto de otras. Por tanto, no se responde sólo por culpa ajena, sino también por la propia, que consiste en la falta de esos deberes (culpa *in vigilando* u culpa *in eligendo*) y que permite el desplazamiento de la culpa desde el agente directo al tercero responsable. Como se indicó anteriormente, la vulneración del deber de vigilancia o de selección se presume por el art. 2320.1.

2. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

La doctrina ha señalado que para que proceda la responsabilidad por el hecho ajeno deben concurrir los siguientes requisitos: (i) capacidad delictual del dependiente y del guardián; (ii) comisión de un hecho ilícito por parte del dependiente; y (iii) un vínculo de subordinación o dependencia entre el guardián y el autor material del daño.

2.1. Capacidad delictual del hechor y responsable

El art. 2319, que establece el requisito de la capacidad en los hechos ilícitos, no distingue si se trata de responsabilidad por el hecho propio o ajeno, y por tanto se aplica a ambos. En consecuencia, tanto el que cometió el hecho ilícito como quien lo tenía a su cuidado no deben estar comprendidos en las causales de incapacidad para que haya lugar a la responsabilidad por el hecho ajeno.

Si es *incapaz quien cometió el hecho ilícito*, tiene aplicación el art. 2319 citado, y responden únicamente los que tienen a su cuidado al incapaz “si pudiere imputárseles negligencia”. La gran diferencia que existe entre los arts. 2319 y 2320 es que la responsabilidad por el hecho ajeno no excluye la del hechor y se presume la culpa de quien tiene a su cuidado a otro; en cambio, tratándose de un incapaz, debe acreditarse la culpa del guardián.

Y si el incapaz resulta ser la persona a quien se pretende responsabilizar del hecho ajeno, el mismo art. 2319 lo impedirá, ya que excluye de toda obligación de indemnizar tanto por el hecho propio como por el ajeno o de las cosas. Y así, por ejemplo, el padre demente no

responderá del hecho de sus hijos menores que vivan con él, pues mal puede cuidar de otra persona quien no puede atenderse a sí mismo.

2.2. Comisión de un hecho ilícito por la persona de cuyos actos se responde

En la responsabilidad por el hecho ajeno hay obligación de indemnizar la comisión de un delito o cuasidelito civil de otro; en consecuencia, el hecho cometido por la persona de quien se responde debe reunir todos los requisitos de la responsabilidad extracontractual.

Aún más, la víctima debe probarlo, a menos que a su respecto exista otro tipo de presunción legal; a falta de ella, deberá acreditar la acción u omisión culpable o dolosa, el daño y la relación de causalidad, todo ello conforme a las reglas generales. La única diferencia es que establecido el hecho ilícito, esto es, probadas todas las circunstancias señaladas, la víctima queda liberada de acreditar la culpa del tercero civilmente responsable. Ella es la que se presume. Por tal razón se ha fallado que no hay responsabilidad de terceros si el hechor ha sido declarado absuelto por falta de culpa.

2.3. Vínculo entre hechor y responsable

En las responsabilidades por el hecho ajeno existe un vínculo entre el responsable y el hechor, que, en general, y desde luego en todas las del Código, es uno de subordinación y dependencia, porque si el fundamento de ellas es una falta de vigilancia, es necesario que se tenga autoridad respecto de la persona por quien se responde. Esto es lo que la ley dice al hablar de aquellos que “estuvieren a su cuidado”.

En los casos expresamente enumerados por la ley se presume la existencia del vínculo de subordinación y así, por ejemplo, el padre para eximirse de responsabilidad deberá probar que no tenía al hijo a su cuidado. En los demás deberá probarse por el que invoca la responsabilidad del hecho ajeno el mencionado vínculo.

Aplicando este requisito se ha resuelto que el ejecutante no responde de los hechos del depositario definitivo, ni el que encargó la obra por los del contratista que ejecuta ésta por su cuenta, ni el mandante por los hechos ilícitos del mandatario, porque los mandatos se otorgan para ejecutar actos lícitos, y el mandatario no está al cuidado del que le dio poder.

El vínculo de dependencia no requiere formalización jurídica, sobre todo cuando se trata de dependientes de un empresario; es una situación fáctica caracterizada por la autorización expresa o tácita del principal para que alguien gestione en interés del primero un determinado negocio siguiendo sus instrucciones, órdenes u orientaciones.

3. CASOS PARTICULARES DE TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES

Sin perjuicio de la regla general consagrada en el art. 2320.1 del Código Civil, dicho cuerpo legal y otras leyes especiales han consagrado casos específicos y particulares de responsabilidad por el hecho ajeno.

Los casos que el Código Civil reglamenta son los siguientes:

3.1. Responsabilidad del padre o madre por sus hijos menores que habiten con ellos

Dice el inc. 2º del art. 2320: *“Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”*.

En la actualidad, de acuerdo con la regla contenida en el art. 224, el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente. En los casos de filiación no matrimonial (definida en el art. 180), el cuidado personal del hijo corresponde al padre o madre que lo hubiese reconocido y, si ninguno lo ha reconocido, a un tutor o curador designado por el juez.

Si los padres viven separados, se aplica la regla contenida en el art. 225, que asigna el cuidado personal de los hijos a la madre, lo cual no obsta a que, por acuerdo celebrado con las formalidades y los plazos que la citada disposición prescribe, el cuidado personal pueda corresponder al padre. También corresponde al padre la tuición si el juez se la atribuye en consideración al mejor interés del niño, según la regla de clausura del art. 242 inc. 2.

Para que tenga lugar esta responsabilidad por el hecho ajeno es necesario que se cumplan las siguientes circunstancias:

- (i) Debe tratarse de hijos menores de 18 años. Estos son los hijos menores en nuestra legislación. Por los hijos mayores no responden los padres; en consecuencia, en el caso del art. 251, o sea, si el hijo de familia comete un hecho ilícito en la administración de su patrimonio profesional o industrial, no responderán los padres, porque el hijo “se mirará como mayor de edad”.
- (ii) El hijo debe habitar en la misma casa con sus padres. Así lo exige la ley, pues en tal caso podrán ejercer la vigilancia necesaria; de ahí que en principio los padres no responden de los hechos de sus hijos menores que no conviven con ellos, salvo el caso de excepción del art. 2321, según se verá a continuación.
- (iii) Que el padre o la madre, con la autoridad y cuidado que su calidad les confiere, no haya podido impedir el hecho (art. 2320, inc. final).

Los dos primeros requisitos los debe probar el demandante; el último se presume, y toca a los padres acreditar que no pudieron impedir el hecho ilícito, prueba que no se les acepta en el caso del art. 2321, que señala que “los padres serán *siempre responsables* de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”. Como la disposición usa la expresión “siempre” se concluye que es una presunción de derecho, de manera que probado el hecho ilícito y que él proviene conocidamente, esto es, notoriamente de alguna de las circunstancias señaladas, nada obtendrían los padres con probar que no se reúnen los requisitos anteriores, como el caso del hijo que no vive con el padre, o que con su autoridad y cuidado fue imposible evitar el hecho; siempre será responsable mientras el hijo sea menor.

3.2. Responsabilidad del guardador por el pupilo

El inciso tercero del art. 2320 indica que “*Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado*”.

Corresponde esta responsabilidad al tutor por los hechos del impúber mayor de 7 años que ha obrado con discernimiento y a los curadores generales del menor adulto, o sea menor de 18 años, pero siempre que teniendo menos de 16 años haya obrado con discernimiento, del disipador y del sordomudo que no puede darse a entender por escrito; no del demente, dada la incapacidad extracontractual de éste. El guardador del incapaz sólo responderá si se le prueba negligencia de acuerdo al art. 2319.

La ley no exige que el pupilo viva en la misma casa del guardador, como lo hizo respecto del padre o madre; basta que lo haga bajo su dependencia y cuidado; por ello no puede aplicarse a los curadores adjuntos, de bienes y especiales, que no tienen a su cuidado al pupilo, y de acuerdo a la regla general del inc. final del art. 2320, el tutor o curador se libera de responsabilidad, probando que con la autoridad y vigilancia que su cargo le confiere no ha podido impedir el hecho.

3.3. Responsabilidad de los jefes de escuelas y colegios por sus discípulos

Dice la primera parte del inc. 4º del art. 2320: “*Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras estén bajo su cuidado*”.

La responsabilidad afecta al jefe o quien ejerza el cargo equivalente, director, rector, etc., por los hechos ilícitos de sus discípulos mayores o menores de edad, ya que el precepto no distingue como en otros casos. Y sólo subsiste mientras los tenga a su cuidado, o sea, mientras permanezcan en el establecimiento o bajo su control. Se libera de ella de acuerdo a la regla general, o sea, si prueba que con su autoridad y cuidado no habría podido impedir el hecho.

3.4. Responsabilidad del artesano por sus aprendices

De conformidad al art. 2320.4 los artesanos responden por el hecho de sus aprendices, mientras están bajo su cuidado.

Son artesanos los que ejercitan algún arte u oficio mecánico, sin maquinarias complejas y en pequeña escala; el aprendiz es el que está adquiriendo bajo su dirección el mismo arte u oficio.

La responsabilidad del primero por los hechos del segundo subsiste mientras el aprendiz esté bajo vigilancia del artesano; puede suceder que viva con él, y en tal caso es permanente. Es indiferente que el aprendiz sea mayor o menor de edad, y que esté unido al artesano por un contrato de trabajo o no. Este se libera de responsabilidad conforme a la regla general del inc. final del art. 2320: probando que con su autoridad no habría podido evitar el hecho ilícito.

En realidad, esta responsabilidad se funda más bien en la relación casi patriarcal entre artesano y aprendiz que en el vínculo de trabajo que entre ellos existe;

3.5. Responsabilidad del empresario por sus dependientes

De conformidad al art. 2320.4 los empresarios responden por el hecho de sus dependientes mientras estén a su cuidado.

El Código habló de “empresario” y “dependiente”, expresiones que no son muy precisas en la legislación, pero que los tribunales han entendido en un sentido sumamente amplio. Otras legislaciones, como la francesa e italiana, usan un término más extensivo que el de empresario, “comitentes”.

En efecto, uno de los campos donde mayor desarrollo ha experimentado la jurisprudencia en el último tiempo es precisamente el de determinar cuáles son las personas que se encuentran sometidas a la autoridad del empresario. La delimitación de esta materia, como es lógico, es de suma importancia, habida consideración que su mayor o menor extensión determinará el número de personas por las que responde el empresario, la que en la actualidad no sólo se encuentra restringida a los funcionarios que directamente trabajen bajo sus órdenes.

Una primera interpretación dada por la jurisprudencia al arts. 2320.4 concluyó que sólo cabía atribuir responsabilidad al empresario por los hechos de sus dependientes en la medida que hubiera una relación que vinculara al empresario con el subordinado autor del daño, en términos tales que autorizara el empresario a impartir instrucciones al funcionario que le son exigibles, existiendo un vínculo de obediencia. Esta posición recogía la visión existente al momento de dictarse el Código Civil, el que entró en vigencia en una

época en que la economía se caracterizaba por ser agrícola, desintegrada y artesanal. Dicho sea, esta fue la postura claramente adoptada por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia hasta hace menos de treinta años.

Como ya se dijo, esta interpretación de la dependencia al empresario era explicable en una época en el que éste tenía la preparación y los conocimientos apropiados para enseñarles a sus subordinados la forma en que debían realizar su trabajo. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y los cambios en la estructura y organización de las empresas modernas, unido a la creciente necesidad en encargar a profesionales calificados actividades complejas, llevaron a una reformulación de estos conceptos en el mundo. La doctrina y la jurisprudencia chilena, por supuesto, no quedaron fuera de estos cambios y de estas interrogantes; evolución que decisivamente fue respaldada por la amplitud del art. 2320 del Código Civil.

En la actualidad, el criterio más aceptado por la doctrina no consiste en entender que se es dependiente de un empresario en la medida de que exista una subordinación jerárquica a las órdenes que éste le instruya, sino que se será dependiente de otra persona siempre exista otra que intervenga en una determinada *actividad organizadora*.

En este sentido, ZELAYA afirma que actualmente el criterio de la subordinación jerárquica o dependencia estrictamente laboral viene siendo reemplazado –en muchos sectores de la moderna actividad empresarial- por el criterio del control empresarial o poder organizativo del empresario sobre la actividad de sus dependientes o auxiliares. En otras palabras, ya no se hace necesaria la existencia de una relación jurídica estable y definida en virtud de la cual el principal ejerce una autoridad efectiva y real sobre los medios o mecanismos técnicos que debe emplear su dependiente –muchas veces no puede ni es conveniente que lo haga- sino que sólo la posibilidad o facultad potencial de intervenir, de alguna forma, en el resultado final de la obra o encargo encomendado.

Dicho de otro modo, se tiene por empresario, y se será responsable en dicha calidad por los hechos de otra persona, siempre que se controle una organización que se beneficia del trabajo de dichos terceros y de la cual este último forma parte, con prescindencia de que actúen porque se le dio una instrucción de obrar en ese sentido o porque exista un vínculo jurídico de subordinación.

En general, y apartando otras teorías con diferencias menores, son estos dos los rasgos esenciales: (i) Que las gestiones del tercero dependiente redunden en beneficio del interés del empresario; y, (ii) Que el empresario intervenga en las actividades del tercero pues participan de una estructura organizacional de la que este dependiente forma parte, sobre la que tiene una dirección integral. Se pasa así de una “dependencia jerárquica” a una “dependencia funcional”, como enfatiza la doctrina.

Estos nuevos criterios han sido acogidos en diversos fallos de la jurisprudencia nacional, los que se alinean sobre la idea de sancionar a alguien por la responsabilidad civil que le compete como empresario, si es que el autor del daño formaba parte de una organización

que él controla y dirige. De esta manera, se ha resuelto que para que se aplique este estatuto de responsabilidad al empresario no es necesario que medie un contrato de trabajo con el agente material del perjuicio; que es suficiente incluso que el servicio se preste gratuitamente por el dependiente; que un supermercado debe adoptar las medidas de seguridad que los empleados del contratista realizan diariamente en el local donde desarrolla su giro; que un hospital es responsable por las operaciones que especialistas realicen en sus salas; o que basta con que un médico figure en la lista oficial de una Isapre.

Frente a esta amplitud con que es concebida en la actualidad el carácter de empresario y la responsabilidad que puede recaer sobre él por los hechos de los integrantes de su organización, interpretación que se encuentra amparada por el tenor en que están redactadas las disposiciones pertinentes del Código Civil, es conveniente mencionar los principales criterios o índices reconocidos en el Derecho Comparado para identificar esta relación de dependencia: (i) El grado de extensión o control del empresario sobre la actividad del agente del daño; (ii) La mayor o menor diferencia entre el giro o tráfico desarrollado por el empresario con la persona que ocasiona el daño; (iii) El grado o nivel de especialización de la persona contratada en la actividad que realiza; (iv) Saber quién suministró los materiales, los instrumentos y las herramientas de trabajo que fueron utilizados en la generación del daño; (v) Determinar si el lugar donde se realizó el daño era de propiedad del empresario o de la persona contratada; (vi) La duración del trabajo o encargo y la obligación de exclusividad; (vii) La existencia o no de remuneración o pago por la obra o servicios contratados; (viii) El método o sistema de pago de la obra o de los servicios contratados con el agente material del daño; (ix) Si el trabajo o servicio encargado al agente material del daño forma parte del negocio o tráfico ordinario del empresario; (x) Si las partes se denominan a sí mismas empleador y empleado; y, (xi) Si el tercero se ha obligado a un resultado o sólo a unos servicios para con el empresario.

Por otro lado, y congruente con estas ideas, es que tradicionalmente se ha excluido a la subcontratación como un caso idóneo para demandar la responsabilidad civil del empresario, toda vez que el contratista no forma parte de la organización o estructura que dirige el principal, sino que recibe un precio o renta del empresario sobre un producto u obra final determinada, respecto de la cual no tiene la más mínima participación y en la cual el contratista goza de la misma autonomía que tendría de ser haber celebrado el mismo contrato con cualquier otra persona; lo que se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que la legislación laboral establezca. Así se ha fallado.

3.6. Responsabilidad del amo por sus criados o sirvientes

Este caso no está contemplado por el art. 2320, sino que en el art. 2322, que señala que *“los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista”*.

La expresión “amos” y “criados” tiene significación bien precisa en el Código: son éstos los empleados domésticos. Sin embargo, la jurisprudencia ha interpretado el precepto a veces en forma amplia, aplicándolo en forma general a toda clase de obreros e incluso empleados.

Más allá de la formulación del art. 2322, que se refiere a la relación de amos con criados, los arts. 2320 y 2322 presentan ciertas diferencias.

En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacionales han señalado que los arts. 2320 inc. 4 y 2322 contienen supuestos distintos y presentan peculiaridades diversas. Así, por ejemplo, ALESSANDRI respecto del primero fue partidario de una interpretación extensiva, pues el empresario respondería mientras el dependiente esté a su cuidado no sólo de los daños causados “en el ejercicio de sus funciones”, sino también de aquellos causados “con ocasión” e incluso “en abuso de las mismas”.

Por el contrario, respecto del art. 2322, el referido autor fue muy restrictivo, por cuanto -en su opinión- el amo sólo debería responder de los delitos y cuasidelitos que cometan sus criados o sirvientes “en el ejercicio de sus respectivas funciones”. Por ello, el amo no debería responder de los delitos y cuasidelitos cometidos por sus criados sólo “con ocasión de sus funciones”, esto es, aprovechándose de las circunstancias o de la oportunidad que esas funciones le proporciona. Un ejemplo clásico sobre la materia es el del pasajero invitado o transporte benévolo, es decir, cuando el dependiente/conductor del vehículo, sin contar con la autorización del empresario, autoriza que un tercero suba al vehículo y durante su trayecto, por descuido o negligencia en la conducción, causa un accidente con daño para el tercero transportado.

ALESSANDRI agrega que tampoco debería responder de los daños causados en claro abuso de sus funciones, es decir, cuando las ejerce en pugna con los intereses del amo, como si ese mismo chofer, contraviniendo las órdenes del amo, en ausencia de éste o sin su permiso o conocimiento, saca el automóvil del mismo para pasear con unos amigos y atropella a un transeúnte.

Nuestra jurisprudencia, sin embargo, ha señalado todo lo contrario pues ha dicho que el art. 2320 inc. 4 es más limitado, en su esfera de aplicación, pues exige que el daño haya sido causado mientras el aprendiz o dependiente esté bajo el cuidado del empresario, es decir, en condiciones inmediatas de poder impedir el hecho, valiéndose de la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere. En cambio, el art. 2322 establece que el amo responde no sólo cuando el criado o sirviente está en el ejercicio de sus funciones sino también cuando ha causado el daño en el ejercicio impropio de las mismas, si el amo estuvo en situación de preverlo o impedirlo, empleando el cuidado ordinario y su autoridad competente.

Según ABELIUK, el art. 2322 al cambiar la expresión “a su cuidado” por “ejercicio de sus respectivas funciones”, y agregar todavía: “aunque el hecho... no se haya ejecutado a su vista”, es revelador de que el cuidado no comprende esta última situación. En consecuencia, no podría fundarse en el art. 2320 la responsabilidad del empresario por el conductor que trabaja en la calle, cosa que la jurisprudencia siempre ha aceptado. La verdad es que el art. 2322 es más propio para las empresas que el anterior.

Más allá de lo dicho, en nuestra legislación la responsabilidad de todo empleador o patrón es ampliamente aceptada por la doctrina y jurisprudencia, ya sea fundada en el inc. 4 del art. 2320, ya en la regla general que señala este precepto (“toda persona es responsable... del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”), ya en el art. 2322, excediendo con mucho su texto estricto. Ello mientras los dependientes se encuentran en el ejercicio de sus funciones y las realicen del modo que es propio, aun cuando las efectúen fuera del recinto de la empresa, como conductores de vehículos, o reparadores de artefactos a domicilio, etc.

4. EXONERACIÓN DEL TERCERO RESPONSABLE

4.1. Regla general

La responsabilidad del hecho ajeno se funda en la concepción de que ha habido un descuido, una culpa por falta de vigilancia en la persona que tiene autoridad sobre otra, y por ello se presume su responsabilidad, presunción que normalmente es meramente legal.

La regla general la contempla el art. 2320, cuyo inciso final establece “*pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho*”.

La víctima, en consecuencia, no tiene que probarle culpa al tercero civilmente responsable, sino que éste debe acreditar que no la tiene rindiendo la probanza antes transcrita. Y la jurisprudencia ha sido estricta en este sentido, porque exige una imposibilidad total de evitar el hecho para que el responsable pueda eximirse. Se ha resuelto también que es cuestión de hecho determinar si con su autoridad pudo evitarlo.

Tratándose de los amos por hechos de sus criados, la prueba contraria es aún más estricta: consiste en que los criados han ejercido sus funciones de modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente (art. 2322.2).

4.2. Casos de improcedencia de exoneración de responsabilidad

Sin embargo, en ciertos casos la ley niega toda prueba en contrario, convirtiendo la presunción en presunción de derecho. En particular, no se admite la exoneración cuando los hijos menores cometen ilícitos que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que los padres les han dejado adquirir (art. 2321).

ALESSANDRI, en base a lo dispuesto en el art. 2325, agrega que tampoco cabe la exoneración cuando el subordinado obra por orden del civilmente responsable, caso en el

cual el superior es coautor del ilícito y responderá solidariamente junto con el hechor material.

5. ACCION DE REGRESO CONTRA EL SUBORDINADO

Señala el art. 2325 que *“Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que de ellas dependen tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere, y si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía obediencia, y era capaz de delito o cuasidelito, según el artículo 2319”*.

En consecuencia, para que exista el derecho a repetir, deben concurrir las siguientes circunstancias:

(i) *El acto ilícito debe haber sido cometido por una persona capaz.* El guardián del incapaz sólo responde si se le prueba culpa propia. El incapaz no es responsable ante nadie ni tampoco respecto del guardián culpable que por su negligencia se vio obligado a pagar indemnización.

(ii) *El responsable debe haber pagado la indemnización.* En caso contrario no tendría que repetir. El fundamento de esta disposición es evitar el enriquecimiento sin causa del hechor. A la inversa, si se pudiera repetir sin haber pagado habría enriquecimiento injustificado para el tercero responsable.

(iii) *Es preciso que el acto se haya ejecutado sin orden de la persona que pretende repetir.* El autor del hecho ilícito debe obediencia a la persona responsable; es posible, pues, que haya actuado por orden suya, y en tal caso se le niega a ésta la posibilidad de repetir, y

(iv) *El hechor debe tener bienes.* Lo cierto es que este no es un requisito de procedencia de la acción, sino que de su eficacia.

6. RESPONSABILIDAD DEL HECHOR

Por último, cabe indicar que la responsabilidad por el hecho ajeno no excluye la del hechor. No lo ha dicho expresamente la ley, pero deriva de la aplicación de las reglas generales: el hechor ha cometido un acto ilícito, y es plenamente capaz. En consecuencia, queda comprendido en las disposiciones generales de los arts. 2314 y 2329, no habiendo precepto legal que la excluya. Antes, por el contrario, el 2322.2 señala que si el amo se exonera de responsabilidad por los hechos de sus criados “toda la responsabilidad” recae sobre éstos.

En consecuencia, la responsabilidad del guardián sólo extingue la del hechor cuando aquél paga la indemnización.

La víctima si no la ha percibido del responsable, podrá entonces cobrarla al hechor, pero lo normal será lo contrario, ya que uno de los fundamentos de la responsabilidad por el hecho ajeno es la probable insolvencia del autor.

Según ABELIUK la víctima no puede, eso sí, demandar a ambos, porque la ley no establece solidaridad; podría sí hacerlo pero en forma subsidiaria, porque lo que no puede es pretender cobrar a ambos. Por su parte, ALESSANDRI sostiene que la víctima tiene dos responsables a cada uno de los cuales podrá demandar separada o conjuntamente la reparación total del daño, pero esto no significa que haya entre ellos solidaridad; según el art. 2317 ésta existe entre los coautores de un mismo delito o cuasidelito. El responsable civilmente y el autor directo del daño no tienen este carácter, pues el delito o cuasidelito ha sido cometido por una sola persona. El civilmente responsable es una especie de caución o de deudor subsidiario, pero a quien se puede demandar desde luego sin necesidad de demandar antes al autor directo del daño. En cambio BARROS sostiene que hay solidaridad. Según CORRAL no se trata propiamente de una obligación solidaria, aunque en la práctica pueda funcionar como tal en un aspecto: la opción para demandar el total indistintamente al responsable directo o al tercero civilmente responsable.

Según parte de la jurisprudencia, cuando se demanda con fundamento en el art. 2320 sí puede demandar primero a uno de los responsables; y en el evento de no tener éxito, hacerlo con el otro; pero en caso alguno a ambos conjuntamente por el total de la obligación; porque ello imputa ejercer una facultad inherente a la solidaridad pasiva, que en la presente situación el precepto mencionado no autoriza. Con todo, en otros fallos los tribunales han aceptado que se trata de una obligación solidaria entre el empresario y el dependiente.

Tampoco podría acumular las responsabilidades por el hecho ajeno provenientes de diferentes causales, como si, por ejemplo, el hijo menor que vive con su padre comete un hecho ilícito mientras está en el colegio. La responsabilidad por el hecho ajeno corresponde en tal caso al jefe del colegio, porque él tiene a su cuidado al menor, y no al padre.

Finalmente, no hay tampoco inconveniente para que la víctima demande al responsable de acuerdo al derecho común, por ejemplo, por no reunirse los requisitos legales, como si el hijo menor no vive con su padre y el hecho ilícito no deriva de su mala educación o hábitos viciosos, pero en tal caso deberá probarle su culpa al padre, según las reglas generales.

IV.

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS

1. NOCIONES GENERALES

A diferencia de la responsabilidad por el hecho propio y por el hecho ajeno, en que existen presunciones generales de culpabilidad (artículos 2329 y 2320 del Código Civil, respectivamente), en materia de responsabilidad por el hecho de las cosas la ley sólo contempla presunciones específicas, referidas a los daños causados por el hecho de animales, por la ruina de edificios y, por la caída de objetos desde la parte superior de un edificio.

El Código Civil se aparta en materia de responsabilidad por el hecho de las cosas del código francés, cuyo artículo 1384 dispone, en general, que se responde por el hecho de las cosas que se tienen bajo custodia.

A falta de una presunción genérica de culpabilidad por el hecho de las cosas, y fuera de los casos específicos, en el derecho chileno sólo es posible acudir a la presunción general de culpabilidad por el hecho propio del artículo 2329 del Código Civil, siempre que se trate de daños que razonablemente y de acuerdo a la experiencia puedan atribuirse a negligencia.

Conviene tener presente que tras la presunción de culpabilidad por el hecho de las cosas existe una presunción de culpabilidad del hecho del dueño o custodio de la cosa, de modo que éste podrá exculparse probando su propia diligencia.

2. DAÑOS CAUSADOS POR UN ANIMAL

En relación a la responsabilidad civil por daños causados por animales, dividiremos el análisis: primeramente se analizará la reglamentación contenida en el Código Civil, para luego referirnos a la regulación contenida en la Ley N° 21.020, publicada el 2 de agosto de 2017 con el título “Sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía” (bautizada por los medios como “Ley Cholito”), reproduciendo al efecto lo señalado por CORRAL.

2.1. Regulación del Código Civil

(i) Presunción de culpa por el hecho de un animal

El artículo 2326 del Código Civil presume la culpabilidad del dueño por los daños causados por un animal, aún después que se haya soltado o extraviado. El dueño podrá exculparse probando que el daño, la soltura o el extravío del animal no se deben a su culpa ni a la del dependiente encargado de guarda o cuidado. En este último caso, a la presunción de culpabilidad por el hecho del animal se agrega una presunción de culpabilidad por el hecho del dependiente.

La misma presunción se aplica a toda persona que se sirve de un animal ajeno, quien será responsable en los mismos términos que el dueño frente a terceros, pero tendrá acción de reembolso contra este último, si el daño causado se debió a un vicio del animal que el dueño debió conocer e informarle. La víctima del daño podrá dirigir su acción de responsabilidad tanto contra el dueño como contra aquel que se sirve del animal, pues frente a ella ambos responden solidariamente, sin perjuicio de la acción de reembolso que pueda corresponder.

(ii) Responsabilidad estricta por el hecho de animales fieros

Tratándose de animales fieros, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, el artículo 2327 del Código Civil establece una regla de responsabilidad estricta de la persona *que lo tenga*, por los daños que dicho animal ocasione. La responsabilidad se funda en la tenencia física y no en el dominio. La víctima únicamente deberá probar que se trata de un animal fiero que no presta utilidad para la guarda o servicio de un predio y que el demandado lo tenía, para que éste sea obligado a indemnizar los daños que haya provocado, resultando inadmisibles las excusas de actuar diligente.

2.2. Regulación contenida en la Ley N° 21.020

La Ley N° 21.020 emplea la palabra “responsabilidad” en dos sentidos: uno amplio y otro específico. En un *sentido amplio* alude a todos los deberes que asume una persona cuando decide aceptar o mantener una mascota o animal de compañía, a saber, obligación de registrar al animal cuando corresponda, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle cuidados veterinarios, respetar las normas de salud y seguridad pública y “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la mascota o animal de compañía cause daños a la persona o propiedad de otro” (art. 2 N° 7). La responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad en sentido *específico*, se da sólo en este último aspecto, es decir, cuando surge un deber de reparar el daño que el animal causa a una persona determinada. Este aspecto, aunque sea considerado sólo un elemento integrante de la responsabilidad en la tenencia de mascotas, parece haberse sido importante en la intención del legislador, al menos así se aprecia cuando se dispone, en el art. 1º, que uno de los

cuatro objetivos de este cuerpo normativo es “4) Regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía”.

Esta idea pareciera confirmarse cuando se observa que todo el título V, con artículos que van del 10 al 14, es denominado “de la responsabilidad en la tenencia de mascotas o animales de compañía”. Sin embargo, al leer los preceptos se ve que se mezclan preceptos de la responsabilidad amplia por tenencia de mascotas con unas pocas reglas de responsabilidad civil (el inciso 1º del art. 10, y los dos incisos del art. 13).

La norma base de la Ley N° 21.020, en lo que a la responsabilidad civil se refiere, es su art. 13, cuyo inciso primero señala: “Todo responsable de un animal regulado en esta ley responderá siempre civilmente de los daños que se causen por acción del animal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda”.

De acuerdo a la Ley N° 21.020, serán legitimados pasivos de la acción responsabilidad, en primer término, el dueño o poseedor del animal; y tendrá responsabilidad subsidiaria la persona que tenga a su cuidado el animal al momento de los daños, aunque no sea dueño o poseedor. La ley agrega que también será responsable (entendemos que de manera principal, y no subsidiaria) el organizador de espectáculos o exhibiciones de animales.

En efecto, al aludir el art. 13 a “todo responsable”, la norma se refiere al dueño o poseedor, ya que el inciso 1º del art. 10 dispone que “será responsable de las mascotas o animales de compañía su dueño o poseedor”.

Pero a continuación hay que señalar que también asume responsabilidad civil la persona que tenga a su cuidado el animal al momento de los daños, aunque no sea dueño o poseedor, siendo esta responsabilidad subsidiaria, es decir, sólo se hace efectiva en la medida en que no se pueda obtener la reparación del daño del principalmente responsable (dueño o poseedor). Nos parece que esto quiere decir la segunda parte del inciso 1º del art. 10: “Sin perjuicio de lo anterior, quien tenga un animal bajo su cuidado responderá como fiador de los daños producidos por éste, en los términos establecidos en el Título XXXVI del Libro Cuarto del Código Civil”. El título al que se remite la norma es el que regula el contrato de fianza (arts. 2335 y ss.). Se aplicará entonces a este cuidador no dueño el estatuto propio de la fianza, y gozará, por tanto, de un beneficio de excusión para que se demande en primer lugar al dueño o poseedor.

Sin embargo, el art. 27, referido al organizador de espectáculos o exhibiciones de animales, contiene una contra excepción a la regla anterior, ya que su inciso 2º dispone que este “será responsable de los daños que causen dichos animales a las personas, a la propiedad o al medio ambiente, conforme a las reglas señaladas en el artículo 13”, sin que se contenga una alusión al inciso primero del art. 10. Nuestra interpretación es que, al organizador, aunque sea un mero tenedor de los animales y pese a tenerlos bajo su cuidado, no se aplica la responsabilidad subsidiaria o de fiador que le correspondería si se siguiera el criterio del art. 10. Por ello, habrá de responder de manera principal, aunque no sea dueño. Se mantiene la duda de si el dueño sigue respondiendo, de manera concurrente con el organizador, o si la responsabilidad del organizador sustituye la del propietario.

Cabe observar que la Ley N° 21.020 dispone en su art. 13 que el dueño o poseedor “responderá *siempre* civilmente de los daños que se causen por acción del animal”. La expresión “siempre” podría dar a entender que se quiso establecer una responsabilidad

estricta u objetiva. Es decir, que, tratándose de mascotas reguladas por esta ley, la responsabilidad surgiría “siempre”, haya o no culpa. No se aplicaría así el art. 2326 del Código Civil que permite excusarse probando ausencia de culpa. Esta interpretación podría reforzarse con el inciso segundo que dispone como causal de exoneración de responsabilidad: “... en el caso de que un ejemplar canino causare lesiones graves o diere muerte al que se encontrare en la situación descrita y sancionada por el artículo 144 del Código Penal, así como al que se introdujere en un domicilio, residencia o morada sin autorización de los moradores ni justificación alguna o con el propósito de cometer delito”, en la medida en que se pretenda que no serían procedentes otras formas de exoneración.

Sin embargo, si se estudia la tramitación de la ley no se logra obtener una respuesta categórica a esta cuestión.

La moción parlamentaria inicial señalaba claramente: “Todo dueño, poseedor o tenedor de un animal potencialmente peligroso será responsable civilmente, de manera objetiva, de los daños que se causen por acción del animal” (art. 4). Pero durante el estudio en el Senado se prefirió el criterio de remitirse a las normas del Código Civil: “Todo responsable de un animal en los términos de esta ley deberá responder civilmente de los daños causados por éste, conforme lo establecen los artículos 2326 y 2327 del Código Civil” (art. 9). Sin embargo, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados sustituyó esta norma por la que en definitiva se convertiría en ley, es decir, la que dispone que se responderá “siempre” civilmente.

Si uno busca alguna explicación sobre la razón del cambio permanecerá perplejo. En el informe de la Comisión de Salud de la Cámara (1º de octubre de 2013) sólo se da noticia de que la redacción fue propuesta en indicación de los diputados Accorsi, Castro, Monsalve, Nuñez, Rubilar, Saa, Silber y Torres, y que la Comisión la aprobó por unanimidad. Nada hay en el informe que indique qué intención tuvieron los legisladores para modificar el texto que se remitía al Código Civil ni tampoco por qué no se volvió al precepto de la moción original.

A falta de una intención clara deducida del establecimiento de la ley, no parece que la expresión “siempre” y la mención de una causal de exoneración especial sean suficientes para entender que se ha tratado de introducir un supuesto de responsabilidad objetiva o estricta. A esto, cabe añadir que, si así fuera, el art. 6 perdería todo sentido, al disponer que la mascota calificada de animal “potencialmente peligroso” será considerado “un animal fiero para todos los efectos legales”. Pese a la generalidad de esta última expresión, lo cierto es que el principal efecto, si no el único, es que se aplicará a los daños causados por estos animales la responsabilidad estricta que el art. 2327 del Código Civil consagra justamente respecto de un “animal fiero”. Como podrá comprenderse, si el art. 13 impusiera esta misma forma de responsabilidad, la referencia implícita del art. 6 al art. 2327 del Código Civil sería superflua.

Por otro lado, el art. 2 N° 7 de la ley, al definir lo que es la “tenencia responsable” señala que incluye “la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que la mascota o animal de compañía cause daños a la persona o propiedad de otro”. Esto revela que el legislador pensó que la responsabilidad por daños debía provenir de un

incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar el daño, lo que implica falta del cuidado debido, es decir, culpa. Por cierto, en caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en la ley que genere daños a terceros se producirá responsabilidad infraccional, conforme al art. 30, y en dicho proceso ante el Juez de Policía Local podrá la víctima ejercer su acción de responsabilidad civil.

En suma, puede observarse que esta regulación especial, en vez de reforzar la responsabilidad del dueño o tenedor de un animal establecida en el Código Civil, más bien la ha atenuado. Sólo respecto de las mascotas que sean calificadas como animales potencialmente peligrosos podrá aplicarse la responsabilidad estricta sin culpa del animal fiero, pero siempre que se acredite que la mascota no reportaba utilidad para la guarda o servicio de un predio. Respecto de las demás mascotas o animales de compañía deberá probarse que el dueño o poseedor no adoptó las medidas necesarias para evitar el daño causado por el animal, por aplicación preferente de los arts. 2 letra N° 7 y 13 de la ley N° 21.020, por sobre el art. 2326 del Código Civil.

Si el daño es causado por un animal que no puede calificarse como mascota o animal de compañía, podrá aplicarse la responsabilidad por culpa presunta prevista en el referido art. 2326 del Código Civil. Por ello tendrá importancia determinar si un animal puede o no ser considerado mascota, y adquiere relevancia la definición que encontramos en el art. 2 N° 1 de la ley, según la cual son mascotas o animales de compañía los “animales domésticos, cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad”. Un análisis de la definición podría ser útil, pero este comentario ya se ha extendido en demasía, por lo que conviene dejar el punto para otra oportunidad.

3. DAÑOS CAUSADOS POR LA RUINA DE UN EDIFICIO

Las expresiones “edificio” y “ruina” son utilizadas en sentido amplio; la primera comprende toda construcción que adhiere al suelo en forma permanente, y la ruina no implica necesariamente la íntegra destrucción de la obra; la hay cuando una parte cualquiera del edificio, adherida al mismo, sufre un deterioro que causa daño a terceros

En esta materia existe un concurso de disposiciones legales aplicables. Al efecto es necesario distinguir entre la acciones preventivas y las acciones indemnizatorias.

3.1. Acciones preventivas

El Código Civil concede la acción posesoria especial de querrela de obra ruinosa, tratada en los artículos 932 al 935; y la acción general de prevención por daño contingente, de los artículos 2333 y 2334.

3.2. Acciones indemnizatorias

El artículo 934 del Código Civil dispone: *“Si notificada la querella posesoria de obra ruinosa cayere el edificio por efecto de su mala condición, se indemnizará de todo perjuicio a los vecinos; pero si cayere por caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto, no habrá lugar a indemnización; a menos de probarse que el caso fortuito, sin el mal estado del edificio, no lo hubiera derribado. No habrá lugar a indemnización, si no hubiere precedido notificación de la querella”.*

A su vez, quienes no hayan ejercido la acción del artículo 934 tendrán una acción indemnizatoria conforme a las reglas de los artículos 2323 y 2324 del mismo código. De acuerdo al artículo 2323, la responsabilidad recae sobre **el dueño del edificio** si la ruina se produce por haber omitido las reparaciones necesarias, o haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. Por consiguiente el enunciado de esta norma no establece una presunción de culpabilidad, pues exige que el dueño haya actuado con culpa, que debe ser probada. Con todo, ha sido interpretada por la doctrina y la jurisprudencia como una presunción de culpabilidad, de modo que corresponde al dueño probar su diligencia o la ocurrencia de caso fortuito.

Si el **edificio pertenece proindiviso a dos o más personas**, la indemnización se divide entre los propietarios a prorrata de sus cuotas de dominio (artículo 2323.2).

La norma del artículo 2323 establece una excepción a la regla de solidaridad de los corresponsables de un hecho que causa daño (artículo 2317): si los propietarios son dos o más se divide entre ellos la indemnización a prorrata de sus cuotas de dominio.

3.3. Daños provenientes de vicios de construcción

El art. 2324 establece que si el daño causado por la ruina de un edificio proviniera de un vicio de construcción, tendrá lugar la responsabilidad prescrita en la regla 3ª del artículo 2003, relativo al contrato de construcción de obra.

De este modo, en sede de responsabilidad extracontractual se hace una referencia a la regla que establece la responsabilidad contractual del constructor de una obra material respecto del dueño.

Así, la responsabilidad del constructor es idéntica tanto respecto del dueño como de terceros que sean afectados por la ruina, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

- (i) Que la ruina total o parcial del edificio ocurra dentro de los 5 años subsiguientes a la entrega, y
- (ii) Que ella se deba: a) a vicios de la construcción; b) a vicios del suelo que el empresario o las personas empleadas por él han debido conocer en razón de su

oficio; c) a vicio de los materiales suministrados por el empresario, o d) a vicio de los materiales suministrados por el dueño, siempre que sean de aquellos que el empresario por su oficio ha debido conocer o conociéndolos no dio aviso oportuno.

4. DAÑOS CAUSADOS POR UNA COSA QUE CAE O SE ARROJA

El Código Civil otorga, también en esta materia, una acción preventiva y otra reparatoria.

4.1. Acción preventiva

Se contempla una *acción pública* para que se remuevan de la parte superior de un edificio u otro paraje elevado objetos que amenacen caída y daño. La acción es análoga a la querrela posesoria de denuncia de obra ruinoso, pero se dirige no sólo contra el dueño, sino, indistintamente, contra éste o contra el arrendatario o la persona a quién pertenezca la cosa o se sirva de ella (artículo 2328.2).

4.2. Acción indemnizatoria

El mismo artículo 2328.1 establece una presunción de culpabilidad en caso de daños causados por la cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, respecto de todas las personas que habitan la misma parte de aquel. Si los responsables son varios, la indemnización se dividirá entre todos ellos, lo que constituye una nueva excepción al principio de la solidaridad establecido en el artículo 2317 del Código Civil.

La exculpación exige la prueba de que la caída del objeto se debe a culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso sólo ésta será responsable.

V.

RESPONSABILIDAD OBJETIVA

1. NOCIONES GENERALES

Como se indicó en la parte introductoria, a diferencia del modelo general de responsabilidad por culpa o negligencia, la responsabilidad estricta u objetiva tiene como antecedente el riesgo generado por una determinada conducta y no la negligencia, de modo que es indiferente el juicio de valor respecto de la conducta del autor del daño.

En este tipo de responsabilidad, la obligación de indemnizar es impuesta sin necesidad de calificar la acción, bastando que el daño se produzca en el ejercicio de una actividad considerada riesgosa. En términos generales, se exige que el hecho se verifique dentro del ámbito de la actividad sujeta al régimen de responsabilidad estricta y que exista una relación de causalidad entre el hecho y el daño, prescindiendo del juicio de negligencia propio del régimen de responsabilidad por culpa.

En el plano dogmático, se comenzó a contraponer a una responsabilidad objetiva indiscriminada que se fundaba sólo en la causalidad material entre el agente y el daño, diferentes tipos de responsabilidad sin culpa pero atribuibles a otros factores de imputación diversos del mero nexo causal. El más recurrido de todos ello fue el concepto de riesgo, en sus dos versiones: “*riesgo provecho*” (el que realiza una actividad riesgosa de la cual obtiene beneficios económicos, debe responder por los perjuicios que se causen en ella), y “*riesgo creado*” (el que dirige una actividad que crea riesgos en su propio interés, sea o no pecuniario, debe responder de los daños causados). De allí que muchas veces se usa como sinónimo el concepto de responsabilidad objetiva y el concepto de responsabilidad por riesgo.

La doctrina objetiva también ha recibido severas críticas, que importan otras tantas defensas de la doctrina clásica.

Se destaca, en primer lugar, que es peligrosa: si bien, por una parte, ampara a la víctima frente al daño que se le ha ocasionado facilitándole el cobro de la indemnización, por otro lado fomenta la existencia de nuevas víctimas, porque si de todos modos habrá que reparar, puede introducirse en la conciencia general la idea de que ante el Derecho da igual actuar con diligencia o sin ella, ya que siempre se responderá del daño que pueda llegarse a ocasionar. Para defenderse de esta posibilidad se contratarán seguros de riesgos a terceros, todo lo cual puede conducir a un aumento de los hechos ilícitos.

Enseguida, se señala que el subjetivismo informa todo el Derecho Civil, que no puede dejar de considerar a las personas para adoptar un criterio meramente material del efecto producido. Hay numerosas instituciones de desarrollo reciente impregnadas del mayor subjetivismo: abuso del derecho, causa ilícita, etc.

Finalmente, referido al problema de la víctima y del autor, se señala que no es equitativo que siempre la primera resulte indemne, pues debe mirarse a ambas partes y no sancionar a quien nada ha puesto de su parte para que el accidente ocurra.

La responsabilidad estricta es un **régimen especial y como tal de derecho estricto**, que opera sólo respecto de ciertos ámbitos de conducta o de tipos de riesgos previamente definidos por el legislador. En consecuencia, su fuente es la ley.

2. REGÍMENES LEGALES DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA

Existen varios ejemplos en la legislación chilena en los cuales claramente se ha aceptado la responsabilidad sin culpa. La mayor parte de ellos puede justificarse en la teoría del riesgo-provecho, o en la de riesgo creado.

Casos representativos de responsabilidad estricta en el ordenamiento jurídico nacional son los siguientes:

2.1. Responsabilidad por daños causados por animales fieros

El artículo 2327 del Código Civil establece una regla de responsabilidad estricta bajo la forma de una presunción de derecho, aplicable a todo aquel que tenga un animal fiero de que no se reporte utilidad para la guarda o servicio de un predio, por los daños que este haya ocasionado.

2.2. Responsabilidad por daños ocasionados por las cosas que se arrojan o caen desde la parte superior de un edificio

Según lo dispuesto en el artículo 2328 del Código Civil, el daño es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. Como se advierte, en el primer caso se trata de responsabilidad sin culpa o estricta, que se distribuye entre todos quienes pudieron provocar el daño.

2.3. Responsabilidad por accidentes del trabajo

Esta materia está regulada en la Ley N° 16.744 sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en ella coexiste un principio de responsabilidad estricta del empleador con un sistema de seguro obligatorio.

En efecto, la ley define el accidente del trabajo como toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte, incluso por accidentes ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar

de trabajo, exceptuando únicamente los accidentes debidos a fuerza mayor extraña o que no tenga relación alguna con el trabajo, y aquellos producidos intencionalmente por la víctima. Estos accidentes están cubiertos por un seguro obligatorio financiado principalmente por aportes del empleador, y contempla prestaciones por incapacidad temporal, invalidez parcial o total y muerte.

La negligencia inexcusable del trabajador no excluye la responsabilidad del empleador, y sólo da lugar a la aplicación de una multa (artículo 70.1).

Si el accidente se debe a culpa o dolo del empleador, la víctima y las demás personas a quienes el accidente causa daño tienen acción para reclamar de éste una indemnización complementaria por todo perjuicio no cubierto por el sistema de seguro obligatorio, inclusive el daño moral; además, el organismo administrador del seguro tendrá acción contra el empleador para obtener el reembolso de lo pagado (artículo 69).

2.4. Responsabilidad por daños ocasionados por el conductor de un vehículo motorizado

La regla general en esta materia está contenida en el artículo 170 de la Ley N° 18.290, Ley del Tránsito, que establece la responsabilidad por culpa del conductor del vehículo. El sistema está complementado por un listado de presunciones de responsabilidad, contenidas en el artículo 172, y que en rigor corresponden a hipótesis de culpa infraccional, que sólo admiten como excusa la fuerza mayor.

Sin perjuicio de lo anterior, la ley contempla dos instrumentos adicionales para proteger a las víctimas de accidentes:

(a) Responsabilidad estricta del propietario del vehículo por los daños ocasionados por el conductor (artículo 174). Esta regla contiene una hipótesis de responsabilidad estricta por el hecho ajeno, en virtud de la cual el propietario vehículo responde solidariamente con el conductor, y sólo puede eximirse probando que el vehículo le fue tomado sin su conocimiento o sin su autorización expresa o tácita, circunstancias que equivalen a casos de fuerza mayor.

(b) Un sistema de seguro obligatorio análogo al existente en materia de accidentes del trabajo, que coexiste con el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados, y con el seguro de accidentes de pasajeros de la locomoción colectiva.

2.5. Responsabilidad del explotador de aeronaves por daños ocasionados en caso de accidente aéreo

Está tratada en el Código Aeronáutico, artículos 142 y siguientes. Respecto del empresario aeronáutico, la ley establece dos ámbitos de responsabilidad sin culpa:

(a) El primero de carácter *contractual*, por los daños ocasionados a los pasajeros y la carga, con un límite de 4.000 U.F. por cada víctima, en caso de muerte o lesión, y de 1 U.F. por kilogramo de peso bruto de la carga. Se trata de una obligación de garantía, que opera por la sola ocurrencia del daño (artículos 144 y 148).

(b) El segundo de carácter *extracontractual*, respecto de los daños ocasionados a terceros en la superficie, a consecuencia de la acción de una aeronave en vuelo, o a la caída de todo o parte de una aeronave. Esta responsabilidad es de carácter estricto, pues sólo admite como excusas las causales de fuerza mayor definidas en la misma ley. Con todo, el monto de las indemnizaciones está sujeto a un límite determinado según el peso de la aeronave. Sobre dicho límite se aplican las reglas comunes de responsabilidad por culpa (artículos 155 y ss.).

2.6. Responsabilidad por daños ocasionados por aplicación de plaguicidas

A la responsabilidad por esta especie de daños se refiere el Decreto Ley N° 3.557, artículo 36. Según esta disposición, “si al aplicar plaguicidas se causaren daños a terceros, ya sea en forma accidental o como consecuencia inevitable de la aplicación, éstos podrán demandar judicialmente la indemnización de perjuicios correspondiente dentro del plazo de un año contado desde que se detecten los daños. En todo caso, no podrán ejercerse estas acciones una vez que hayan transcurrido dos años desde la aplicación del plaguicida”.

Quien utiliza un plaguicida está sujeto a responsabilidad estricta por todos los daños que se sigan de su aplicación, aunque sean causados “en forma accidental”, es decir, sin culpa. Esta responsabilidad alcanza incluso al Servicio Agrícola y Ganadero por los daños ocasionados en la erradicación de plagas.

2.7. Daños ocasionados por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar

Su fuente legal es el Decreto Ley N° 2.222, que en el artículo 144 establece una regla de responsabilidad estricta por el sólo hecho del derrame. Según esta disposición, el dueño, armador u operador a cualquier título de la nave o artefacto naval que produzca el derrame o la descarga responden solidariamente por los daños que se causen.

Por otra parte, la excusa de fuerza mayor se encuentra limitada a los casos específicos que señala la propia ley, y son los siguientes: acto de guerra, hostilidades, guerra civil o

insurrección, fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible; y, acción u omisión dolosa o culpable de un tercero extraño al dueño, armador u operador a cualquier título del barco o artefacto naval. (artículo 144 letras a y b).

El monto de la indemnización se limita al equivalente a 2.000 francos por tonelada de registro de la nave o artefacto naval causante de los perjuicios, con un monto máximo de 210 millones de francos. Si el siniestro ha sido causado por falta o culpa del propietario, naviero u operador, la indemnización es ilimitada (artículo 145).

Estas reglas de responsabilidad estricta se complementan con un sistema de seguro obligatorio exigible a toda nave o artefacto naval que mida más de 3.000 toneladas (artículo 146).

2.8. Responsabilidad por daños nucleares

Esta materia está regulada en la Ley N° 18.302, Ley de Seguridad Nuclear, artículos 49 y siguientes. En su artículo 49 señala expresamente que “la responsabilidad civil por daños nucleares será objetiva y estará limitada en la forma que establece esta ley”. Esta responsabilidad se aplica a las personas que tengan la calidad de explotador de una instalación, planta, centro, laboratorio o establecimiento nuclear, por los daños ocasionados por un accidente nuclear que ocurra en ellos.

La responsabilidad del explotador alcanza incluso a los daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que el accidente nuclear se deba “directamente a hostilidades de conflicto armado exterior, insurrección o guerra civil” (artículo 56).

También en este caso se ha establecido un límite máximo a la responsabilidad, fijado en el equivalente a 75 millones de dólares, que se reajusta automáticamente en la forma que señala la ley, entre la fecha de su dictación y la fecha del accidente nuclear (artículo 60). En lo que respecta a los daños a las personas, la indemnización debe ser a lo menos el doble de la cantidad que correspondiere por aplicación de las tablas del seguro de accidentes del trabajo (artículo 61).

2.9. Responsabilidad por daños causados en ejercicio de la facultad de catar y cavar

El artículo 14 del Código de Minería reconoce a toda persona la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio (salvo las que queden comprendidas dentro de los límites de una concesión minera ajena) con el objeto de buscar sustancias minerales. Como correlato de esta facultad, concebida en términos amplios, la ley establece una regla de responsabilidad estricta respecto de los daños que se causen en su ejercicio. A la misma regla queda sujeto el titular de una concesión de exploración, respecto de los daños que ocasione en las labores propias de dicha concesión (artículo 113).

3. OBJETIVACION DE SECTORES DE RESPONSABILIDAD. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Por último, es necesario destacar que hay casos en los que la responsabilidad, si bien tiende a la objetivación, supone todavía alguna relación con el concepto de culpabilidad.

Es lo que sucede con la responsabilidad del Estado, respecto de lo cual cabe distinguir entre la responsabilidad de la Administración del Estado, de la responsabilidad por error judicial y de la responsabilidad por actos legislativos.

Históricamente, el derecho público ha concebido al menos cuatro regímenes de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado:

- (a) Según la doctrina de la inmunidad de jurisdicción, el Estado no es responsable. Esta doctrina tiene sus orígenes remotos en la idea de que el soberano establece el derecho pero no está sujeto a él. En la actualidad, resulta inaplicable por ser contraria a las normas constitucionales que rigen la materia (artículos 6, 7, 19 N° 7 letra i), y 38 de la Constitución Política).
- (b) Un segundo sistema distingue entre los *actos de autoridad*, en los que se manifiesta el poder soberano del Estado y que en consecuencia, según la primera doctrina, no le generan responsabilidad, y los *actos de gestión*, que quedan sujetos al derecho común.
- (c) Un tercer modelo de responsabilidad asume que el Estado es responsable por los actos de sus órganos o funcionarios, a condición de que éstos hayan actuado en infracción de un deber de cuidado (culpa en sentido civil), o se haya incurrido en una *falta de servicio* (defecto en el ejercicio de una función pública).
- (d) Finalmente, el Estado puede responder según un sistema de responsabilidad estricta basado exclusivamente en la causalidad entre la acción u omisión del órgano y el daño ocasionado al derecho de una persona.

Si bien el estudio acabado de la responsabilidad del Estado corresponde al Derecho Administrativo, siguiendo a BARROS se realizará una apretada síntesis sobre esta materia.

3.1. Responsabilidad de la Administración del Estado y de las Municipalidades

Una clara objetivación se da en la responsabilidad de la Administración del Estado, las municipalidades y organismos públicos, en particular por los daños provenientes por *falta de servicio*, cuyo fundamento normativo se encuentra en la Constitución Política (arts. 6, 7, 38.2 y 19 N° 7 letra i), en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (art. 4 y 42) y, en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (art. 141).

Sobre la materia es posible señalar lo siguiente:

- (a) En primer término, de los principios y normas citados aparece con claridad que se excluye el sistema de inmunidad de jurisdicción, cuyo efecto es la irresponsabilidad patrimonial del Estado.

(b) De acuerdo a esas mismas normas, el Estado está sujeto a un régimen de responsabilidad estricta por los hechos de sus órganos y funcionarios, cometidos en el ejercicio de sus funciones, de los que responde como hechos propios. En otros términos, se trata de una especie de responsabilidad vicaria, en virtud de la cual el Estado y las municipalidades responden personal y directamente, sin consideración al cuidado aplicado respecto de la actuación de los funcionarios.

(c) El Estado responde además por la culpa infraccional de sus órganos, cuando éstos actúan en contravención a la ley o a la Constitución. Según las reglas generales, la infracción a una norma obligatoria acarrea responsabilidad cuando el daño es objetivamente atribuible a esa infracción.

(d) El Estado responde por la *falta de servicio* en que incurran los órganos de la administración.

El concepto tiene una connotación objetiva, análoga a la que ha adoptado el concepto civil de negligencia. Tanto en la responsabilidad por culpa, como por *falta de servicio* no basta la mera causalidad material para que haya lugar a la indemnización del daño. Se requiere además un juicio normativo, que en la culpa civil reside objetivamente en la conducta efectiva, que es comparada con el estándar de conducta debida; y en la *falta de servicio*, recae en el estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública. En todo caso, tanto la responsabilidad por culpa, como la por *falta de servicio*, suponen un juicio objetivo de reproche, que, respectivamente, recae en el deber de cuidado (culpa) o en el correcto ejercicio de la función.

(e) Cierta doctrina, apoyándose en lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política y en el artículo 4º de la Ley de Bases, ha sostenido que la responsabilidad del Estado sería de carácter estricto en sentido propio, esto es, que basta la existencia de un daño que pueda ser atribuido causalmente a la actividad del Estado, para que éste responda. Según esta doctrina, el único requisito adicional a la causalidad es que se trate de un daño antijurídico, esto es, que el sujeto administrado no tenga la obligación de soportar.

Esta doctrina conduce a que el Estado y las municipalidades devengan en un vasto sistema de seguridad social respecto de todos los daños en que haya intervenido causalmente un agente público, lo que no es compartido por buena parte de la doctrina.

3.2. Responsabilidad por error judicial

Este ámbito de la responsabilidad del Estado tiene un reconocimiento expreso en el artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política que señala: “Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente

errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”.

Sin embargo, la jurisprudencia ha sido extremadamente exigente para dar por establecidos los supuestos de dicha responsabilidad, exigiendo en la práctica, aunque no de modo explícito, que se haya incurrido en culpa grave.

3.3. Responsabilidad por actos legislativos

Bajo el principio de la soberanía política del legislador, la responsabilidad del Estado en este ámbito resulta inimaginable. Sin embargo, ese principio está en colisión con el de la supremacía del derecho, propio del constitucionalismo.

La propia Constitución se encarga de establecer los procedimientos para velar por la supremacía de sus preceptos, por medio del control preventivo de carácter general, que se aplica antes de la entrada en vigencia de la ley, a cargo del Tribunal Constitucional y del control correctivo de carácter particular, a cargo hoy del mismo Tribunal.

Los límites que el derecho impone al legislador están circunscritos a estos instrumentos procesales que persiguen impedir la vigencia o la aplicación de una ley que vulnere derechos garantidos por la Constitución. Fuera de este ámbito, la cuestión de la responsabilidad del Estado se presenta por ahora bastante más imprecisa. Con razón, el derecho comparado se muestra en general tímido en reconocer responsabilidad por decisiones legislativas que no adolecen de inconstitucionalidad. Nada obsta, sin embargo, para que la obligación reparatoria que pesa sobre el Estado administrador por la imposición de cargas graves y especiales (por lícitas que sean desde el punto de vista de la eficacia normativa de la disposición), se extienda en casos excepcionales a la ley, al menos cuando de las circunstancias puede inferirse que el legislador no tuvo en vista privar a los afectados de esa reparación.

VI.

RESPONSABILIDAD PREVENTIVA

1. CARACTERIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PREVENTIVA

El sistema prototípico de responsabilidad es aquel cuya finalidad y fundamento consiste en la reparación de daños que ya han ocurrido. Es el daño que ya se ha causado en realidad el que debe ser reparado o compensado, y para ello surge el mecanismo de transferencia del costo de daño en que consiste la responsabilidad civil. Se trata de una responsabilidad jurídica que mira siempre al pasado: el hecho del autor, la relación de causalidad, el daño producido.

Pero frente a este sistema de responsabilidad surge el problema de que en la mayor parte de los casos la víctima y la sociedad hubieran preferido que el daño no se hubiera producido. La sabiduría popular resume esta preferencia con el dicho “es mejor prevenir que curar”. ¿Es posible que la responsabilidad pueda servir no sólo para reparar, sino para cautelar y prevenir?

Esto, que puede aparecer novedoso, no lo es tanto para el sistema chileno, que reconoce desde sus inicios la posibilidad de articular medidas, sobre la base de la responsabilidad, para evitar daños que amenazan con cierta certidumbre de ocurrencia. En el Código Civil se regula claramente el supuesto de responsabilidad por un daño contingente (aún no ocurrido) que amenace a personas determinadas o indeterminadas por imprudencia o negligencia de alguien (arts. 2333 y 2334). Además, se establece como caso especial la amenaza de caída de una cosa de la parte superior de un edificio (art. 2328.2).

Aunque tratados como acciones posesorias, es indudable que cumplen el mismo rol los llamados interdictos de obra nueva y de obra ruinosa (arts. 930 y ss.) y las medidas que el juez puede adoptar, de oficio o a petición de cualquiera persona, para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra (art. 75).

2. EL DAÑO CONTINGENTE COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PREVENTIVA

2.1. Amenaza y contingencia del daño

El art. 2333 habla en general de “daño contingente”, es decir, que puede suceder o no, sin hacer ninguna distinción.

Sin embargo, no basta que el daño sea meramente hipotético o posible, es necesario que sea más que probable. No basta que haya un mero riesgo de que se produzca el daño o una situación de peligro general.

La amenaza puede provenir tanto de un comportamiento activo como de una omisión. Así se ha establecido para la acción constitucional de protección.

Normalmente, se ha relacionado el concepto de daño contingente con consecuencias materiales, como la caída de un edificio que amenaza ruina o de un árbol mal arraigado, pero el Código no hace ninguna distinción respecto de la naturaleza del perjuicio. Todo daño puede ser objeto de la responsabilidad preventiva.

2.2. Relación de causalidad

La amenaza del daño debe tener como causa un comportamiento descuidado del demandado. Esta vinculación coincidirá normalmente con la relación de causalidad que existiría entre el daño que se produciría y la conducta negligente del responsable. Si esta relación existe (hipotéticamente), debe afirmarse la causalidad entre la amenaza y el hecho activo u omisivo del agente.

2.3. Culpabilidad

El art. 2333 es claro al exigir que de parte del agente exista negligencia, es decir, culpa. La amenaza debe corresponderse con una omisión que al demandado le sea imputable por haber incumplido un deber de cuidado que le inducía a eliminar la amenaza o inminencia del daño.

Lo que se dice de la culpa, con mayor razón se aplicará si el agente no toma las precauciones necesarias con la intención de que el daño sobrevenga, es decir, dolosamente.

3. LEGITIMACIÓN PASIVA

Pasivamente está legitimada toda persona natural o jurídica a la cual le corresponda el deber de suprimir una situación de amenaza o de riesgo inminente de un daño a otro. Por aplicación de las reglas generales, el demandado debe tener capacidad para delinquir. Pero por él pueden responder las personas a cuyo cargo esté, de acuerdo con el art. 2319.

4. LEGITIMACIÓN ACTIVA

(i) **Acción individual**

Si el daño contingente amenaza a personas que están determinadas, sólo a éstas compete la acción: “si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción” (art. 2333).

(ii) **Acción popular**

Si no fuera posible identificar claramente a los afectados por el daño y si más bien este amenaza a cualquier persona indeterminada que se exponga a la situación amenazante, la ley concede acción popular: “Por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas” (art. 2333).

El ejercicio de la acción popular tiene una consecuencia económica: el actor debe ser indemnizado de todas las costas de la acción, además de lo que valga el tiempo y diligencia empleados en ella (art. 2334). Estas sumas las apreciará discrecionalmente el juez, y deberá abonarlas el demandado.

Además, señala el Código que lo anterior es “sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados” (art. 2334).

Se conecta esta norma con la del art. 948, que, tratándose de una querrela posesoria de acción popular, establece una recompensa en favor del actor cuyos límites la norma fija.

5. PRESCRIPCIÓN

No parece que pueda aplicarse a la responsabilidad preventiva la norma del art. 2332, ya que ordena computar la prescripción desde la “perpetración del acto”. Es decir, supone que el daño ya ha sido causado.

Tratándose de daño contingente, debiera aplicarse la norma del art. 950.2, que establece la imprescriptibilidad de las acciones dirigidas a precaver un daño mientras haya justo motivo para temerlo. Es decir, mientras exista amenaza de un daño, con los requisitos que hemos precisado, estará abierta la acción para evitarlo mediante el juicio civil ordinario, posesorio o mediante la acción constitucional de protección.

VI.

ACCIÓN Y JUICIO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRACONTRACTUAL

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Concurriendo los requisitos ya estudiados de la responsabilidad extracontractual nace para el autor de un hecho ilícito la obligación de reparar el daño ocasionado.

Los caracteres más importantes que presenta esta acción son los siguientes:

- a) Es una acción *personal*, pues corresponde ejercerla contra el responsable del daño;
- b) Es siempre *mueble*, pues normalmente persigue el pago de una suma de dinero, y en ciertos casos la ejecución de un hecho. De acuerdo al art. 581 los hechos que se deben se reputan muebles.
- c) Es una acción netamente *patrimonial*, y como consecuencia de esto es renunciable, transigible, cedible y prescriptible, todos aspectos que se analizarán más adelante.

2. OBJETO DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

El objeto de la acción de responsabilidad es obtener la reparación del daño causado, respecto de lo cual procede realizar las siguientes precisiones.

2.1. Formas de reparación

La reparación puede ser en especie (*in natura*) o en equivalente.

(i) **Reparación en naturaleza**

La reparación en especie o *in natura* consiste en la ejecución de actos o adopción de medidas que hagan desaparecer el daño. Así, se busca que el demandante sea restituido en naturaleza a la situación anterior al daño, y por lo mismo se pretende el restablecimiento de la situación alterada por el ilícito, en términos de eliminar todo vestigio del daño posible.

La reparación en naturaleza usualmente tiene un objeto definido por el tipo de daño: si una cosa ha sido deteriorada, se le debe reparar; si ha sido destruida, debe ser reemplazada por otra equivalente; si la víctima ha sufrido lesiones corporales, deben

cubrirse los costos médicos y de hospitalización; si se ha deteriorado el medio ambiente, se le debe restituir.

Pero también puede obtenerse una reparación en naturaleza por medio de conductas que no están dirigidas a restituir, sino que conducen a un resultado equivalente; es el caso, por ejemplo, de la reparación de una difamación mediante la carga de publicar la sentencia que declara incorrecta una información que afecta el nombre ajeno, lo que opera como una especie de restitución moral del ofendido, o la reparación de un atentado a la libre competencia mediante una resolución que ordena poner término a un cierto contrato que es calificado como ilícito. En el extremo, especialmente cuando el daño moral puede ser reparado mediante la publicidad del ilícito que lo ha provocado, la reparación en naturaleza puede asumir la forma de una indemnización simbólica.

(ii) Reparación en equivalente

Por su parte, la reparación “en equivalente” tiene por objeto que el daño sea compensado por un sustituto, que generalmente es una suma de dinero. Esta es la acción que se ejerce más usualmente, y por ello es a la que le daremos un tratamiento más detallado.

(iii) Relación entre una y otra clase de reparación

La doctrina afirma que la víctima tiene la facultad para elegir la forma de reparación que prefiera, aunque la reparación en especie sólo podrá exigirse si es materialmente posible acceder a ella y siempre que no cause un daño desproporcionado, y excesivamente gravoso para el demandado.

En otras palabras, la reparación en naturaleza es una *opción* para el demandante, pues el derecho chileno no establece un orden de precedencia de las acciones. La reparación en naturaleza, sea que el demandado emprenda la restitución por sí mismo o la haga posible mediante una indemnización suficiente para que la víctima pague los costos de reparación, es siempre una alternativa o un complemento a la valoración contable de la pérdida patrimonial neta o del daño moral sufrido. Ello se muestra, por ejemplo, en el caso de una cosa deteriorada: la acción en naturaleza tiene por objeto que el responsable la repare por sí mismo o indemnice a la víctima con una suma equivalente al costo de reparación (en perfecta analogía con las obligaciones contractuales de hacer, según el artículo 1553); la indemnización compensatoria del perjuicio patrimonial neto, por el contrario, tiene por objeto la diferencia del valor de la cosa entre antes y después de haber sido dañada. Como se ha visto, uno y otro método de cálculo de la indemnización pueden conducir a resultados diferentes, que se explican por sus distintas finalidades.

La restitución en naturaleza corrige totalmente el daño o lo disminuye, de modo que produce un efecto reflejo en la acción indemnizatoria: en la medida que el daño disminuye, menor será el monto de la indemnización. Incluso puede considerarse que

constituye un ejercicio abusivo de la acción indemnizatoria si ella es ejercida sin consideración de que la corrección en naturaleza pueda disminuir significativamente los perjuicios. Por otra parte, especialmente en ilícitos de palabra, una indemnización puramente simbólica puede tener el efecto de una reparación en naturaleza, en la medida que supone dar por públicamente establecido lo injusto del daño provocado al demandante.

Por lo mismo, al determinar la indemnización el juez debe valorar el daño remanente si el demandado ha realizado actos de reparación en naturaleza, o debe realizarlos en razón de lo dispuesto en la sentencia (como ocurre con la eliminación de una fuente de malos olores, con la corrección de una información falsa, con las disculpas en caso de un insulto o con la publicación de una sentencia que da por establecido el ilícito del demandado)

2.2. Extensión de la reparación

(i) Principio general: la reparación integral

La Corte Suprema ha resuelto que la ley “obliga a indemnizar el daño, a reparar el perjuicio causado por el hecho ilícito, reparación que, es obvio, deberá ser completa, esto es, igual al daño que se produjo, de modo que permita a la víctima reponer las cosas al estado en que se encontraban a la fecha del acto ilícito”.

En opinión de ALESSANDRI, de este principio emanan las siguientes consecuencias: 1º El monto de la reparación depende de la extensión del daño y no de la gravedad del hecho; 2º La reparación comprende todo el perjuicio sufrido por la víctima que sea una consecuencia necesaria y directa del delito o cuasidelito; y 3º El monto de la reparación no puede ser superior ni inferior al daño.

Por otra parte, la doctrina y jurisprudencia nacional están de acuerdo en que la indemnización debe incluir tanto el daño material como el daño moral.

(ii) Reducción de la reparación

Eventualmente la reparación puede verse reducida en los siguientes eventos:

a) Por disposición legal especial. El art. 2331 señala que las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero. Como se ha expuesto, tradicionalmente la doctrina y jurisprudencia entendían que esta norma excluía el daño moral, cuestión que se fundaría en evitar litigios, en una época en la que los insultos o agresiones eran ordinariamente verbales y no podían afectar en forma tan seria la psique de un individuo.

En todo caso, y como se indicó anteriormente, esta norma ha sido reiteradamente declarada inaplicable por inconstitucional por el Tribunal Constitucional; y adicionalmente la Corte Suprema ha reinterpretado la norma, en el sentido que la misma no contiene una exclusión de la indemnización del daño moral.

b) Por concurrencia de culpa de la víctima. Como se ha indicado, el art. 2330 establece una suerte de “compensación de culpas”, en cuanto dispone que la indemnización está sujeta a reducción por los daños a los que imprudentemente se expuso la víctima.

(iii) Reajustabilidad de la indemnización

En la actualidad se indica que el valor del daño debe también reajustarse para que la indemnización repare completamente el menoscabo sufrido por la víctima.

Según ABELIUK, hoy en día la jurisprudencia y la doctrina se han uniformado en torno a aceptar la reajustabilidad, por dos razones: por la regla general del art. 2329, de que todo daño imputable debe indemnizarse, o sea la reparación debe ser integral y no lo sería si el acreedor la recibiera desvalorizada, y porque sobre todo, a partir de la dictación del D.L. 455 (hoy reemplazado por la Ley N° 18.010), la regla normal de la legislación chilena es la reajustabilidad de las deudas de dinero.

No existe un índice de uso obligatorio para el juez a efectos de establecer la corrección monetaria, aunque en la práctica se utiliza el Índice de Precios al Consumidor.

(iv) Procedencia del pago de intereses

ABELIUK y ALESSANDRI creen que la única manera de que la reparación sea cabal es que ella considere todas las variaciones ocurridas durante el pleito, y si la manera de obtenerlo es el pago de intereses desde la demanda, el juez está facultado, dentro de la relativa libertad que tiene en materia extracontractual, y siempre que ello le haya sido pedido, para fijarlos.

Con todo, determinar el momento a contar del cual deban aplicarse los reajustes y los intereses ha sido objeto de discusión en la jurisprudencia.

En relación con el daño patrimonial, algunas sentencias se pronuncian por aplicar reajustes e intereses desde la fecha del ilícito. En otros casos se ha fallado que deben aplicarse aquí las normas que regulan la mora (art. 1551 del C.C.), y que en consecuencia, los reajustes e intereses corren sólo desde la presentación o desde la notificación de la demanda. Por último, algunos fallos han sostenido que los reajustes e intereses deben considerarse sólo desde la dictación de la sentencia que impone la obligación de indemnizar, e incluso desde que ésta queda ejecutoriada.

Según BARROS, sólo se cumple el principio de que la indemnización (del daño material) deba ser completa si los reajustes e intereses son contabilizados desde que el daño se produce. Estos sólo expresan la cautela del valor (reajustes) como el costo de haber estado privado del goce del bien perdido o lesionado (intereses). Por lo demás, las normas sobre la mora tienen marcado carácter contractual, como se infiere del análisis más detallado del art. 1551. A diferencia de lo que ocurre en materia contractual, la obligación indemnizatoria en sede extracontractual nace con ocasión del mero ilícito que causa daño; no existe una obligación preexistente que se deba tener por incumplida como condición de la responsabilidad.

La jurisprudencia se inclina en materia de daño material a que reajustes e intereses se calculan desde la presentación o notificación de la demanda o bien desde la dictación de la sentencia. Tratándose del daño moral, en cambio, la determinación del cómputo del reajuste e intereses debe regirse por reglas diversas. La valoración de esta especie de daño sólo puede hacerse en la sentencia que ordena indemnizarlo, considerando las circunstancias relevantes del hecho; antes de la sentencia el daño moral no puede ser cuantificado. Por consiguiente, debe preferirse la opinión de que corresponde aplicar reajustes e intereses sólo a contar de la dictación de la sentencia.

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA

La legitimación procesal activa es la titularidad que el sistema jurídico reconoce para ejercer una acción judicial. Los titulares para ejercer la acción de responsabilidad pueden ser titulares por derecho propio o por derecho derivado.

3.1. Titulares por derecho propio

Para determinar los titulares por derecho propio, debe distinguirse entre los que son directamente lesionados por el actuar del autor del ilícito y los que son afectados como consecuencia del daño producido a la víctima directa.

(i) Lesionados directos

a) Daño en las cosas

Si se trata de daños causados a las cosas (bienes patrimoniales) pueden interponer la acción para hacer valer la responsabilidad tanto el *dueño* como el *poseedor*. Tendrán acción además todos aquellos que *detentan otros derechos reales sobre la cosa*, como el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a sus respectivos derechos.

El *mero tenedor* no tiene derechos sobre la cosa, en consecuencia, no puede reclamar su valor en caso de pérdida o deterioro mediante acción directa. Sólo podrá accionar en

ausencia del dueño y en tal caso se entenderá que lo hace a nombre de éste y no a título personal (artículo 2315 del Código Civil).

Sin embargo, el mero tenedor está legitimado para ejercer la acción indemnizatoria como titular de un derecho personal que se ejerce sobre una cosa, como el arrendatario, por el perjuicio que experimenta su crédito.

b) Daño en las personas

También son legitimados los que sufren una lesión directa en intereses o derechos no susceptibles de evaluación económica. Sea que concurra o no con un daño material, los afectados en los bienes extrapatrimoniales pueden demandar para pedir la reparación del daño moral.

(ii) Lesionados indirectos o víctimas por repercusión

Los lesionados indirectos son aquellos que reciben un daño, no directamente a su persona o bienes, sino por sufrir ellos las consecuencias de un daño causado a una persona con la cual tienen alguna relación.

Así, se reconoce titularidad activa a la víctima indirecta, que es aquella que sufre un daño patrimonial o moral a consecuencia del daño experimentado por la víctima directa, como el dolor que causa la muerte de un ser querido.

Tratándose de daños patrimoniales, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido titularidad a todo aquel que recibía una ayuda económica de la víctima directa, aún cuando no tuviese derecho a ella, de la que resulta privado a consecuencia del accidente, como el caso del padre que pierde la ayuda pecuniaria y personal de su hijo ilegítimo.

En materia de daño moral, en cambio, la regla general es que sólo se concede acción a la víctima indirecta en caso de muerte, a condición de que se acredite un parentesco cercano con la víctima directa. Excepcionalmente, se concede acción para reclamar indemnización por el daño moral en caso de lesiones, cuando estas son de tal entidad que en los hechos imponen una obligación de cuidado que afecta la calidad de vida de la víctima indirecta. Tal es el caso del pariente de la víctima directa que debe hacerse cargo de su invalidez.

3.2. Titulares por derecho derivado

(i) Sucesores mortis causa

Pueden interponer la acción los sucesores a título universal, esto es, los herederos de los legitimados por derecho propio. El Código Civil sólo lo señala expresamente respecto del

daño en las cosas: “puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o *su heredero*” (art. 2315). Pero lo mismo se sostiene respecto de los daños personales, pues se aplican los principios de la transmisibilidad de los derechos.

(ii) Cesionarios

El derecho a pedir indemnización de perjuicios ya devengados puede ser objeto de una cesión por acto entre vivos. La cesión procede aunque el daño a reclamar sea de naturaleza moral, ya que la indemnización tiene un carácter patrimonial y no hay norma que prohíba su transferencia.

3.3. Titularidad de las “clases de perjudicados”

En el *common law* existe la institución de las acciones de clase o *class actions*, por la cual se acepta que uno o más miembros de una categoría o clase de personas demande invocando el interés común, siempre que la clase sea tan numerosa que haga impracticable el Litis consorcio, que se acredite que hay cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, que las demandas o excepciones de las partes sean típicas respecto de las demandas o excepciones de la clase y que las partes representativas protegerán equitativa y adecuadamente el interés de la clase.

En nuestro ordenamiento jurídico no existe una norma general que admita tal titularidad, por lo que deberá darse aplicación al art. 18 del Código de Procedimiento Civil, que permite la acumulación de acciones que emanen directa e inmediatamente de los mismos hechos, pero cuyos titulares las interpongan expresamente por sí o por mandatario común.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley N° 19.995 del año 2004 introdujo una serie de modificaciones a la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos del Consumidor, estableciendo al efecto una suerte de acción de clase, únicamente aplicable para tal marco normativo. En particular, el art. 50.3 de la referida ley establece que “El ejercicio de las acciones puede realizarse a título individual o en beneficio del *interés colectivo o difuso* de los consumidores”, agregando el inc. 5° que “Son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual”, y que “Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos”.

3.4. Acción popular

La ley en general otorga acción popular para la prevención del *daño contingente*, pero si él amenaza solamente a personas determinadas, a ellas pertenecerá la acción. Así lo señala el art. 2333: “por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño

contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare a personas determinadas sólo alguna de éstas podrá intentar la acción”.

La ley señala, además, reglas particulares para ciertos casos, como ocurre con la denuncia de obra ruinosa, de que tratan los arts. 932 y siguientes del Código, y el inc. 2º del art. 2328.

Dispone este precepto: “si hubiere alguna cosa que, de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado, amenace caída y daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa o que se sirviere de ella; y cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción”.

Finalmente, el art. 2334 señala el efecto de estas acciones populares: si ellas “parecieren fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de su acción, y se le pagará lo que valgan el tiempo y diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados”.

4. LEGITIMACIÓN PASIVA

En términos generales la acción de indemnización de perjuicios se dirigirá contra todo aquel que responde del daño.

4.1. Autor del hecho ilícito

En primer término, es legitimado pasivo el autor del daño (art. 2316.1º).

La jurisprudencia afirma que en el autor del daño se comprende al cómplice, pero no al encubridor, lo que no ha estado exento de críticas.

Es posible que los autores sean varios, y en tal caso nuestro Código, estableció entre todos ellos la responsabilidad solidaria. Dice el art. 2317: “si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328”.

Estas excepciones son las ya vistas: del edificio cuya ruina causa daños y pertenece a una comunidad, en que la indemnización se divide entre los copropietarios a prorrata de sus cuotas, y de las cosas que se arrojan o caen de la parte superior de un edificio, en que la indemnización, si no puede imputarse dolo o culpa a persona determinada, se divide por partes iguales entre todos quienes habitan dicha parte del edificio.

Para que proceda la solidaridad es necesario que dos o más personas hayan participado como autores o cómplices en la comisión de un mismo delito o cuasidelito. Si se han

cometido distintos delitos o cuasidelitos respecto de la misma víctima, como si por ejemplo, una persona es atropellada primero por un vehículo, y vuelve a ser atropellada por otro por haber quedado botada en el camino, no hay solidaridad.

Otro caso de solidaridad previsto por la ley es el de la responsabilidad del propietario de un vehículo que lo ha dado o prestado a otra persona para su conducción.

4.2. Responsable del hecho ajeno

La acción podrá intentarse contra la persona que responde del hecho ajeno, como por ejemplo, contra el padre por los hechos ilícitos del hijo menor que vive con él, que figurará en el proceso criminal si el juez en lo penal conoce de la demanda civil, como tercero civilmente responsable, pero sin que lo afecte naturalmente responsabilidad penal.

4.3. El que recibe provecho del dolo ajeno

De acuerdo al art. 2316.2: “el que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho”.

El hecho de que el precepto excluya al cómplice es el argumento para decidir que su responsabilidad es la misma del autor. En cambio, el encubridor del delito queda afecto a esta obligación de indemnizar hasta el monto del provecho recibido.

La responsabilidad se limita al caso de dolo, pero no de culpa, o sea, tiene lugar únicamente en los delitos, pero no en los cuasidelitos, y es la misma solución que da el art. 1458.2 respecto del dolo en la formación del consentimiento: si es incidental no vicia éste, pero da acción contra los que lo han fraguado o aprovechado de él, respecto de estos últimos hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo;

La acción es, en este caso, restitutoria de un enriquecimiento sin causa. Quien, por el contrario, conoce de la existencia del dolo pero es reticente en prevenir de su existencia con el propósito de aprovecharse de sus efectos, es considerado autor en razón de esa reticencia y responde por el total de los perjuicios

4.4. Los herederos

Finalmente, la obligación de indemnizar es transmisible conforme a las reglas generales.

5. TRIBUNAL COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO

La regla general es que si el hecho ilícito lo es a la vez civil y penalmente, la competencia pertenece indistintamente al juzgado civil o penal, a elección de la víctima.

Si el hecho es ilícito penalmente, corresponderá conocer de la indemnización al mismo tribunal que juzga el delito o cuasidelito, o al juez civil que sea competente de acuerdo a las reglas generales; si el hecho ilícito no tiene sanción criminal es únicamente competente el juez civil, como por ejemplo si se trata de un cuasidelito de daños.

Si tratándose de un delito de acción privada se ejerce solamente la acción civil, se entiende por ello renunciada la penal.

El juicio indemnizatorio ante los juzgados del crimen se sujeta en cuanto a su procedimiento a las reglas que señala al efecto el Código Procesal Penal, pero no por ello deja de ser civil.

Ante los juzgados civiles, sigue las reglas del juicio ordinario sin variantes especiales. Cabe tener presente únicamente que el juicio civil puede quedar en suspenso, según lo dispuesto por los arts. 167 del Código de Procedimiento Civil, hasta la terminación del juicio criminal, y siempre que en éste se haya dado lugar al plenario.

Conviene eso sí tener presente que según la jurisprudencia, en materia extracontractual no se aplica el art. 173 del Código de Procedimiento Civil, que permite reservar para la ejecución del fallo o en juicio diverso lo relacionado con la especie y monto de los perjuicios, siempre que estén establecidas las bases para su liquidación. En los delitos y cuasidelitos, en un solo juicio deben establecerse todos estos factores.

Por regla general, para cada uno de los elementos cuya presencia conjunta determina la existencia de un hecho ilícito, la prueba corresponderá a la víctima, sin limitaciones de ninguna especie, puesto que se trata de acreditar un hecho: puede valerse de todos los medios de prueba que la ley franquea.

6. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La acción de responsabilidad se extingue, en general, por los medios de extinguir las obligaciones, pues su objeto es hacer valer una pretensión indemnizatoria. No obstante es conveniente detenerse en algunos modos de extinción, como la renuncia, la transacción y la prescripción.

6.1. Renuncia

De acuerdo a la regla general del art. 12 no hay duda de que puede renunciarse a la reparación del daño, una vez producido. En consecuencia, la renuncia es un acto de disposición que extingue la acción si es efectuada con posterioridad al hecho que genera la responsabilidad.

La autorización que la víctima del accidente da con anterioridad a su ocurrencia, constituye técnicamente una causal de justificación, que opera como eximente de responsabilidad

6.2. Transacción

Este modo de extinguir la responsabilidad extracontractual lo admite expresamente el Código Civil en el art. 2449: “La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito; pero sin perjuicio de la acción criminal”. Las partes pueden componer libremente la indemnización ya devengada.

6.3. Prescripción

El art. 2332 establece un plazo especial de prescripción para la acción de indemnización, en los siguientes términos: “*Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto*”.

Este plazo de prescripción sólo se refiere a la acción de indemnización que nace del delito o cuasidelito civil, y no a otras acciones que pueden corresponder a la víctima, como la reivindicatoria si ha sido objeto de robo, hurto, usurpación, etc., que se rige por su propio término de prescripción. Y es sin perjuicio de los plazos señalados en leyes especiales, y en el propio Código en caso de ruina de un edificio, en que el plazo es de 5 años en cuanto a la responsabilidad del empresario; y de un año por los daños a los vecinos (art. 950, inc. 1º).

En cuanto al **cómputo del plazo** se ha generado bastante debate. Como el precepto habla de la “perpetración del acto” como momento inicial del transcurso de la prescripción, la jurisprudencia y la doctrina entendían habitualmente que ella comenzaba a correr desde el instante de la acción u omisión imputable del hechor, aunque el daño se ocasionara posteriormente. De ordinario ambos momentos van a coincidir, pero no ocurre siempre en esta forma.

Así se había fallado habitualmente en relación a la responsabilidad extracontractual de los conservadores de bienes raíces, por el otorgamiento de certificados de gravámenes y prohibiciones con omisión de una hipoteca debidamente inscrita; con el mérito de ellos los acreedores habían facilitado dineros al deudor, y al tiempo de rematar la propiedad no alcanzaron a pagarse por haberse hecho presente el acreedor de la hipoteca omitida en el certificado. No se negaba la responsabilidad del Conservador por este daño, pero de acuerdo a la distinción antes mencionada, se contaba el plazo de la prescripción desde el otorgamiento del certificado erróneo, y no desde la fecha del daño, que ocurre cuando la segunda hipoteca no puede cancelarse.

Para ABELIUK esta interpretación es incorrecta, pues conduce al absurdo de que la acción resulte prescrita antes de nacer, porque es requisito de la indemnización la existencia del daño. Antes de que éste se produzca, la víctima nada puede demandar, pues no ha sufrido

perjuicio. Los hechos ilícitos se definen precisamente como las acciones u omisiones culpables o dolosas que causan daño; al hablar de perpetración del acto, el Código se está refiriendo a este concepto que incluye el daño. Evidentemente, la víctima no podría cobrar pasado el cuadrienio otros perjuicios sobrevenidos posteriormente, porque desde el momento que hubo daño se completó el hecho ilícito y comenzó a correr la prescripción.

La jurisprudencia ha resuelto de una y otra forma.

En cuanto a la **suspensión**, tradicionalmente se ha sostenido que se trataría de una prescripción de corto tiempo especial y que por tanto se aplicaría el art. 2524 que declara la improcedencia de la suspensión. Respecto de la **interrupción** rigen las reglas generales, sin perjuicio de considerar al efecto la posibilidad de iniciar un proceso criminal relativo a un hecho del que emane una acción penal y una civil.

VIII.

RESPONSABILIDAD CIVIL

CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

Sobre la base de la distinción romana de las fuentes de las obligaciones, recogida en el artículo 1437 del Código Civil, el estudio de la responsabilidad civil ha sido dividido históricamente en dos grandes estatutos: la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Según la opinión mayoritaria, ambos pertenecen a esferas distintas; así, mientras la responsabilidad contractual se origina en el incumplimiento de un contrato, la segunda tiene su fuente en un hecho que ocasiona un daño, sin que exista un vínculo previo entre el autor de ese daño y la víctima.

En todo caso, ambos estatutos de responsabilidad comparten un objetivo común: dar lugar a una acción civil de indemnización de perjuicios, que persigue la reparación pecuniaria de los daños sufridos por el hecho de un tercero.

En este capítulo se analizarán los principales aspectos relativos a ambos regímenes de responsabilidad.

1. DISCUSIÓN ACERCA DE LA DUALIDAD O UNIDAD DE REGÍMENES

Atendido el recién indicado objetivo de ambas responsabilidades (reparación pecuniaria de perjuicios), parte de la doctrina comparada ha sostenido que la responsabilidad civil debe ser tratada bajo un estatuto único.

Al efecto, la *teoría de la unidad de la responsabilidad civil* tiende fundamentalmente a equiparar ambas categorías de responsabilidad, considerando que siempre representan una actuación contraria a derecho que da origen a la obligación de indemnizar los perjuicios que ocasiona la contravención.

La teoría unitaria se sustenta, en primer término, en el hecho que el hecho ilícito y el incumplimiento contractual son ambos manifestaciones de una actuación contraria al derecho, y sancionados civilmente con el resarcimiento del daño ocasionado; esta obligación nace con el hecho ilícito o la infracción del contrato, y en este último caso pasa a sustituir a la obligación propia de éste. Se ha replicado que ello no es efectivo, porque desde luego la indemnización moratoria no viene a sustituir a la obligación anterior, sino que coexiste con ella; y enseguida, porque el incumplimiento no da necesariamente lugar a esta transformación de la obligación sino cuando el cumplimiento en naturaleza deja de ser posible. Si puede obtenerse aun el cumplimiento, se dará lugar a éste forzosamente, y podrá proceder, además, la indemnización moratoria. El incumplimiento no ha dado necesariamente nacimiento a una obligación nueva, como ocurre en el hecho ilícito.

Adicionalmente, la teoría unitaria afirma que entre ambos estatutos existe una identidad de elementos fundamentales: una acción u omisión imputable al causante del daño, la existencia de éste y la relación de causalidad entre la conducta del responsable y el perjuicio de la víctima. Sin embargo, entre ambos regímenes existen evidentes diferencias, como es el de la graduación y presunción de la culpa, la mora, y otras más que se analizarán en detalle en el siguiente apartado.

Dicho lo anterior, cabe anotar que la doctrina predominante en Chile es la que sustenta la *dualidad de la responsabilidad civil*, en cuanto la responsabilidad contractual supone una obligación anterior y se genera entre personas ligadas por un vínculo jurídico preexistente; en cambio, la responsabilidad aquiliana supone la ausencia de una obligación previa, se produce entre personas hasta entonces jurídicamente extrañas y es ella la que crea la obligación de reparar el daño.

A ello se agrega que claramente el Código Civil ha seguido la tesis de dualidad de regímenes, como lo comprueban las siguientes normas: (i) el art. 1437, que opone como distintas fuentes de obligaciones el contrato y el “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos o cuasidelitos”; (ii) el art. 2284 que también distingue como fuentes de obligaciones la convención y los hechos ilícitos; (iii) la responsabilidad contractual tiene un régimen legal especial consagrado en los arts. 2314 y siguientes.

2. DIFERENCIAS ENTRE AMBAS RESPONSABILIDADES

Las principales diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual son las siguientes:

- a) *Prueba de la culpa.* En sede contractual, producido el incumplimiento, la culpa del deudor se presume, y a éste corresponde acreditar que actuó con la diligencia debida (art. 1547). En cambio, en la responsabilidad extracontractual corresponde a la víctima (acreedor) probar la culpa. Cabe advertir que este principio no es absoluto, ya que en ciertos casos también se presume la culpa en materia extracontractual.
- b) *Graduación de la culpa.* En materia contractual la culpa admite graduaciones: grave, leve y levísima (art. 44) y existe responsabilidad dependiendo del grado de culpa exigible. Por su parte, buena parte de la doctrina afirma que en materia extracontractual se responde de toda culpa (incluso levísima), punto que en todo caso se ha visto que es sumamente discutible.
- c) *Necesidad de la mora.* Para que exista responsabilidad contractual es necesaria la constitución en mora del deudor (arts. 1557 y 1538). En cambio, en la responsabilidad extracontractual la obligación de indemnizar nace cuando se produce el hecho ilícito dañoso, sin necesidad de constituir en mora.

d) *Capacidad o imputabilidad del obligado.* Sólo son incapaces de delito o cuasidelito civil los dementes, los menores de 7 años, y los mayores de esta edad, pero menores de 16 años cuando han obrado sin discernimiento. Las incapacidades contractuales son más amplias; desde luego, la mayor edad es a los 18 años, y existen otras fuera de la edad o privación de razón: disipador interdicto, etc.

Esta diferenciación se la justifica diciendo que es más fácil distinguir lo lícito de lo ilícito que responder de los daños en el cumplimiento de un contrato.

e) *Solidaridad.* En materia contractual, la obligación de indemnizar es por regla general conjunta, salvo casos de excepción en los que expresamente existe una fuente de solidaridad (como lo es la ley, el testamento o la convención). En cambio, en la responsabilidad extracontractual hay solidaridad en todos los casos en que un delito o cuasidelito es cometido por dos o más personas, salvo ciertas excepciones (art. 2317.1). Sin embargo, la doctrina extiende esta solidaridad a los casos en que el incumplimiento contractual se ejecuta con dolo o culpa grave por parte de dos o más deudores (art. 2317.2).

f) *Extensión de la obligación de reparar.* Se suele indicar que la indemnización extracontractual es más completa que la contractual; la facultad de los jueces es por ello más amplia en la primera.

En ambas se responde de los perjuicios previstos. En la responsabilidad contractual sólo se responde de los perjuicios imprevistos en los casos de convención en tal sentido, dolo o culpa grave, mientras que en la extracontractual no se responde de ellos (sin perjuicio que ciertos autores afirman que en sede extracontractual siempre se responde de los perjuicios imprevistos, lo que es errado conforme a la doctrina moderna).

Del daño moral se responde incuestionablemente si se ha cometido un hecho ilícito; en materia contractual el punto se discute (aunque en la actualidad se acepta su reparación en sede contractual).

g) *Avaluación de perjuicios.* En materia contractual se permite la avaluación anticipada de los perjuicios mediante una cláusula penal, de manera que es posible exigirse la pena por el sólo incumplimiento y sin necesidad de que se prueben los daños sufridos. Esto no es admisible en la responsabilidad extracontractual, ya que ésta no es concebible sin que se acredite el monto de los daños, que son la justificación y la medida del deber de reparar.

h) *Efectos del dolo.* En cuanto al dolo como elemento constitutivo de ambas responsabilidades, si bien su concepción es la misma de acuerdo a la teoría unitaria del dolo, sus efectos son diferentes: en materia extracontractual no produce otros distintos a la culpa (salvo lo dispuesto en el art. 2316), mientras que es una agravante de responsabilidad en el cumplimiento de los contratos.

i) *Prescripción*. La de acción de indemnización por incumplimiento de una obligación es de largo tiempo: 5 años desde que se hizo exigible. En cambio, la extracontractual es de corto plazo: 4 años desde la perpetración del hecho ilícito, sin perjuicio de las excepciones en uno y otro sentido.

3. CÚMULO O CONCURSO DE RESPONSABILIDADES

Bajo el concepto de *cúmulo de responsabilidad* la doctrina se ha referido tradicionalmente al problema de la concurrencia de los dos estatutos de la responsabilidad civil, en aquellos casos en que un mismo hecho importa a la vez el incumplimiento de una obligación contractual y la ocurrencia de un delito o cuasidelito civil.

Bajo el concepto de *cúmulo de responsabilidad* se agrupan dos cuestiones de naturaleza diversa: la primera consiste en determinar si la víctima puede *optar* por el estatuto de responsabilidad que le resulte más provechoso; la segunda, si las acciones que emanan de ambos estatutos son *acumulables*.

La palabra *cúmulo* hace más bien referencia a este último sentido, que plantea pocas dificultades: la responsabilidad contractual no se puede acumular a la extracontractual porque ello se traduciría en un enriquecimiento sin causa de la víctima (que sería indemnizada por dos conceptos diferentes por un mismo daño). Por eso, el sentido relevante del *cúmulo de responsabilidad* se refiere a las situaciones en que, en principio, resultan aplicables los dos estatutos alternativamente y se trata de resolver si la víctima en tales circunstancias puede optar por demandar según el estatuto que le resulte más favorable.

Así, el problema se concibe como una *opción* de la víctima: si el incumplimiento inviste a la vez el carácter de un hecho ilícito por concurrir los requisitos propios de éste, ¿podría la víctima, según le fuere más conveniente, cobrar los perjuicios conforme a las reglas de la responsabilidad contractual o extracontractual a su elección? Así, por ejemplo, el pasajero conducido por una empresa podrá cobrar a ésta conforme a la responsabilidad contractual por la obligación de seguridad ya señalada, y así favorecerse de la presunción de culpa del demandado, o demandarla conforme a los arts. 2314 y siguientes, y así poder, por ejemplo, cobrar sin discusión posible los morales. Dicho de otra manera, se trata de saber si el demandante podría decir que, según el Título 35 del Libro 4º, todo daño que revista los caracteres de delito o cuasidelito civil, obliga a indemnizarlo conforme a dichas disposiciones, y en consecuencia, cobrarlos de acuerdo a ellas, dejando a un lado las que gobiernan la responsabilidad contractual.

Tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia nacional se manifiestan en contra de la opción entre ambos estatutos de responsabilidad. Según esta opinión, conceder la posibilidad de optar entre una u otra acción para reclamar la indemnización de los

perjuicios importaría desconocer la obligatoriedad del contrato, que conforme al artículo 1545 del Código Civil, vincula a las partes con la misma fuerza que la ley. A ello se agrega que en opinión mayoritaria de la doctrina la especialidad de la responsabilidad contractual prima sobre la responsabilidad extracontractual, a la que se asigna un carácter residual. Como se advierte, esta posición importa privilegiar el principio obligatorio del contrato, en virtud del cual los deberes generales de respeto recíproco (típicos de la responsabilidad extracontractual) ceden frente a la relación obligatoria consentida en el contrato.

Sin embargo, en opinión de la doctrina y de alguna jurisprudencia, bajo ciertas circunstancias la opción resulta excepcionalmente procedente. En particular, ALESSANDRI, con el apoyo de cierta la jurisprudencia, señala dos casos de excepción en que el demandante podría elegir entre demandar la responsabilidad contractual y la extracontractual:

- (i) *Si las partes así lo han convenido.* En ello no hay nada excepcional a las reglas de la responsabilidad contractual, porque las partes pueden modificar las normas legales supletorias como estimen conveniente, y si están facultadas para hacer aplicables una por una todas las soluciones de la extracontractual, con mayor razón para hacerla aplicable integralmente o darle opción al acreedor.
- (ii) *Cuando la infracción al contrato constituye típicamente un delito o cuasidelito penal,* como ocurre en los casos del art. 470 N° 1 y 491 del C.P., porque -se dice- de todo delito nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer una civil para obtener la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado (art. 10 del C.P.P., antes de la reforma de la ley 18.857) (Según ABELIUK, esto es muy dudoso, porque el art. 10 del C.P.P. no dice que siempre nazca acción civil, sino que puede nacer cuando está establecido en la ley, o sea, se remite lisa y llanamente a las normas del Derecho Civil).

Por su parte, CORRAL es de la opinión que procede el concurso de responsabilidades cuando prescindiendo del contrato, el daño causado sería igualmente indemnizable por generar responsabilidad extracontractual. Ello sería aplicable no sólo cuando el hecho es penalmente sancionable, sino también cuando el ilícito es sancionado por normas civiles o contravencionales o por violación del *neminem laedere*. No obstante, el cúmulo no será admisible y deberá aplicarse el régimen contractual cuando las partes expresamente lo hayan establecido en el contrato, o cuando, a falta de estipulación expresa, el sometimiento a la distribución de los riesgos previstos en el contrato es una cláusula que emana de la naturaleza de la relación contractual o es impuesta por el principio de la buena fe.

4. EJERCICIO CONJUNTO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL

En los casos en los que se admite el cúmulo, puede preguntarse si es admisible que se ejerzan simultáneamente por la víctima en un mismo proceso la acción de responsabilidad contractual y la de responsabilidad extracontractual. En la medida que se acepte para ciertos casos la opción de responsabilidades, el demandante podrá deducir ambas acciones, pero *una en subsidio de la otra*, ya que ambas deben entenderse incompatibles entre sí (art. 17.2 del Código de Procedimiento Civil).

Por su parte, cuando un mismo hecho importa responsabilidad contractual para las partes y extracontractual para un tercero, no habrá inconvenientes en admitir la acumulación procesal de ambas acciones, en conformidad al artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, ya que las acciones proceden directa e inmediatamente del mismo hecho.

5. RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

La responsabilidad precontractual es la que se genera por el daño causado en las fases preparatorias que aún no han concluido en la celebración de un contrato.

La doctrina ha señalado que la regulación legal de la formación del consentimiento no recoge adecuadamente la realidad práctica, en cuanto, previo a la oferta, suele existir un período previo de negociación o tratativas preliminares.

Se indica que “se denomina etapa de negociación preliminar al período en que las partes desarrollan una multiplicidad de conductas tendientes a conocer sus puntos de vista respecto de un negocio que se proyecta, sin que por ello entiendan quedar obligadas”.

El tema ha sido objeto de un muy detallado análisis a fin de establecer si, en esta etapa previa a la formación del contrato, podría o no surgir una responsabilidad para los partícipes de la negociación; responsabilidad que suele denominarse “*precontractual*”

Sobre la materia, es necesario considerar que durante el período precontractual aún no hay intención de obligarse, sino que existe libertad para negociar, debatir distintas posturas, y así explorar si es o no bueno contratar, intercambiando información.

La *doctrina tradicional* señala que el principio que impera es el de la libertad de contratar y, por lo tanto, hay ausencia de obligaciones, consecuentemente no existe reproche si hay un desistimiento unilateral y no hay responsabilidad porque se ejerce el libre derecho de desistirse del eventual contrato, aunque haya daños.

La *doctrina moderna*, en cambio, cree que sí puede haber responsabilidad.

Al respecto, FAGUELLA sostiene que habrá responsabilidad cuando una de las partes se retira arbitrariamente de las negociaciones, y es arbitrario cuando hay una violación de la confianza que se genera al consentir, al tratar, o bien cuando se viola el “pacto de garantía” al negociar, que tiende a resguardar que las negociaciones seguirán su curso normal hasta llegar a la celebración de un contrato o hasta el fracaso de las negociaciones, por existir intereses económicos irreconciliables.

Se critica a FAGUELLA por ser muy rígido lo que plantea, nadie negociaría en esas condiciones. Por lo mismo, otros autores (v. gr. SALEIYES) afirman que dice que no puede haber responsabilidad sin culpa; y hay culpa cuando se infringen los usos impuestos y la equidad comercial.

En el sistema chileno, Hugo ROSENDE señala que para que nazca responsabilidad precontractual se requiere:

- a. Que exista consentimiento en las tratativas preliminares o acuerdo en negociar. Siempre se debe respetar el principio de la libertad para negociar (decidir si se contrata o no), pero cuidando de respetar el patrimonio ajeno. Las partes deben ejercer su libertad dentro del marco de la buena fe que morigeró lo anterior. Si se viola la buena fe negociando y se causa un daño con culpa, cabe la indemnización pues se está cometiendo un ilícito civil. Si el hecho es ilícito hay un delito civil. Si el hecho es lícito también podría haber responsabilidad precontractual, pues puede tratarse de un caso de enriquecimiento sin causa.
- b. Que se hayan efectuado gastos por una de las partes en vías del contrato. Hay que distinguir:
- si las partes si han estipulado la forma en que se han de solventar los gastos, accidentes, etc., regirá el acuerdo entre las partes de la negociación habrá, consecuentemente responsabilidad contractual;
 - en cambio, si no se ha estipulado nada al respecto, hay que determinar quién paga por ellos en la etapa de negociación. Habrá que ver si los gastos se realizaron antes de la negociación o durante ella. (i) Respecto de los gastos incurridos antes de la negociación, estos son de cargo de quien los realiza, por ejemplo: gastos por publicidad, esto es así porque van en beneficio propio, salvo que otro se haya aprovechado también de los gastos pues, en ese caso, habría enriquecimiento sin causa en la medida que no sea motivo de lucro para quien se empobreció. (ii) Respecto de los gastos incurridos durante las tratativas, hay que distinguir quien hizo el gasto y quien se beneficia. No hay derecho a reembolso respecto de los gastos que se hacen por iniciativa propia y van en beneficio propio. En cambio, respecto de los gastos que se hacen por iniciativa propia y benefician a ambos, habrá derecho a repetir cuando existe enriquecimiento sin causa.
- c. Debe existir un retiro unilateral de las negociaciones contrario a la buena fe, desde el momento en que hay un retiro se materializa el riesgo de no realizar el negocio, hay certeza de la no realización del negocio. Sin embargo, no por el solo hecho del retiro hay responsabilidad, porque si así fuera nadie negociar. Hay que buscar un equilibrio entre la libertad para negociar y el respeto al patrimonio ajeno, y ese equilibrio es la buena fe.

Se ha discutido mucho en doctrina si la responsabilidad que puede derivar para alguna de las partes por los daños originados a la otra en la etapa previa a la formación del contrato, es contractual o extracontractual.

La opinión más general se inclina por esta última doctrina, puesto que la contractual supone un contrato y éste no se forma aún. IHERING, en cambio, sostenía que se daba en este caso la culpa *in contrahendo*, de orden contractual, como lo es el acto que se iba a otorgar.

ALESSANDRI distingue las responsabilidades expresamente previstas por la ley, en los casos de los arts. 98, inc. final, y 100 del Código de Comercio, que por ser legales, se rigen, según dicho autor, por la responsabilidad contractual, que sería según él la regla general entre nosotros; toda otra responsabilidad precontractual derivada de la ruptura de las negociaciones preliminares es extracontractual, pues tales negociaciones no crean entre las partes ningún vínculo jurídico.

Sin embargo, conforme a buena parte de la doctrina, a la que adherimos, las normas comunes en materia de responsabilidad por hechos ilícitos son las de la responsabilidad extracontractual; y por tanto, la responsabilidad precontractual —incluida la

responsabilidad relativa a obligaciones legales relacionadas con la oferta— se rige por dicho marco normativo.

Por último, el contrato preliminar, como una promesa de contrato, dado que es contrato, origina responsabilidades netamente contractuales.

6. RESPONSABILIDAD DE QUIEN CAUSA LA NULIDAD DEL CONTRATO

La doctrina ha discutido arduamente en torno a la naturaleza de la responsabilidad derivada de la nulidad, en el sentido de si ésta es contractual, extracontractual, legal, o incluso sui generis. En buena medida, el problema está dado por el hecho que en esta materia hay una relación, un contacto social, que impone ciertos deberes de lealtad, y que son distintos a los deberes que nacen de un contrato ya celebrado (y que dan lugar a responsabilidad contractual), o los que impone el mero contacto social general que se limita al deber de no causar daño a la persona o propiedad de otro (y que dan lugar a responsabilidad extracontractual).

Sin perjuicio de lo anterior, buena parte de los autores desestima la aplicación de las reglas de la responsabilidad contractual, por cuanto esta es la que emana de una infracción contractual. Y en este caso la imputación que se hace al responsable es por hechos previos al contrato, aunque conectados con las circunstancias de su celebración, pero precisamente la nulidad declarada del mismo pulveriza jurídicamente la existencia del contrato.

Por su parte, RODRÍGUEZ GREZ estima que se trata de una responsabilidad legal. Al efecto, este autor afirma que “la obligación de indemnizar perjuicios, cuando se declara la nulidad de un acto o contrato, nace de la ley, aun cuando es efectivo que esta responsabilidad supone culpa o dolo de parte de quien causa el daño. Pero las norma de responsabilidad extracontractual no son aplicables íntegramente en este evento, especialmente atendiendo a que sólo en algunos casos es posible concebir el derecho indemnizatorio que emana de la nulidad judicialmente declarada”.

Finalmente, varios autores nacionales, entre ellos BARAONA, afirman que la responsabilidad es de naturaleza extracontractual, pero los elementos que configuran la culpa deben ser analizados en cada caso, pues ciertos supuestos conectan con criterios de buena o mala fe o expectativa de confianza, que han de configurarse de una manera peculiar y por lo mismo distinta a la noción general de culpa o negligencia. En lo demás debe calificarse como extracontractual.

7. RESPONSABILIDAD POST CONTRACTUAL

La doctrina se ha cuestionado cuál de los dos regímenes debe regir para la reparación de los daños causados por una de las partes a otra con motivo de la celebración del contrato, pero por hechos posteriores a su expiración. Por ejemplo, si después de terminado un

contrato de trabajo el trabajador transfiere información reservada de la otra parte a empresas de la competencia.

Algunos ven aquí casos de proyección de la responsabilidad contractual por entender que existen acuerdos tácitos que pueden sobrevivir al contrato mismo (de secreto, de no concurrencia). Para otros, esta construcción elude la realidad: que el contrato ha expirado y no puede regir la responsabilidad que se genera con posterioridad, de modo que se postula la aplicación del régimen extracontractual.

CORRAL se inclina por la segunda postura, pero con la salvedad de que si la ley sanciona el ejercicio abusivo de la facultad de poner término a un contrato con la conservación del contrato, la responsabilidad que se genera será contractual.